



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون
قسم الفقه المقارن

قضايا المعاملات المالية المعاصرة

الفرقة الثانية

شعبة شريعة إسلامية

إعداد

أ. د / أسماء فتحي علي	أ. د / شفيقة الشهاوي رضوان
أستاذ، ورئيس قسم الفقه المقارن بالكلية	أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بالكلية
أ. د / زينب عياد حسن	
أستاذ الفقه المقارن المساعد بالكلية	

تنسيق

د / أمل محمد سيد قوشتي	د / فاطمة عبدالله سعد شوقي
مدرس الفقه المقارن بالكلية	مدرس الفقه المقارن بالكلية

للعام الجامعي

١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل ﴿مَا قَرَّرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] والصلاة والسلام على رسوله الكريم أرسله ربه رحمة للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،،،

فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد وهدايتهم إلى سبيل الرشاد، ولهذا نظمت المعاملات المالية تنظيمًا دقيقًا، ومع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه اليوم كشف لنا العلم الحديث عن وقائع وحوادث تتعلق بالمعاملات المالية لم تكن معروفة عند فقهاءنا الأجلاء كالتعامل بالهامش، والبطاقات الائتمانية، والشرط الجزائي (غرامات التأخير) والإجارة المنتهية بالتملك، وعقود التوريد، وأحكام المناقصات وعقد التوريد فهذه الموضوعات من نوازل المعاملات التي تحتاج إلى بيان أحكامها ولما كانت الشريعة عطاؤها وهداياها لا يقف عند حد زمني أو مكاني، فما من معاملة من هذه المعاملات سالفة الذكر إلا ولها حكم في فروع الشريعة أو قواعدها.

وهذه الدراسة قد أعدت لطلاب وطالبات الفرقة الثانية شعبة الشريعة الإسلامية وقد روعي فيها سهولة العبارة والمدة الزمنية المحددة للمنهج.



وختاماً: فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمن أنفسنا،
هذا والله تعالى هو الأعلم بالصواب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

الأهداف العامة للمقرر:

- ١ - مرونة وصلاحيّة الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.
- ٢ - الربط بين المسائل الفقهية التي وردت في كتب المتقدمين والقضايا المستحدثة للوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل الفقهية.
- ٣ - تزويد الطالب بمعلومات فقهية تساعد في حياته العملية.

وبنهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

- ١ - يتعرف على الأحكام المستحدثة في المعاملات المالية.
- ٢ - يشرح بطاقات الائتمان ويعرف الجهات المصدرة لها وأنواعها، والتوصل إلى الحكم الشرعي.
- ٣ - يستخلص أثر التعامل ببطاقات الائتمان على المجتمع والاقتصاد.
- ٤ - يذكر أقوال العلماء في الشرط الجزائي، ويفهم العوامل التي ساعدت على العمل به.
- ٥ - يتعرف الإجارة المنتهية بالتمليك وما هو محرم ومباح من صورها.



- ٦- يكتسب ملكة قياس الفروع على الأصول.
- ٧- يوضح عقد التوريد وصوره وموضوعه.
- ٨- يقارن بين عقد التوريد وبين غيره من عقود المعاملات.
- ٩- يشرح عقود المناقصات واجراءاتها.
- ١٠- يستنبط الحكم الشرعي لعقود المناقصات.
- ١١- يكتسب الطالب القدرة على التعاون مع المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية في مجال المعاملات المالية في الداخل والخارج.

أساليب التعليم والتعلم:

- ١- الإلقاء والمحاضرة.
- ٢- المناقشة والحوار.
- ٣- العصف الذهني
- ٤- المخططات والخرائط.
- ٥- التكيلفات من المصادر الالكترونية.
- ٦- تدريب مجموعات من الطلاب يقومون بتحضير الدروس، وشرحها أمام زملائهم.





الموضوع الأول: البطاقات الائتمانية

ويحتوي على أربع وحدات:



مقدمة:

تعد بطاقات الائتمان من أهم التطبيقات والخدمات المصرفية في السنوات الأخيرة، وقد انتشر استخدامها في جميع أنحاء العالم، وأضحت من وسائل الدفع المعاصرة في التعاملات التجارية والاستهلاكية، ولذا كان من الضروري دارستها من عدة جوانب.

وهذا الموضوع يلقي الضوء على أحكام هذه البطاقة الائتمانية من خلال التعريف بها وبيان أنواعها وتكييفها الشرعي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي، مع اقتراح بدائل شرعية لبطاقة ائتمان تتوافق مع مبادئ وقواعد الشرع الإسلامي.





الوحدة الأولى:

ماهية البطاقات الائتمانية ومنافعها

✍ المعلومات والمفاهيم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - يعرف بطاقات الائتمان والجهات المصدرة لها وأنواعها.
- ٢ - يصور الأشكال التي ترد عليها بطاقات الائتمان.
- ٣ - يستخلص أثر التعامل ببطاقات الائتمان على المجتمع والاقتصاد.





تعرفف بطاقة الائتمان^(١):

أ- مفردات العنوان:

البطاقة في اللغة: البطاقة: الورقة وهي رُقعة صغيرة يُثبَّتُ فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عيناً فوزُّنه أو عدده وإن كان متاعاً فقيمته^(٢).

الائتمان: في اللغة مأخوذ من الأمان وهو ضد الخوف^(٣).

وفي الاصطلاح الاقتصادي: منح دائن لمدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين^(٤).

(١) ويرى بعض الباحثين أن التسمية هذه ليست دقيقة، يقول د. عبد الوهاب أبو سليمان (بطاقات الائتمان) عنوان غير صحيح وقال: "جرت عادة الاقتصاديين والمصرفيين تقديم هذا النوع من البطاقات بعنوان (البطاقات الائتمانية) سواء في البحوث العلمية، والإعلانات المصرفية، وهي في نظر هؤلاء ترجمة لكلمة: (Credit Cards) في اللغة الإنجليزية، لدئ الرجوع إلى معنى هذه الكلمة (Credit) في المعجم الإنجليزي أجد أن لها عدة معان: تطلق غالباً على شرف الشخص، واعتزازه، وانتمائه، الاعتراف بكفاءته سمعته الطيبة، الدرجة العلمية مرتفعة النسبة على درجة النجاح في الامتحان. والعنوان السليم المناسب لهذا النوع من البطاقات هو: (بطاقات الإقراض)؛ إذ هو الوصف المناسب الدال على حقيقتها وماهيتها، المميز لها عن نظيراتها من البطاقات الأخرى " مجلة المجمع ع ١٢.

(٢) لسان العرب مادة بطق.

(٣) لسان العرب مادة أمن.

(٤) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص ١٢.



ب- تعريف بطاقات الائتمان: باعتبارها مركب إضافي:

في الاصطلاح الفقهي: عرفها علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدّر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدّر^(١).

وفي الاصطلاح الاقتصادي: بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع، أو الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري لطرفه^(٢).

التعريف المختار:

تعريف البطاقة في الاصطلاح الفقهي وذلك: لأن هذا التعريف يشمل جميع أنواع البطاقات المصرفية،

ويظهر من خلال ذلك أن بطاقات الائتمان ليست نقوداً في حد ذاتها، بل هي وسيلة متطورة من وسائل الدفع المتعددة التي تقوم في مجملها عن النقود.



(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه بقراره رقم (٦٥ / ١ / ٧) في ٧-١٢ / ١١ / ١٤١٢ هـ.

(٢) معجم المصطلحات التجارية والتعاونية، د. أحمد زكي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، - بيروت، عام ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م، ص ٦٢.



نبذة تاريخية عن البطاقة الائتمانية والجهات المصدرة لها:

أ- ظهرت الحاجة لبطاقة الائتمان في مطلع القرن العشرين في أمريكا عندما أصدرت بعض شركات البترول الأمريكية بطاقات لعملائها لشراء ما يحتاجونه، على أن يتم تسوية هذه المشتريات من قبل العملاء في نهاية كل مدة متفق عليها؛ وأول من أصدر تلك البطاقات هو بنك ناشيونال فرانكلين عام ١٩٥٢ م ثم تبعه البنك الأمريكي عام ١٩٥٨ م، ثم ظهرت بطاقة الأمريكان إكسبريس عام ١٩٥٨ م، لتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الفنادق والشركات مع ضمان استرداد ما تقوم بدفعه، ثم ظهرت فكرة (بطاقة الائتمان) في عام ١٩٧٠ م ونشطت نشاطا كبيرا؛ ثم تأسست جمعية بنكية بإصدار بطاقة منافسة لها، ثم تكونت جمعية تعاونية فأصدرت البنوك بواسطتها (بطاقة فيزا)^(١).

ب- الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان:

يتولى إصدار البطاقات العالمية على اختلاف أنواعها جهتان هما: "أمريكان إكسبريس؛ وفيزا" ويطلق عليهما البنكيون اسم (راعي البطاقة)^(٢).

أنواع البطاقات المصرفية:

تتنوع بطاقات الائتمان من حيث الرصيد الذي ترتبط به وشكلها إلى ما يلي:

(١) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، د. بكر أبو زيد ص ٢٠ - ٢٢.

(٢) بطاقات المعاملات المالية، د. عبد الوهاب أبو سليمان، مجلة المجمع ع ١٠.





أ-: البطاقات المصرفية من حيث الرصيد الذي ترتبط به:

تتنوع البطاقات المصرفية من حيث الرصيد الذي ترتبط به إلى نوعين:

النوع الأول:

البطاقات المرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد وهي الأكثر من حيث التعامل والانتشار وتسمى (بطاقات الحساب الجاري)^(١)، وحامل هذه البطاقة لا يستفيد إلا من مبالغه المودعة في البنك^(٢)، ولا تعد هذه البطاقة بطاقة ائتمان، وليست المقصودة عند الحديث عن بطاقات الائتمان.

النوع الثاني: بطاقات الائتمان:

تنقسم إلى أقسام متعددة؛ فقد تقسم بحسب مزاياها، أو بحسب مادة تصنيعها، أو بحسب الجهة المصدرة لها، أو بحسب وجود الغطاء لها من عدمه، أو بحسب نوع العلاقة بين أطرافها،^(٣) وهذا الأخير هو التقسيم المؤثر في تصوير المسألة، وتكييفها، كما أن وجود الغطاء وعدمه مؤثر كذلك في الحكم، وبقية التقسيمات لا يتعلق بها حكم.

(١) ويقصد ببطاقات الحساب الجاري أنها: أداة دفع وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري، تمكن حاملها من الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً. وهذه البطاقة التي أصدرتها الدوائر الحكومية ويستعملها في الوقت الحالي موظفي الدولة، وأصحاب المعاشات في قبض الراتب الشهري.

(٢) البطاقات الائتمانية أ. د/ محمد محروس، مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في الهند في دورته الخامسة عشرة، مدينة [سري نكار] عاصمة مقاطعة كشمير الهندية ١٤٢٦ هـ ص ٤.

(٣) الجوانب الشرعية والمصرفية لبطاقات الائتمان د. محمد عبد الحليم، ص (١٧-٢٤) بطاقة الائتمان،

طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري



ب: البطاقات المصرفية من حيث الشكل ووصفها:

تصدر البطاقة المصرفية على عدة أشكال منها: العادية، والبطاقة الذهبية، والبطاقة البلاطينية، ولا فرق بين هذه الثلاث في آلية الإصدار والاستخدام، غير أن بعضها يتمتع صاحبها ببعض المزايا الإضافية، مثل التأمين ضد الحوادث، والحصول على تأمين طبي في السفر، و ضمانات خاصة على البضائع المشتراة بها، إلى جانب توفير مزيد في الحد الائتماني للشراء^(١).

ج- وصف بطاقة الائتمان:

هي عبارة عن قطعة من البلاستيك مستطيلة الشكل، مقاساتها طبقاً للقواعد الدولية كالتالي: (٨.٥٧٢) سم للطول، و(٥.٤٠٣) سم للعرض، سُمكها ٨.٠٠ مم). ولها خصائص طبيعية منها: عدم قابليتها للاشتعال، ومُقاومة للمواد السامة والمنتجات الكيماوية.

والبطاقة ذات وجهين:

على الوجه الأول: اسم الجهة المصدرة، وعلامتها، واسم حامل البطاقة، ولقبه، وتاريخ إصدار البطاقة، ونهاية صلاحيتها، ورقم البطاقة الذي يشتمل على ثلاثة عشر رقماً، أو ستة عشر رقماً من اليسار إلى اليمين، وفي خلفها: تسجل البيانات المشفرة الخاصة بالحساب^(٢).

(١) بطاقات الائتمان، د. نزيه حماد، مجلة المجمع ١٢ / ١٣٤١.

(٢) <http://www.alukah.net>



منافع بطاقات الائتمان على أطراف البطاقة^(١): تقدم بطاقات الائتمان منافع لكل طرف من أطرافها، وبيان ذلك على النحو التالي.

أولاً: منافع بطاقات الائتمان لحامل البطاقة:

تقدم بطاقات الائتمان لحامل البطاقة منافع كثيرة ومنها:

- ١ - تزويد حامل البطاقة بتسهيلات نقدية له عند طلبه ذلك من أي عضو في المنظمة في أي دولة كان فيها.
- ٢ - استخدام أجهزة الصرف الآلي التابعة لأعضاء المنظمة، محلياً أو خارجياً، للحصول على مبالغ نقدية ضمن حدود تسهيلات.
- ٣ - تقدم تسهيلات لحامل البطاقة في إجراءات حجز الفنادق وتأجير السيارات والشراء البريدي بضمان البنك المصدر.
- ٤ - إمكانية استخدامها محلياً ودولياً دون الحاجة إلى حمل النقد أو تحويل العملات.

ثانياً: منافع بطاقات الائتمان للتاجر؛ تقدم بطاقات الائتمان للتاجر منافع

منها:

- ١ - جذب عملاء جدد.
- ٢ - توفير ميزة تنافسية للتاجر.

(١) بطاقات الائتمان، د. رفيق المصري، ٧٤، بحث بطاقات الائتمان المصرفية، بيت التمويل الكويتي، مركز تطوير الخدمة المصرفية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ٧٤.



٣- تخفف على التاجر مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في متجره وتقلل أثر مخاطر السرقة أو السطو المسلح.

٤- الاستفادة من الحملات الدعائية التي ينظمها مُصدِّرو البطاقة، وذلك بإدراج اسمه في الدليل الذي يوزعه المُصدِّر على حاملي البطاقة^(١).

ثالثاً: منافع بطاقات الائتمان للبنك المصدر للبطاقة

- ١- توظيف المصرف أمواله.
- ٢- ضم عدد كبير من الأفراد المستفيدين من البطاقة عملاء رئيسيين للمصرف يشجعون على التعامل معه، والاستفادة من خدماته.
- ٣- اضطرار حامليها والتجار فتح حساب لدى المصرف، وبالتالي الاستفادة من خدمات المصرف الأخرى.
- ٤- الانتشار العالمي وسمعة البنك في الخارج^(٢).

أثر التعامل ببطاقات الائتمان على اقتصاد الفرد والمجتمع:

نتج عن التعامل ببطاقات الائتمان آثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي على المجتمع والاقتصاد.

(١) بطاقات الائتمان، د. محمد علي القرني، مجلة المجمع، ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣.

(٢) بطاقات الائتمان، حقيقتها، حكمها د. نايف بن عمار.



فمن الإيجابيات:

أولاً: أن التعامل بالبطاقة يؤدي إلى توسع السوق وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات.

ثانياً: ساعدت البطاقة على توفير قدر أكبر من الأمان للأفراد لعدم تعرضهم للسرقة وضياع أموالهم.

ثالثاً: يؤدي التعامل ببطاقات الائتمان إلى زيادة حجم السيولة في الاقتصاد؛ لأنه يزيد من قدرة المؤسسات المالية (المصدرة للبطاقة) والبنوك على خلق الائتمان^(١). وكل المنافع التي سبق أن سردتها من قبل لأطراف البطاقة تعد من قبيل الإيجابيات.

أما السلبيات فمنها:

أولاً: الوقوع في مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة منح الائتمان لأشخاص غير مؤهلين ائتمانياً، وهذا له ضرر على المصارف وعلى الأفراد: أما ضرره على المصارف فإن مثل هذا يوقع البنوك في الديون المعدومة، وهذا له أضرار اقتصادية جمة، وأما ضرره على الأفراد فتتراكم الديون المالية على صاحب البطاقة، وفي حال تأخر عن سدادها تُفرض عليه غرامة مالية.

ثانياً: زيادة نسبة الفوائد المترتبة على القروض الخاصة بالبطاقة.

(١) بطاقات الائتمان، د. محمد علي القري، مجلة المجمع، ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣.



ثالثاً: إمكانية تزوير البطاقة واستخدامها استخداماً غير قانوني يوقع المصارف في تكاليف باهظة^(١).

رابعاً: أنَّ هذه البطاقات المنتشرة اليوم تُعتبر من أكبر الأسباب في توجيه الديون إلى الحاجات الاستهلاكية غير الإنتاجية، والتوسع فيها بسبب وجود هذه التسهيلات، بدلاً من صرفها على المجالات الاستثمارية المفيدة للاقتصاد والمجتمع.



(١) المعاملات المالية المعاصرة، ١٢/٦٢٧.



الوحدة الثانية:

أقسام بطاقات الائتمان وحكمها

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - يذكر حكم بطاقة الائتمان المغطاة.
- ٢ - يستنبط الدليل على حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية.
- ٣ - يفرق بين البطاقة المغطاة وغيرها.
- ٤ - يستنبط أثر الشروط الباطلة على عقد البطاقة الائتمانية.

أقسام بطاقات الائتمان باعتبار نوع العلاقة:

بين أطرافها وحكمها: البطاقات الائتمانية باعتبار نوع العلاقة بين أطرافها تنقسم إلى قسمين بطاقات ائتمان مغطاة: يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات، وبطاقات ائتمان غير مغطاة: أي لا يوجد رصيد يقابل استخدامها. وبيانها وحكمها على النحو التالي:

القسم الأول: بطاقات الائتمان المغطاة.

يَشترطُ مُصَدِّرُ البطاقةِ على حاملها أن يودع لديه مبلغاً من النقود في حساب مصرفي، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن قيمة المبلغ المودع^(١)؛ ومن أبرز خصائصها:

(١) بطاقات الائتمان د. علي القرعة عيد، مجلة المجمع، ٧/ ٢٩٥. فقه المعاملات المعاصرة د. سعد بن تركي الشخلان، ص ٢٧٣.



- (أ) تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
- (ب) توفر البطاقة لحاملها السحب النقدي، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الخصم منه فوراً.
- (ج) لا يتحمل العميل رسوماً - مالية - مقابل استخدامه هذه البطاقة، إلا في حال سحب العميل نقداً، أو شرائه عملة أخرى^(١).
- (د) تصدر هذه البطاقة برسم - مالي - أو بدونه^(٢).

والذي يبدو من خلال ذكر خصائص بطاقات الائتمان المغطاة أنها لا تدخل ضمن التعريف الأخص للبطاقات الائتمانية وإنما تدخل فيها من باب التغليب، إذ أن حامل البطاقة يتعامل مع حسابه الموجود في البنك سواء كان ذلك عن طريق الشراء أو السحب المباشر، وبالتالي فإن البطاقات المغطاة لا تمثل أي مديونية وهي تختلف عن البطاقات غير المغطاة والتي تقوم على الائتمان الممنوح للعميل والذي يمثل جوهر البطاقة.

حكمها:

أجاز العلماء المعاصرون^(٣) التعامل ببطاقات الائتمان المغطاة برصيد إذا لم يتضمن العقد شروط دفع الفائدة عند التأخر في السداد وذلك: لأن الأصل في

(١) وقد أدخلها بعض الباحثين ضمن البطاقة الائتمانية لأنها يؤخذ على السحب النقدي بها رسوم مالية.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد ١٢. الدورة السابعة. سنة ١٤١٢ هـ - ١٩٨٨ م. ج ١. ص ٧١٧

(٢) المعيار الشرعي رقم (٢) بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان،

<http://www.islamfeqh.com>

(٣) بطاقات الائتمان د. محمد علي، مجلة المجمع ع ١٢، بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، مجلة

المجمع ع ١٥/٣/٢١٩.



المعاملات الإباحة^(١) ما لم يحصل أي شرط، يترتب عليه فائدة ربوية.

(١) وإذا كان هذا القول مبني على أن الأصل في المعاملات الإباحة لا الحظر فأذكر خلاف الفقهاء في هذه المسألة وللفقهاء خلاف على قولين.

القول الأول: يرى من ذهب إليه أن الأصل في المعاملات الإباحة وهو قول جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واستدلوا على ذلك: الكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فمنه قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ المائدة، جزء آية: (١). وقوله سبحانه ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ الإسراء، جزء آية: (٣٤).

أما السنة فعن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)، أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب الرضاع ج ٥ - ص ٣٢٥ برقم ٤٣٩٦، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الضحايا - باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب ج ١٠ ص ٢١ برقم ١٩٧٢٥، وقال البيهقي هذا الحديث موقوف. ج ١٠ - ص ٢١.

أما المعقول: إن العقود هي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيها العفو، وعدم الحظر.

القول الثاني: يرى من ذهب إليه أن الأصل في المعاملات الحظر ذهب لذلك الظاهرية. وذلك بالكتاب والسنة أما الكتاب فقله - تعالى: - ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ سورة البقرة ٢٢٩. أما السنة فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ: - (ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق). أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب البيوع - باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل - ج ٢ ص ١٠٦ برقم (٢١٨٦)، ومسلم في كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق - ج ٢ - ص ١١٤١ برقم (١٥٠٤).

الراجح: والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأن الأصل في المعاملات الإباحة وذلك لما يلي لقوة ما استدلوا به من أدلة، وضعف دليل القول المخالف. ولأن الشريعة قائمة على رفع المشقة والحرج عن الأمة؛ قال ابن تيمية: (والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه). القواعد النورانية الفقهية



وقد صدر قرار رقم: ١٣٩ (٥ / ١٥) من مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من ١٤ إلى ١٩ المحرر ١٤٢٥ هـ، الموافق ٦-١١ آذار (مارس) ٢٠٠٤ م.

فبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وقرر ما يأتي:

(أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطه دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

(ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار ١٠٨ (٢ / ١٢) بشأن الرسوم، والخصم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

(ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

القسم الثاني: بطاقات الائتمان غير المغطاة

عرفها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها مستند يعطيه مُصدره (أي البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (وهو حامل البطاقة) بناءً

= لابن تيمية، مكتبة السنة المحمدية، ط ١، ١٣٧١هـ، ١٨٨ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٦، الذخيرة للقرافي ١/١٥٥، المحصول في علم الأصول ٦/٩٧، شرح الكوكب المنير ١/٣٢٥ المحلي ٨/٤١٤.



على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (وهو التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد الغير مدفوع بعد فترة محدده من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد^(١).

وتتنوع بطاقات الائتمان (غير المغطاة) تبعاً للأسلوب الذي يتم به تسديد دينها إلى:

أ- بطاقة الائتمان المحدد:

تسمى (بطاقة الدفع الشهري)، وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، بعد مضي فترة سماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً؛ فإذا استخدمها العميل في شراء سلعة بألف جنيه مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف جنيه طول فترة السماح.

خصائصها:

- (أ) البطاقة أداة ائتمان في حدود مبلغ معين.
- (ب) يلزم حاملها بالتسديد خلال مدة السماح.
- (ج) يلزم حاملها بمدفوعات أربعة: رسم الاشتراك، ورسم التجديد، وفوائد الإقراض، والتأخر.

(١) مجلة المجمع ١٢/ ٣/ ٦٧٥.



(د) في حال عدم السداد يطالب قضائياً، وتلغى عضويته وتسحب منه البطاقة^(١)

حكمها:

يحرم التعامل بها، لأنها تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين، ولكن يجوز قبولها وإصدارها إذا لم يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه، وبشرط ألا يتعامل بها فيما حرّمته الشريعة^(٢).

ب- بطاقات الائتمان المتجدد:

هذه البطاقة لها نفس خصائص ومميزات النوع الأول، إلا أنها تختلف عنها في أن الدين الناشئ عن الائتمان بها قابل للتجديد فعند السحب النقدي بهذه البطاقات: تجري على حامل البطاقة الفوائد الربوية بمجرد السحب، وإلى وقت السداد.

وعند الشراء بها: يُخير العميل بين أن يسدد الدين كاملاً في فترة السماح المجاني دون فوائد، أو يدفع جزءاً من المستحقات، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية تالية بفائدة مركبة عالية.. فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلع بخمسة آلاف جنيه، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهر ألف جنيه، أي يصبح المبلغ ستة آلاف جنيه.

(١) المعيار الشرعي رقم (٢) بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان،

<http://www.islamfeqh.com>

(٢) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع ع ١٠، د. عبد الوهاب أبو سليمان، بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ٦: ١١-٣-٢٠٠٤ م. مسقط (سلطنة عُمان)



ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا (فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.

ثانياً:- خصائصها:

- أ- تتقاضى البنوك رسوماً على إصدار هذه البطاقة وعلى التجديد.
- ب- عملاء بطاقة الائتمان المتجدد، يقدم لهم قرض بنكي، ولحامل البطاقة حق الاختيار في طريقة الدفع.
- ج- لا يوجد حد أعلى للمديونية، ويسمح لحاملها تأجيل السداد خلال فترة محددة، مع ترتيب فوائد عليه^(١).

حكمها:

لا خلاف بين العلماء المعاصرين^(٢) على تحريم التعامل بهذه البطاقة؛ لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي، إذ يتضمن عقدها زيادة الدين بزيادة الأجل، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية، فالعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة بين مقرض ومقرض^(٣).

وقد أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة معيار البطاقات الائتمانية في عام ٢٠٠٢م ورأت: أن بطاقة الائتمان المتجدد لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية إصدارها

(١) بطاقة الائتمان د. وهبة الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م مسقط (سلطنة عُمان)

(٢) مناقشات مجمع الفقه الإسلامي، بطاقات الائتمان غير المغطاة ع ١٢، بطاقات الائتمان، د. محمد الزحيلي، مجمع فقهاء الشريعة، المؤتمر السنوي الخامس، المنامة، البحرين ص ١٤.

(٣) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع ع ١٠، د. عبد الوهاب أبو سليمان، بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م، مسقط (سلطنة عُمان).



كون الدين المترتب على التعامل بها يسدد على أقساط آجلة بفوائد ربوية ويجوز إصدار بطاقة الائتمان لدين يتجدد بالشروط الآتية^(١):

(أ) ألا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

(ب) أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرّمته الشريعة، وأنه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.

كما أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٤ م قراراً بخصوص البطاقات غير المغطاة جاء فيه ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

(١) المعيار الشرعي رقم (٢) بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان،



ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠/٢) و١٣ (١/٣).

أثر الشروط الباطلة على صحة عقد بطاقة الائتمان:

بناء على الحكم الشرعي للتعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة ترد إشكالية وهي: يغلب على ظن الفرد قدرته على الوفاء في مدة السماح بحيث لا يزيد عليه الأجل ولا يزيد الدين. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم إجراء هذا العقد ولهم في ذلك قولان.

القول الأول: يجوز إجراء هذا العقد ذهب لذلك د. عبد الستار أبو غدة، د. عبد الوهاب أبو سليمان، الشيخ محمد تقي العثماني، الشيخ حسن الجواهري^(١).

القول الثاني: لا يجوز إجراء هذا العقد ذهب لذلك د. علي القري، د. عبد الرحمن عقيل، د. الصديق الضير، د. علي السالوس^(٢).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين العلماء المعاصرين إلى خلاف الفقهاء السابقين^(٣) في

(١) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، ع/١٢/٢، مناقشات المجمع ع ٨.

(٢) بطاقات الائتمان د. محمد علي القري، د. الصديق الضير مجلة المجمع، ع ١٠، ١٢، مناقشات المجمع ع ٨.

(٣) ذهب المالكية والشافعية إلى بطلان العقد وعدم صحته، وذهب الحنفية إلى تصحيح هذا العقد وإبطال الزيادة الربوية جاء في "الدر المختار": "القرض لا يتعلّق بالجائز من الشروط، فالفاسد منها =



اعتبار عقد الربا عقد باطل، أم عقد فاسد يمكن تصحيحه؟

فمن قال: إنه عقد باطل، حرم التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة؛ لأن العقود الباطلة لا يمكن تصحيحها، ومن قال أنه عقد فاسد، رأى جواز تصحيح العقد، وأجاز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة، ويصحح العقد بسداد حامل البطاقة المستحقات التي في ذمته في الوقت المسموح به للسداد، ولا يقع في الربا.

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

من السنة والقياس والمعقول:

أما السنة فمنها: عن عائشة رضي الله عنها في قصة عتق بريرة ^(١) قالت: قال رسول الله: "خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت ثم قام

= لا يبطئه" ووافقهم في ذلك الحنابلة في القرض جاء في شرح "منتهى الإرادات": "ولا يفسد القرض بفساد الشروط". شرح الدر المختار، مطبعة صبيح وأولاده، ج ٢، ص ٨٨، شرح منتهى الإرادات، ج ٣، ص ٢٢٧.

(١) مولاة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مولاة لبعض بني هلال فكتبوها، ثم باعوها من عائشة توفيت الصحابية الجليلة بريرة رضي الله عنها في زمن خلافة يزيد بن معاوية الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ١٧٩٥. وقصتها كما وردت في كتب السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءني بريرة فقالت: كاتب أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعيني. فقلت: إن أحبوا أن أعدّها لهم، ويكون ولاؤك لي، فعلت؟ فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء..... الحديث.



رسول الله ﷺ: فقال أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، فأیما شرط ليس في كتاب الله، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق^(١)

وجه الدلالة من هذا الحديث:

دل هذا الحديث على جواز إجراء عقد بطاقة الائتمان غير المغطاة بعد تصحيح الشرط، ما دام أن هذا الشرط فاسد، وحامل البطاقة يصح العقد بإسقاط هذا الشرط الفاسد، بدفع الدين في تاريخه بدون تأجيل، فقد أمر النبي ﷺ أن تدخل في عقد شرطه فاسد؛ لإمكانية إبطاله^(٢).

ويناقش وجه الاستدلال هذا: بأن ذلك غير مسلم:

فتصحیح العقد الذي يتضمن شرطاً باطلاً إنما يكون بطريقتين:

الأول: إسقاطه من قبل المشتري لا من قبل المشرط عليه؛ لأن إسقاط الشرط من قبل من اشترط عليه الشرط يؤدي إلى النزاع بينهما، إذ هو يفوت على الطرف الآخر منفعة مشروطة له، في عقد تحقق فيه الرضا بين الطرفين^(٣).

الثاني: أن الشرط الموجود في البطاقة شرط ملزم، لا يستطيع حامل البطاقة أن

(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل - ج ٣ - ص ٧٣ - برقم ٢١٦٨.

(٢) أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: "نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق" مناقشات مجمع الفقه الإسلامي ٨٤، ١٢٤.

(٣) بطاقات الائتمان، د. محمد علي القري، مجلة المجمع، العدد ١٢، مناقشات بطاقات الائتمان، د. عبد الرحمن عقيل مجلة المجمع ١٢٤.



يتخلّى عنه أو لا ينفذه، والقضاء يلزم بهذا الشرط^(١).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن المتعامل يمكنه إسقاط هذا الشرط إذا وثق من السداد في فترة السماح المجاني.

أما القياس: قياس إجراء عقد البطاقات الائتمانية غير المغطاة، على ما عمت به البلوى^(٢) من تضمن عقود الكهرباء والهاتف وغيرها غرامات مماثلة، بحيث إذا تخلف المشترك عن السداد تعرض لتطبيق هذه الغرامات عليه، ولم يقل أحد بحرمة الاشتراك في هذه المرافق نظرا لوجود هذه الشروط.

يقول د. محمد تقي العثماني: "نرى في كثير من المعاملات أن مثل هذه الغرامة يحملها رجل مسلم، والمعاملة في أصلها ليست ربوية، فقد رأيت في كثير من البلاد أن شركة الكهرباء - مثلا - تفرض على مستهلك الكهرباء أنه إذا لم يسدد فواتير الكهرباء في مدة محددة فإنه يحمل غرامة، فهل نستطيع أن نقول: إن شراء هذه الكهرباء بسبب هذا الشرط حرام؟ لا نستطيع أن نقول: إن الدخول في هذه العملية حرام من أجل أن شركة الكهرباء تفرض غرامة في صورة عدم التسديد، فكذلك هنا إذا فرضت الشركة المصدرة على حامل البطاقة أنه إن لم يسدد في خلال تلك المدة فإنه يفرض عليه غرامة، فبمجرد هذا الشرط لا يقال: إنها عملية محرمة لا يجوز الدخول فيها لمسلم، فإذا كان من نيتي وعزمي الصادق أني سوف أؤدي هذا المبلغ في خلال المدة، فإنه يحل لي شرعا أن أدخل هذه العملية، فإن العقد أصله ليس عقدا ربويا، وإنما جاءت الغرامة لعارض التأخير في السداد من غير أن يكون لحامل البطاقة أي خيار، فأظن أن هذا ليس مانعا شرعيا من الدخول في هذه المعاملة، ومن الحصول على هذه البطاقة".

(١) مناقشات المجمع لبطاقات الائتمان، د. على السالوس مجلة المجمع، ع ١٢٤.

(٢) البلوى: أي انتشر وشاع أمره بين الناس.

ويمكن أن يناقش: بأن قياس إجراء عقد البطاقات الائتمانية غير المغطاة، على عقود الكهرباء والهاتف قياس مع الفارق؛ لشدة الحاجة إلى هذه المرافق، أما البطاقات الائتمانية غير المغطاة الأمر فيها أدنى من ذلك^(١).

أما المعقول: إن عقد بطاقات الائتمان غير المغطاة ليس من العقود الباطلة، وإنما يعتبر من العقود الفاسدة، وإنما منع من أجل وصفه من حيث كونه ربا؛ لاشتماله على زيادة محرمة؛ فعلى هذا يسقط الربا ويصح العقد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا^(٢).

أدلة القول الثاني: من المعقول

الدليل من المعقول: - أن عقود بطاقات الائتمان غير المغطاة تؤول إلى المعاوضة، فإن فيها قرضاً أو وعداً بالقرض، والقرض وإن كان تبرعاً في الابتداء إلا أنه معاوضة في الانتهاء.

الراجع:

بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بجواز العقد لانتفاء الحرج عمن غلب على ظنه قدرته على الوفاء في مدة السماح، وذلك لرفع الحرج عمن احتاج إلى ذلك وأبطل الشرط الفاسد، وذلك بشرط اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يطبق عليه هذا الشرط.

هذا من حيث المستخدم، أما من جهة المشتري فإن اشتراطه فوائد التأخير حرام باتفاق، وهو من ربا الجاهلية، وهو ما يسمى بقاعدة: (زدي أنظر ك).

(١) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، ع ١٢.

(٢) الشيخ ديبان محمد الديان: <http://www.alukah.net>



الوحدة الثالثة:

أطراف بطاقات الائتمان والتكليف الفقهي لأطراف التعاقد

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - يذكر أطراف التعاقد في بطاقات الائتمان والتكليف الفقهي ..
- ٢ - يفهم العلاقة التعاقدية بين أطراف البطاقة الائتمانية.
- ٣ - يبين علاقة هذه النازلة بالمسائل الفقهية المدونة في كتب الفقهاء القدامى.





أطراف بطاقات الائتمان:

يتكون عقد بطاقات الائتمان من ثلاثة أطراف^(١):

الطرف الأول: وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر.

الطرف الثاني: حامل البطاقة، وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها.

الطرف الثالث: التاجر وهو مصطلح يُطلق على كل من المؤسسات، والشركات، والمصارف التي يتم تطبيق اتفاق معهم؛ من أجل تقديم الخدمات، وقبول عمليات البيع، وتوفير النقود بموجب بطاقة الائتمان^(٢).

الطرف الرابع: المنظمة العالمية: وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة، ومن أشهرها: منظمة فيزا، ومنظمة ماستر كارد، ومنظمة أمريكان إكسپريس.

التكليف الفقهي لأطراف التعاقد بالبطاقات الائتمانية:

تنحصر العلاقة بين أطراف التعاقد وبيان ذلك على النحو التالي:

(١) بطاقات الائتمان، د. رفيق المصري، ٣١٦/٧.

(٢) المرجع السابق، د. عبد الوهاب أبو سليمان ع ١٠، المعاملات المالية المعاصرة ٥٤٣/١٢.



التكييف الفقهي^(١) بين مصدر البطاقة وحاملها:

كما سبق أن أوضحنا أن من خصائص بطاقات الائتمان منح مصدر البطاقة حاملها مميزات مباحة^(٢) شرعاً.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها إلى عدة أقوال^(٣).

ويرجع سبب الخلاف بين العلماء إلى ما يلي:-

أولاً: عدم وقوف بعض العلماء إلى حقيقة النظام الذي تقوم عليه هذه البطاقات، وعدم تدقيقهم في العقود التي تحكم الأطراف المتعاملة بها....

ثانياً: إن العلاقة بين الأطراف الثلاثة في عقود بطاقة الائتمان علاقة معقدة.

ثالثاً: منهم من لا يخرج المعاملة على عقد مسمى^(٤)، ويكتفي بأن الأصل في

(١) ويعرف التكييف الفقهي بأنه تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة.

(٢) لا يجوز إعطاء امتيازات لحامل البطاقة تحرمها الشريعة الإسلامية، كالتأمين التجاري على الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً، كالخمرات والمراقص ودور اللهو الماجنة. بطاقات الائتمان دكتور وهبة مصطفى الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ٦-١١ / ٣ / ٢٠٠٤ م مسقط (سلطنة عُمان)

(٣) وقد حيرت هذه العلاقة رجال القانون الغربي في البلاد التي نشأت فيها البطاقة كما حيرت الفقهاء المسلمين. دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية: د. أسامة الأشقر ص ١٢٤

(٤) العقود تنقسم من حيث التسمية إلى قسمين: عقود مسماة: وهي العقود التي نص الشارع على تسميتها، وجعل لها أحكاماً خاصة كالبيع، والإجارة، والرهن،،،، وعقود غير مسماة: وهي العقود التي لم ينص الشارع على تسميتها، وإنما استحدثت تبعاً لحاجة الناس، ولم تكن موجودة زمن التشريع، كعقود التأمين، والإجارة المنتهية بالتمليك،. نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع - محمد سلامة ص ١٧.



المعاملات الحل، ومنهم من يخرج المعاملة على أنها عقد من العقود المسماة.

القول الأول: أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان^(١) ذهب لذلك د. نزيه كمال حماد، د. محمد القري، وهي قول للشيخ علي عندليب، والشيخ محمد علي التسخيري^(٢).

وجه كون العلاقة عقد ضمان: حيث ضمن مصدر البطاقة - حامل البطاقة - في سداد ما عليه للتاجر، وهذا من قبيل ضمان الحق قبل وجوبه؛ وهو جائز عند جمهور الفقهاء^(٣) ومنهم الحنفية، والمالكية، الشافعية في القول الأول والحنابلة^(٤) وذلك

(١) ويقصد بعقد الضمان: في اللغة يطلق على معان منها:

أ - الالتزام: تقول ضمننت المال، إذا التزمته.

ب - الكفالة: تقول: ضمننت الشيء ضمناً، فهو ضامن وضمين، إذا كفله.

ج - التغريم، تقول: ضمننت الشيء تضميناً، إذا غرمته القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة: (ضمن) وفي الاصطلاح: إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات، حكمة مشروعيتها: شرع الضمان، حفظاً للحقوق، ورعاية للعهود، وجبراً للأضرار، وزجراً للجناة، وحداً للاعتداء دليل مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿وَلَمَن جَاءَ بِهِ حُمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ سورة يوسف: ٧٢.

(٢) مجلة المجمع ١٢/٣.

(٣) وذهب الشافعي في الجدِيد والثوري، والليث، وابن أبي ليلى، إلى عدم صحة الكفالة بالدين المجهول وذلك لأن الكفالة التزام دين في الذمة، والتزام المجهول غرر ينهي عنه الشارع، فوجب أن يكون الدين معلوماً حتى يكون الكفيل على بينة من أمره، ومن قدرته على الوفاء بما التزم به. نهاية المحتاج: ٤/٤٢٥؛ أسنى المطالب: ٢/٢٣٨ المغني لابن قدامة: ٦/٧٣، الإنصاف للمرداوي: ٥/١٧٥

(٤) حاشية الشلبي على تبين الحقائق ٤/١٥٢؛ الفتاوى الهندية ٣/٢٥٦، مواهب الجليل ٥/٩٩، شرح منتهى الإرادات ٢/٢٤٨.



لأنَّ الضمانَ مِن قبيل التبرُّع، والتبرُّع يصحُّ مع الجهالة^(١).

ويناقش بأن ذلك غير مسلم من وجهين:

الوجه الأول: أن الضمان عقد تبرع محض، والجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية ليست صندوقاً خيرياً، وإنما تهدف الربح إما عن طريق الفائدة الربوية إذا لم يسدد حامل البطاقة التزاماته، وإما من التاجر حيث تأخذ منه نسبة معينة من المال المستحق له، وكل هذا مخالف للضمان في الشريعة الإسلامية.

الوجه الثاني: أن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة شرعاً، يستطيع فيها الدائن أن يطالب المكفول - حامل البطاقة - وأن يطالب الكفيل (مصدر البطاقة)، والدائن (التاجر) في هذه المعاملة لا يستطيع أن يطالب المضمون عنه - حامل البطاقة - وإنما يطالب الضامن^(٢).

وأجيب بما يلي:

- أ - أن الحنفية والمالكية^(٣) أجازوا^(٤) اشتراط براءة ذمة المضمون عنه.
- ب - أن الدَّين ينتقل إلى ذمة الضامن فالضمان يبرئ المضمون عنه^{(٥)(٦)}؛

(١) بطاقات الائتمان غير المغطاة د. نزيه حماد، مجلة المجمع العدد ١٢.

(٢) بطاقات الائتمان د. محمد الضير، مجلة المجمع ١٢ / ١٤٣٢.

(٣) فتح القدير ٨ / ١٨٢، والشرح الصغير للدردير ٣ / ٤٣.

(٤) خالف في ذلك الشافعية والحنابلة. تحفة المحتاج ٥ / ٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٤٦.

(٥) فتح القدير ٦ / ٢٨٤؛ الحاوي للماوردي ٨ / ١١٢؛ المغني ٦ / ٨٤، المحلى ٨ / ١١٣.

(٦) بطاقات الائتمان غير المغطاة د. نزيه حماد، مجلة المجمع العدد ١٢.



وذلك استدلالاً بالسنة والمعقول.

أما السنة فمنها:

١- عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الزعيم غارم)^(١) (٢).

وجه الدلالة من هذا الحديث: خص النبي ﷺ الضامن بالغرم، فاقتضى ذلك أن يكون المضمون عنه بريئاً من الغرم.

٢- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فلما وضعت، قال: "هل على صاحبكم من دين؟" قالوا: نعم، عليه ديناران. فعدل رسول الله ﷺ عنه وقال: "صلوا على صاحبكم". فقال علي رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فتقدم النبي ﷺ فصلى عليه، ثم قال لعلي: "جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك". فقيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل للمسلمين عامة"^(٣).

وجه الدلالة من هذا الحديث: دل هذا الحديث على براءة ذمة المضمون عنه بالضامن وذلك من وجهين:-

(١) الزعيم: الكفيل. غارم: أي ضامن.

(٢) جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه - كتاب البيوع - باب ما جاء في العارية مؤداة ج ٣- ص ٥٥٧- برقم ١٢٦٥. قال أبو عيسى: وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب.

(٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الضمان - باب وجوب الحق بالضمان - ج ٦- ص ١٢١- برقم ١١٣٩٨، وفي إسناده ضعفاء. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ٧١١/٦.

أحدهما: أن النبي ﷺ بعد أن امتنع من الصلاة عليه صلى عليه، فذل ذلك على براءة ذمته.

ثانيهما: دل قوله ﷺ (فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك) على براءة المضمون عنه..

أما المعقول:

فإن أهل الاختصاص لا ينفون حق التاجر في مطالبة حامل البطاقة^(١).

القول الثاني: العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة حوالة^(٢) أي: أن حامل البطاقة يحيل التاجر على مصدرها ذهب لذلك جمع من العلماء المعاصرين منهم د. الصديق محمد الأمين الضرير، د. وهبة الزحيلي وهو قول للشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري، د. رفيق المصري، والشيخ عبد الله بن منيع^(٣).

(١) يقول أحد الباحثين: "لم أجد في العقود المنظمة للبطاقات ما ينص على أنه ليس للقبال أن يطالب حاملها؛ ولذا اختلف القانونيون في هذه المسألة"، وعليه فليس ثمة إشكال أصلاً. بطاقات الائتمان، د. على القرى مجلة المجمع ع ١٢ ج ٣ ص ٥٤١.

(٢) الحوالة في اللغة: من حال الشيء حولا وحوّولا: تحول. وتحول من مكانه انتقل عنه وحولته تحويلا نقلته من موضع إلى موضع. لسان العرب مادة حول. المصباح المنير مادة حول.

في الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. مغني المحتاج ١٩٣/٢. الدليل على مشروعيتها: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء - ج ٥ - ص ٣٤ - برقم ٤٠٨٥. وقد حكى ابن قدامة الإجماع على جوازها فقال: وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة.

(٣) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط، سلطنة عمان ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م، بطاقات الائتمان غير المغطاة، الشيخ محمد علي



وجه هذا القول: أن حامل البطاقة هو المحيل، والتاجر هو المحال، ومصدر البطاقة هو المحال عليه.

وبيان ذلك: أن يحيل حامل البطاقة التاجر بدينه على مصدر البطاقة، ويقبل المحال عليه أداء الحوالة، وإذا كانت العلاقة من قبيل الحوالة، فالحوالة جائزة وتعد من قبيل الحوالة بأجر.

ويناقش: أن هذا القول غير مسلم من وجهين^(١):

الوجه الأول: أن عقد البطاقة ليس فيها ما يشير إلى عقد الحوالة، والاتفاقيات تعقد بشكل منفصل بين حامل البطاقة والبنك المصدر لها من جهة، ثم بين التاجر ومصدر البطاقة من جهة ثانية.

الوجه الثاني: بأنه لا دين للمحيل (حامل البطاقة) على المحال عليه (البنك)، ومن شروط الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال^(٢) ولو بدين حوالة سابقة^(٣)، ولو كانت حوالة من شخص ليس مديناً، لصارت حوالة على مقرض، وهذا غير

= تسخير مجلة المجمع العدد ١٢.

(١) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، د. محمد علي القرني، العدد ١٢.

(٢) قال الخرشي في سياق الحديث عن الحوالة: (ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور). شرح الخرشي علي مختصر خليل ١٧/٦.

(٣) اختلف الفقهاء في صحة الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل ولهم في ذلك قولان: القول الأول: الحوالة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الأول للشافعية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، القول الثاني: أن هذا من قبيل الضمان، وليس من الحوالة في شيء، ولو استعمل لفظها، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنَّ المحال عليه احتمل سداد الدَّين عن المُحيل، وهذا هو الرَّاجح. بدائع الصنائع ١٦/٦، شرح الخرشي علي خليل ١٧/٦، مغني المحتاج ١٢٤/٢، المغني ٥/٥٧.



جائز، لأن فيه شبهة الربا^(١).

وأجيب عن ذلك: بأن الحوالة لا يشترط فيها أن يكون المحيل مدينا للمحال عند الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء؛ فتكون الحوالة داخلة في عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَطْلٌ»^(٢) الْغَنَى ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»^{(٣)(٤)}.

الثالث: القول بأن العقد عقد حوالة يتعارض مع أخذ مصدر البطاقة من حاملها أجرا على الخدمات، فإذا أخذ مصدر البطاقة رسوم من حامل البطاقة؛ فيكون أخذ زائدا عن حقه وهذا يخل بشروط الحوالة^(٥).

القول الثالث: للبطاقة حالان: حال قبل استخدامها من قبل حاملها وهي في هذه الحالة تكون كفالة، وبعد استخدامها تنقلب إلى حوالة وهو قول د. عبد الستار أبو غدة^(٦).

(١) بطاقات الائتمان، د. رفيق المصري مجلة المجمع العدد ٧.

(٢) المطل: التأخير؛ أي: تأخير الغني الواجد للمال قضاء ما عليه من الدين.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاستقراض - باب مطل الغني ظلم - ج ٥ - ص ٥٧ - برقم ٢٤٠٠، ومسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغني - ج ٥ - ص ٣٤ - برقم ٤٠٨.

(٤) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط، سلطنة عمان ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م

(٥) قال ابن قدامة: (ومن شرط صحة الحوالة شروط ثلاثة. أحدها: تماثل الحقيين في أمور ثلاثة: الجنس فيحل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة،، الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر، وإن أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة بل هي وكالة، وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا نص عليه أحمد فلا يلزم المحال عليه الأداء ولا المحتال قبول ذلك لأن الحوالة معاوضة ولا معاوضة هاهنا وإنما هو اقتراض لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، الشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم..). المغني لابن قدامة ٥/ ٥٥.

(٦) بطاقات الاعتماد، مجلة المجمع، ع ١٢.

وجه هذا القول: أن المصرف يتكفل تجاه التجار ومقدمي الخدمات بأداء ما في ذمة حامل البطاقة، وبعد قيام حامل البطاقة باستخدام البطاقة ينشأ دين للتاجر (المحال) لدى حامل البطاقة (المحيل) فتتحول العلاقة بين أطراف البطاقة من كفالة إلى حوالة.

ويمكن أن يناقش: بأن الكفالة لا تكون إلا بدين ثابت، وقبل استخدام البطاقة لم يثبت دين في ذمة حاملها، وأما بعد الاستخدام فالقابل لها لا يطالب حاملها، وإنما يطالب المصدر وهذا معنى الائتمان^(١).

القول الرابع: أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة وكالة^(٢).

وهو قول الشيخ علي عندليب، والشيخ محمد علي التسخيري^(٣).

(١) بطاقات الائتمانية، د. صالح بن محمد الفوزان، موقع صيد الفوائد.

(٢) الوكالة: في اللغة: الحفظ. وفي الاصطلاح: إقامة الغير مقام نفسه - ترفها أو عجزا - في تصرف جائز معلوم. الدليل على مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فمنه قول الله سبحانه: ﴿فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَورِقْكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١٩]

أما السنة فمنها: عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه". أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية، فأراه انشقاق القمر - ج ٤ - ص ٢٠٧ - برقم ٣٦٤٢

أما الإجماع: قد حكى الإجماع ابن قدامة وقال: أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين وأما المعقول: أن الحاجة داعية إلى مشروعية الوكالة، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه فدعت الحاجة إليها. حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٠٠ المغني ٥/ ٨٧، الإجماع لابن المنذر ٢/ ٧٠.



وجه هذا القول: أن حامل البطاقة وكل (مصدر البطاقة) أن يسدد عنه، ثم يقضيه، ويعتبر هذا التوكيل توكيلاً مطلقاً^(٢)^(٣).

ويمكن أن يناقش هذا القول من أوجه:

الأول: أن العلاقة في الوكالة بين طرفين هي الموكل والوكيل، أما في البطاقة فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف حامل البطاقة، والتاجر، والمصدر.

الثاني: يجوز في الوكالة مطالبة كلا من الموكل والوكيل بالدين، وفي دين البطاقة لا تجوز مطالبة الموكل، بل يطالب الوكيل فقط^(٤).

القول الخامس: أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة وكالة، وحوالة، وكفالة، وقرض حسن وهو قول بعض العلماء المعاصرين^(٥).

وجه هذا القول:

أن البطاقة تقوم أساساً على الحوالة مع جزء من الوكالة، وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها، كما أنها تصبح قرضاً حسناً بالنسبة للبنوك الإسلامية.

(١) بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه ع ١٢.

(٢) بطاقات الائتمان، د. عبد الوهاب أبو سليمان، مجلة مجمع الفقه ع ١٠.

(٣) فيصبح مصدر البطاقة وكيلاً عن حامل البطاقة في تسديد قيمة مشترياته مجلة المجمع، بطاقات المعاملات المالية ع ١٠.

(٤) بطاقات الائتمان، الشيخ الصديق الضير، مجلة مجمع الفقه، ع ١٠.

(٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، العدد السابع، عام ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م، ج ١، ص ٦٥٧ - ٦٥٩.



ويناقدش:

سلمنا القول بأن هذا العقد يتضمن الوكالة والضمان، أما عقد الحوالة فإنه لا يسلم؛ لأن عقد الحوالة يتضمن شروط خاصة، غير موجودة في بطاقة الائتمان^(١).

القول السادس: العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة إقراض فهي قرض ربوي بفوائد معجلة ومؤجلة وهو قول د. بكر أبو زيد^(٢).

وجه هذا القول: أن مصدر البطاقة يوفر لحاملها التصرف في حدود مبلغ يحدده له، ثم يأخذ زيادة على المبلغ المحدد، فهو قرض بزيادة، والزيادة ربا^(٣).

ويمكن أن يناقدش من أوجه:

الأول: أن حقيقة القرض: هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، بينما عقد الائتمان قد يوجد ولا يوجد القرض^(٤).

الثاني: القول بأن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة بين مقرض ومقترض، يقتضي هذا أن مصدر البطاقة لا يكون مسئولاً ولا ضامناً للبضاعة المعيبة التي يشتريها حامل البطاقة من التاجر^(٥).

(١) بطاقات المعاملات د. عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ع ١٠.

(٢) بطاقة الائتمان د. بكر أبو زيد، ص ٢.

(٣) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط، سلطنة عمان ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م

(٤) تكييف بطاقات الائتمان، د. ديان محمد الديان، المقال العاشر، القصيم، العدد ١٣٠،

رمضان ١٤٢٩.

(٥) بطاقات المعاملات المالية ص ٥٦.



الثالث: أن القرض من عقود الإرفاق والبنوك ليست محلاً لمثل ذلك، بل تهدف جميع البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقة الائتمانية الحصول على أرباح^(١).

القول السابع: أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها معاملة مستجدة تدرج تحت مسمى (العقود غير المسماة) وهو قول بعض العلماء المعاصرين^(٢).

وجه هذا القول: أن عقد البطاقة الائتمانية عقد جديد على الفقه الإسلامي، لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد من عقود المعاملات الشرعية المعروفة، ولا يصح تكييفه في صورته الكلية بعقد واحد، حوالة، أو جعالة، أو ضمان، أو وكالة، أو عقدين معاً: كالوكالة والكفالة، أو الوكالة والجعالة^(٣).

القول الرابع:

والله أعلم - هو القول الذي يرى أصحابه أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة مستجدة تدرج تحت العقود غير المسماة، والعقود الأصل فيها المشروعة إن لم يوجد فيها مخالفات شرعية؛ وذلك لأن هذا العقد إذا اندرج تحت عقد من جانب تخلف من جانب آخر. والعقود الجديدة تكون مشروعة ما لم تعثرها مخالفات شرعية.

(١) تكييف بطاقات الائتمان، د. ديبان محمد الديبان، المقال العاشر، القصيم، العدد ١٣٠، رمضان ١٤٢٩.

(٢) المرجع السابق.

(٣) البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، عبد الرحمن الحجي ص ١٤٩.



يقول د. أسامة الأشقر: ((إن التكييفات الفقهية التي كيف بها الفقهاء العلاقة التي تقوم بين الأطراف المتعاملة في البطاقة لم تسر على منهج سواء، ولم تنتج حكماً شرعياً واضحاً، وإن كلاً منها ضاق أن يتسع لهذا النوع من التعاملات كما يضيق الثوب عن أن يتسع للابس. والسبب في ذلك إن الذين صنعوا هذه البطاقات لم يقيموها على هذه العقود التي أجهد الفقهاء أنفسهم بتكييف العلاقة بها، والتكييف الذي كيف الفقهاء به عقد البطاقة هو تكييف تصوري أو اعتباري، وليس بتكييف حقيقي واقعي؛ والطريقة المرضية لدي في الوصول إلى الحكم الشرعي هو النظر إلى عقد البطاقة على أنه عقد جديد مستحدث، ومثل هذه العقود تكون مشروعة إن لم يوجد فيها مخالفات شرعية تمنعها^(١).

التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر :

اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر ولهم ستة أقوال.

القول الأول: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر هي علاقة كفالة مقترنة بالحوالة^(٢).

وجه هذا القول: أن الغرض من اشتراط الكفالة مع أن الحوالة وحدها توصل التاجر إلى حقه - هي استمرار التزام مصدر البطاقة بالأداء للتاجر، دون الرجوع على المحيل (حامل البطاقة) في حالة (الإفلاس).

(١) دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية: ص ٤٢.

(٢) بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة مجلة المجمع، العدد ١٢.

القول الثاني: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر: وكالة بأجر^{(١)(٢)}.

وجه هذا القول: أن البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للتاجر في قبض استحقاقات قيمة المبيعات من حامل البطاقة، والوكالة بأجر؛ وبغير أجر جائزة^(٣).

فإن قيل: أن ذلك من قبيل "ضع وتعجل"^(٤).

(١) والوكالة بأجر لها حكم الإجازات، وبغير أجر هي معروف من الوكيل.
(٢) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط، سلطنة عمان ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م.

(٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٩٧، الحاوي ٨/ ٢٥٥، المغني ٥/ ٢١١.

(٤) مسألة (ضع وتعجل) وهي أن يُصَالِحَ عَنِ الدِّينِ الْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالاً وفيها خلاف بين الفقهاء على قولين القول الأول: يرى تحريم التعامل بها وإليه ذهب الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الأولى وذلك استدلالاً بحديث المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلاً مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له: عجل تسعين ديناراً، وأحط عشرة دنائير، فقال: نعم، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ((أكلت ربا يا مقداد، وأطعمته)) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب البيوع - باب لا خير في أن يجعله بشرط - ج ٦ - ص ٢٨ - برقم ١١٤٧١، هذا الحديث ضعيف. وجه الدلالة: سمى رسول الله ﷺ هذه المعاملة ربا، والربا هنا ربا النسيئة ولا خلاف في تحريمه. ومن الأثر: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعْ لَكَ، فَهَنَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: «نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالْأَجَلِ». مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب البيوع - باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل - ج ٨ - ص ٧٢ - برقم ١٤٣٥٩؛ وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢ / ١٢). كما استدلووا بالمعقول ومنه: أن الحطيطة في الدين المؤجل عوض عن التأجيل وهو لا يجوز، فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادة الأجل مقابلة زيادة العوض.

القول الثاني: يرى من ذهب إليه جواز الوضع والتعجل وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشوكاني، وقد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة، فقد نص على ما يلي: (الحطيطة من الدين المؤجل لأجل

أجيب: بأن القول بأن هذه العلاقة من قبيل (ضع وتعجل) غير مسلم؛ لأن تسديد البنك المصدر للبطاقة فوري، عند تسليم سندات البيع الصحيحة من التاجر.

القول الثالث: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة حوالة فالبنك محال عليه والتاجر محال، وحامل البطاقة محيل^(١).

وجه هذا القول: أن حامل البطاقة عندما يشتري سلعة يتعلق بذمته قيمتها للتاجر، فالتاجر دائماً له بذلك المبلغ فيحيله على مصدر البطاقة.

ويمكن أن يناقش: بأن أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقاً، سواء كانت الحوالة من قبيل بيع الدين بالدين، أو من قبيل استيفاء الحق وليست بيعاً.

القول الرابع: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة سمسرة^(٢) وقال بهذا التخريج الدكتور رفيق المصري، د. وهبة الزحيلي، د. محمد تقي العثماني، د.

= تجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية). وذلك استدلالاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمر النبي ﷺ بإخراج بني النضير من المدينة، وفيه قوله ﷺ: ضعوا وتعجلوا". رواه الحاكم في المستدرک - كتاب البيوع - ج ٢ - ص ٦١ - برقم ٢٣٢٥، والدارقطني في سننه ج ٣ - ص ٤٦٥ - برقم ٢٩٨٠، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى - ج ٦ - ص ٤٦، ومن أراد المزيد فليراجع: تكملة فتح القدير ٣٩٧/٧ المدونة ١٧٣/٩، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١٦٥/٢، مغني المحتاج ١٢٩/٢، المغني ١٧٤/٤، كشاف القناع ٣/٣٤٢، الاختيارات الفقهية ص ١٣٤، إغاثة اللهفان ١٢/٢.

(١) الضوابط الشرعية في البطاقات الائتمانية الشيخ محمد الباشا، بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط، سلطنة عمان ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م (٢) السمسار: هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر. حاشية ابن عابدين ٥/٥٦٥.



عبد الستار أبو غدة، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين^(١)

وجه ذلك: أن المُصدِر يرسل حاملي البطاقات إلى التاجر على أن يتقاضى منه أجراً عن مشتريات كل حامل للبطاقة يشتري من التاجر بالبطاقة الائتمانية، كما أنه يوفر بعض الخدمات للتاجر مثل تحصيل فواتير الشراء، وخدمة الإيداع المباشر في الحساب، ونحو ذلك.

القول الخامس: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة الكفالة والوكالة:

وجه ذلك: أن الجهة المصدرة للبطاقة تعد ضامن للتاجر للوفاء بمستحقاته من قبل حامل البطاقة، كما أن تحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعها في حسابه.

القول السادس: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة مستدة الأصل فيها الإباحة وهو قو د. أسامة الأشقر.

الراجع: القول السادس^(٢).



(١) بطاقات الائتمان لرفيق المصري مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٧ / ١ / ٤١٠، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين نص المعيار ٢٨.

(٢) يراجع الترجيح في العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها.



التكييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:

اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر ولهم في ذلك قولان.

القول الأول: العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر لا تخرج عن عقدين فإما أن تكون علاقة بيع أو علاقة إجارة^(١).

وجه هذا القول: أن العقد إن كان عقد تمليك فهو عقد بيع، وإن كان من قبل تقديم خدمات معلومة فهو عقد إجارة، ويحيل حامل البطاقة التاجر على مُصدر البطاقة لاستيفاء الثمن أو الأجرة.

القول الثاني: العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر هي علاقة شبيهة بخصم الأوراق التجارية^(٢).

وجه هذا القول: أن الفاتورة التي وقّع عليها حامل البطاقة هي بمثابة كمبيالة مستحقة الدفع، يقوم التاجر بخصمها لدى البنك "المصدر للبطاقة" مقابل نسبة معلومة^(٣).

(١) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط، سلطنة عمان ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م. بطاقات الائتمان غير المغطاة د. نزيه حماد، مجلة المجمع العدد ١٢.

(٢) يقصد بخصم الأوراق التجارية أنها عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى المصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف لصرف قيمتها له بعد خصم مبلغ معين نظير ذلك التعجيل. حكم التعامل المصرفي بالمعاصر بالفوائد، د. علي أحمد السالوس، مجلة المجمع ٢.

(٣) الضوابط الشرعية في البطاقات الائتمانية الشيخ محمد الباشا، عضو الاتحاد العالمي لعلماء



القول الراجح: يبدو لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الأول فإن كان العقد عقد تمليك للسلع فهو من عقود البيع، أو كان من قبيل تقديم خدمات معلومة فهو من عقود الإجارة، ويشترط لصحة البيع والإجارة اكتمال شروطهما وانتفاء موانعهما.

العلاقة بين المنظمة الراعية^(١) وأطراف البطاقة.

تغطي المنظمة العالمية مصاريفها من خلال:

- إيرادات الاشتراك (العضوية) للأعضاء.
- الإيرادات ربع السنوية.
- ثمن بعض البرامج التي تقدمها المنظمة.
- الرسوم على بعض الخدمات.

تخريج العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة.

العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة علاقة (سمسرة) وبه قال د. عبد الستار أبو غدة، د. وهبة الزحيلي، والشيخ ديان محمد الديان^(٢).

= المسلمین:

<http://mohamedelbasha.blogspot.com>

(١) منظمة " الفيزا " هي عبارة عن ناد يضم في عضويته جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء والتي تلتزم باللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه المنظمة مع عدم التعارض مع النظام الداخلي للعضو المشترك في هذه المنظمة. التكيف الشرعي لبعض الجوانب الإجرائية لبطاقة فيزا التمويل، مجلة المجمع ع٧.

(٢) بطاقات الائتمان تصورها... د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع ع١٢ / ٢ / ٤٨٦، د. وهبة مجلة =



ووجه ذلك: أن المنظمة هي صاحبة الحق المعنوي في البطاقة (الترخيص أو الامتياز). وتنشئ المنظمة علاقة بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تصدر البطاقة، حيث تزود المنظمة تلك البنوك بالخبرة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقة.





الوحدة الرابعة: الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة أن يكون / تكون قادرا على:

- ١ - يصور كيفية شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان.
- ٢ - إدراك الحكم الشرعي للعمولة التي يتقاضاها مصدر البطاقة.
- ٣ - استثمار الثقافة الدينية في ترسيخ القيم والأخلاق في المجتمع.
- ٤ - تحديد البدائل الشرعية لبطاقات الائتمان غير المغطاة.





الأحكام الفقهية المتعلقة ببطاقات الائتمان:

يتعلق ببطاقات الائتمان عدة أحكام أعرضها على النحو التالي أولاً: أحكام
العمولات (رسم مالي) التي يتقاضاها مصدر البطاقة
يشترط مصدر بطاقة الائتمان شروط عديدة منها شروط باطلة، وشروط
صحيحة، وشروط مختلف فيها:

الشروط الصحيحة:

كاشتراط فتح حساب بالبنك المصدر للبطاقة.

الشروط الباطلة منها:

- ١- فرض نسبة معينة عقوبة على تأخير السداد.
- ٢- دفع نسبة معينة على الشراء بالبطاقة بأكثر من المبلغ المسموح به قرضاً
حسب الاتفاقية.
- ٣- فرض نسبة معينة على تحويلات العملات الأجنبية.
- ٤- فرض نسبة معينة على تسديد الدفع للعمليات النقدية، تحسب من يوم
الشراء.

الشروط المختلف فيها:

- ١- حصول مصدر البطاقة من حامل البطاقة على رسوم الإصدار والتجديد
والاستبدال.



٢- المدفوعات التي يأخذها المصدر من التاجر، وبيان الحكم الشرعي لهذه الشروط المختلف فيها على النحو التالي.

العمولات (رسم مالية) التي يتم تحصيلها من حامل البطاقة

وتتمثل العمولات في الآتي:

١- رسوم العضوية: يحصل هذا الرسم مرة واحدة عند الموافقة على طلب العميل للحصول على البطاقة أول مرة.

٢- رسوم التجديد: يحصل هذا الرسم عند تجديد صلاحية البطاقة وإصدار أخرى للعميل بدلا عنها بعد انتهاء مدتها المقررة السابقة (سنة واحدة أو سنتين).

٣- رسوم الاستبدال: يحصل هذا الرسم عند ضياع البطاقة عن حاملها أو تلفها أو سرقتها، فيصدر البنك بدلا عنها عند إبلاغه بذلك^(١).

٤- رسوم السحب النقدي.

واختلف الفقهاء المعاصرون على حكم أخذ مصدر البطاقة رسوم الإصدار أو التجديد من حامل البطاقة ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان ذهب لذلك، د. محمد القري، د. عبد الله بن بيه، د. علي السالوس^(٢).

القول الثاني: يجوز أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان وقد ذهب

(١) مجلة المجمع، بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة، العدد ١٢.

(٢) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، ع ٣٩٠ / ١ / ٧، ع ٥٩٦ / ٢ / ٨، ع ٦٤٢ / ٣ / ١٢، ع ٦٤٢ / ٣ / ١٢، ص ٦٤٢، ٦٤٨، ٦٦٤، ع ٦٤٠ / ٣ / ١٢.



إليه أكثر الباحثين ومنهم د. رفيق المصري، د. نزيه حماد، د. عبد الوهاب أبو سليمان، د. عبد الستار أبو غدة، الشيخ محمد تقي الدين العثماني، د. عبد الله بم منيع، د. إبراهيم الدبو، د. بكر أبو زيد، د. محمد مختار السلامي وصدر به قرار مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وندوة البركة الفقهية الثانية العشرة^(١)

القول الثالث: التفصيل بين الرسوم فمنها رسوم محرمة كرسوم الضمان^(٢)، ورسوم غير محرمة كأجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة وهو ما رجحه بعض العلماء المعاصرين^(٣).

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

من المعقول ووجه الاستدلال به وجهين:

أحدهما: أن الصمان الذي يقدمه مصدر البطاقة لحاملها شبيه بالقرض، فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا؛ باعتباره من المنفعة المشروطة في القرض، فيحرم

(١) بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، ع ٧ / ١ / ٦٧٤ ، ٣٩٠ ، الجوانب الشرعية د. محمد عبدالحليم عمر ص ٧٦ ، الوثيقة رقم (١) في مجلة مجمع الفقه: ع ٧ ج ١ ص ٤٦٧ من إعداد مركز تطوير الخدمة المصرفية في بيت التمويل، قرارات وتوصيات ندوة البركة: ص ٢٠٣ .

(٢) أي أجرا على ضمان الائتمان لا الخدمات الفعلية وقد اتفق الفقهاء على تحريم أخذ الأجر على الضمان.

(٣) البطاقات الائتمانية د. محمد صالح الفوزان، www.saaaid.net



سدا للذريعة^(١).

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه لا علاقة بين القرض وبين هذه الرسوم، فالرسوم تُفرض ولو لم تستخدم البطاقة، ثم إن الرسوم تكون عند الإصدار، أي قبل وجود القرض الذي لا يحصل إلا باستخدام المشترك للبطاقة^(٢).

الوجه الثاني: أن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لدرجة الوقوع في الحرج.

ثانيهما: أن تكلفة الرسوم لا تتناسب مع تكلفة إصدار البطاقة.

ويمكن أن يناقش: سلمنا تحريم الزيادة في الرسوم، ولا يعني ذلك تحريم كل رسم في أي بطاقة؛ لأن قيمة الخدمات المصرفية يصعب تحديدها بدقة والغرر^(٣) اليسير معفو عنه^(٤).

أدلة القول الثاني:

القياس والمعقول:

أما القياس: قياس أخذ رسوم البطاقة على حكم أخذ الرسوم المتعارف عليها في

(١) د. علي القري، مجلة المجمع، ع ٧.

(٢) د. تقي الدين العثماني، مجلة المجمع ع ٧.

(٣) الغرر: فالغرر في اللغة: الخطر، وهو الذي لا يُدرى أيكون أم لا، وغرر بنفسه وماله تغريراً عرضهما للهلكة. لسان العرب ١٣/٥.

والغرر في الاصطلاح: "ما يكون مجهول العاقبة. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٩/٢٢.

(٤) أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يؤثر وممن نقل الإجماع الجصاص، وابن العربي، والنووي. أحكام القرآن، للجصاص ٢/ ١٨٩، المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي ٦/ ٨٣، المجموع، للنووي ٩/ ٥٨.



المرافق العلمية والاجتماعية؛ إذ المقصود منها تغطية نفقات الأعمال الإدارية، والأدوات المكتبية^(١).

أما المعقول فوجه الاستدلال به: أن الرسوم مقابل خدمات فرسـم الاشتراك بمثابة أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرفية المرتبطة بالبطاقة لقاء إجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة.^(٢) فهي عبارة عن وكالة بأجر على عمل أو منفعة يؤديه مصدر البطاقة لحامل البطاقة^(٣)

ويمكن أن يُناقش: بأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيراً على هذه التكاليف خاصة مع كثرة البطاقات المُصدرة؛ فيشترط أن تكون الرسوم في مقابل التكلفة الفعلية، خروجاً من شبهة الأجر على الضمان والمنفعة المشروطة في القرض فيما زاد عن التكلفة رباً^(٤).

أدلة القول الثالث:

من المعقول ووجه الاستدلال به:

أن الرسوم إن كانت واردة على التكاليف والنفقات الفعلية، فهي جائزة أما رسوم الضمان فيحرم أخذ الأجر على الضمان، وكذا أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة، وهذه في الواقع تابعة للضمان؛ لذا لا يجوز أخذها؛ للقاعدة الفقهية (التابع تابع)^(٥).

(١) مجلة المجمع ع ١٠.

(٢) الشيخ حسن الجواهري، مجلة المجمع ع ٨.

(٣) مجلة المجمع: ع ١٢ ج ٣، ٥٠٩.

(٤) البطاقات الائتمانية، د. محمد صالح الفوزان، www.saaaid.net

(٥) المرجع السابق، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، قرارات وتوصيات، ٢٧.

الراجع:

بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: القائلون بجواز أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان؛ لأن هذا مقابل خدمات فعلية، وذلك لرفع الحرج عن جميع الأطراف ولضمان استمرارية هذه الخدمات، ولما فيه من التوسط بين تحريم القول الأول وإطلاق الثاني.

وهذا الجواز مقيد بشرطين^(١).

الشرط الأول: أن يكون المبلغ ثابتاً؛ أما جعله بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ^(٢) فيه شبهة الربا.

الشرط الثاني: أن يكون المبلغ مقابل خدمة فعلية حقيقية؛ فلا يجوز زيادة المبلغ فوق هذا.

وقد صدر عن ندوة البركة الثانية عشرة الفتوى التالية: يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان أن يأخذ من طالب البطاقة رسوم العضوية، ورسوم الاشتراك أو التجديد، ورسوم الاستبدال على أن تكون تلك الرسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل البطاقة.

وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة "بخصوص أجور خدمات

(١) البطاقات البنكية، د. عبد الوهاب أبو سليمان، مجلة مجمع الفقه ع ١٠.

(٢) فثلاً أن تكون النسبة ٢٪ فيكون على سحب الألف عشرة جنيهاً، والألفين عشرين وهكذا، أما المبلغ الثابت فلا يتزايد بزيادة السحب كعشرة جنيهاً على عملية السحب أياً كان المبلغ المسحوب.



القروض في البنك الإسلامي للتنمية القرار رقم (١) في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨-١٣ صفر عام ١٤٠٧هـ / ١١-١٦ أكتوبر ١٩٨٦م وجاء فيه ما نصه:

"جواز أخذ أجور عن خدمات القروض، أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً^(١)"

عمولات الجهة المنظمة الراعية للبطاقة الائتمانية: تُجني المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان أرباح كثيرة من البطاقات المصرفية، إضافةً إلى رسوم العضوية في المنظمة.

وللعلماء قولان في العمولة التي تحصلها المنظمة الراعية للبطاقة:

القول الأول: يرى مشروعية العمولة التي تحصل عليها الجهة الراعية للبطاقة؛ لأن ما تحصل عليه المنظمة من الأعضاء عمولة في حدود الخدمة التي تقدمها للعملاء، لأن هذه المنظمات ليست شركات هدفها الربح، بل هي بمثابة ناد أو هيئة مالية لجذب البنوك الراغبة في إصدار البطاقة.

القول الثاني: فيه تفصيل فإن كانت البطاقات بطاقات ربوية تعتمد الفائدة مقابل تقسيط الدين، فعمل تلك المنظمات يكون محرماً؛ لأن عملها يقوم على تيسير عملية الإقراض بالفائدة، أما إذا لم يترتب على وساطتها فوائد ربوية محرمة فأجرتها صحيحة، ولا حرج في دفع الرسوم^(٢).

(١) منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، قرارات وتوصيات، ٢٧.

(٢) بطاقات الائتمان والتكليف الفقهي لها، المقال العاشر، القصيم، العدد ١٣٠، رمضان ١٤٢٩.



العمولات التي يقطعها مصدر البطاقة:

من التاجر:

يترتب على العقد المبرم بين مصدر البطاقة والتاجر رسوم يحصلها البنك من التاجر.

تنقسم الرسوم إلى قسمين:

القسم الأول: رسوم مقطوعة يأخذها البنك مقابل خدمات معلومة مباحة، ونحو ذلك، فهذه الرسوم لا خلاف في أخذها.

القسم الثاني: رسوم متعلقة في عملية البيع والشراء عن طريق بطاقات الائتمان، وذلك بخضم نسبة معينة من قسائم البيع لصالح مصدر البطاقة، وتُعد هذه العمولة التي يأخذها البنك المصدر والتي تتراوح ما بين ٢ إلى ٥ ٪ من قيمة الفاتورة حسب الاتفاق بينه وبين التاجر من أهم مصادر الربح للبنوك في نظام البطاقات^(١).

صورة المسألة: إذا كانت المشتريات بمائة جنية - مثلاً - علي حاملها، فإن التاجر يستوفي من البنك خمسة وتسعين جنيهاً، وخمسة جنيهاً تكون للبنك، عمولة علي التسديد عن حاملها، والترويج للتاجر وما يلزم ذلك من دعاية. فما مدى مشروعية أخذ البنك لهذه الرسوم؟^(٢)

واختلف العلماء المعاصرون على حكم العمولة التي يحصلها البنك من التاجر

(١) البطاقات البنكية، د. عبد الوهاب أبو سليمان، مجلة مجمع الفقه ١٠ ع.

(٢) المعاملات المالية المعاصرة د. ديبان محمد ١٢ / ٨٦٨.



بنسبة معينة من فاتورة البيع ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر جائزة ذهب لذلك د. عبد الستار أبو غدة، د. الصديق محمد الأمين الضرير، علي القري عيد، د. نزيه حماد، د. محمد علي داغي، د. حسن الجواهري^(١).

القول الثاني: العمولة التي يحصلها البنك من فاتورة التاجر غير جائزة ذهب لذلك: الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري، الشيخ إبراهيم الدبو، الشيخ حمادي، د. بكر أبو زيد، د. عبد الستار أبو غدة^(٢).

الأدلة والمناقشة.

أدلة القول الأول:

من المعقول ووجه الاستدلال به.

الأول: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر، هي أجرة السمسرة التي يقوم بها البنك للتجار لحاملي البطاقات، وكذلك مقابل الأجهزة والنشرات والملصقات^(٣).

(١) بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة، ندوة فقه بطاقات الائتمان/ البحرين - سبتمبر ١٩٨٨ م ص ٢٩، مجلة المجمع، ع ١٢، مناقشات مجلة المجمع د. علي داغي، ع ١٢، التكيف الشرعي لبطاقة الائتمان د. نواف باتوبارة، ص ١٧٣، ١٧٤. د. نزيه حماد قضايا فقهية معاصرة ص ١٥٣، د. حسن الجواهري، مجلة المجمع، ٦٢٠ / ٢ / ٨.

(٢) بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه، ع ٨، ع ١٢، مناقشات المجمع، مجلة المجمع، ع ٨، مناقشات المجمع مجلة المجمع، ع ١٢، بطاقات الائتمان د. بكر أبو زيد ص ٥٩.

(٣) بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع، العدد ١٢.



ويمكن أن يناقش: بأن تخريج العمولة على أنها سمسرة غير مسلم؛ لأن السمسار يقوم ببيع أشياء معينة ومعروفة، ومصدر البطاقة قد لا يعلم بهذه السلع التي تباع عند التجار، إلا إذا جاءه التاجر ببطاقات البيع^(١).

الثاني: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر من باب المصالحة على الدين، بين مصدر البطاقة والتاجر، بناء على ما ذكره الحنفية من جواز رجوع الضامن على المكفول بما ضمن لا بما أدى^{(٢)(٣)}.

ويناقش: بأن هذا القياس مع الفارق؛ لأن الصورة الحاصلة بين العميل والبنك والتاجر، تختلف عن صورة رجوع الضامن على المكفول بما ضمن؛ لأن البنوك تلتزم بالدفع والأداء عن العميل قبل معرفة المال المطلوب وقبل الأجل، وبذلك تكون البنوك مقرضة، ثم تأخذ من العميل القرض الذي أدته عنه، مقابل الزيادة وهي ما خصمته من التاجر.

الثالث: العمولة التي يحصلها البنك من التاجر، عبارة عن أجر على وكالة ووساطة بين التاجر وبين حامل البطاقة، من ترويج التعامل معه ودعاية له وتأمين زبائن وتسهيل تحصيل قيمة بضائعه^(٤).

(١) مناقشات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع، العدد ١٢.

(٢) مثال ذلك: يفترض أن حامل البطاقة اشترى بقيمة ألف جنيه ثم أحال حامل البطاقة التاجر على مصدر البطاقة، وتم الاتفاق بين المصدر والتاجر على نسبة خصم معينة، كأن تكون ٣٪ من قيمة الفاتورة، فيدفع المصدر للتاجر ٩٧٠ جنيهاً فقط بموجب الاتفاق، ويحق للمصدر الرجوع على حامل البطاقة بما ضمن أي بالألف كاملة لا بما دفعه للتاجر.

(٣) بطاقات الائتمان غير المغطاة، د. نزيه حماد، د. محمد على القري، مجلة المجمع، العدد ١٢.

(٤) الأسئلة الموجهة إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، في بيت التمويل الكويتي، مجلة المجمع،



أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن العمولة التي يحصلها البنك من التاجر محرمة بالمعقول ووجه الاستدلال به.

الأول: أن بنك التاجر^(١) إذا قام بتسديد المبالغ المستحقة للتاجر حالا، ثم رجع بها على المصدر مع خصم عمولته وعمولة المصدر، فقد قام بإقراض التاجر بالفائدة المئوية؛ لأنه يحصل هذه المبالغ كاملة من المصدر، والمصدر يحصلها من حامل البطاقة، فالعملية تصير قرضا جر نفعا، وهو حرام، وليس مجرد وكالة من التاجر^(٢).

ويناقش: بأن أخذ البنك المصدر للبطاقة نسبة من ثمن البضاعة أجراً على قبول البنك ضمان الدين الذي في ذمة العميل للتاجر، وعلى هذا فلا توجد عملية إقراض للتاجر؛ بل هي عملية إقراض للعميل^(٣).

الثاني: إن نسبة الخصم الذي يأخذها البنك من التاجر تشبه (خصم) الأوراق التجارية وخصم الأوراق التجارية محرم فتكون النسبة محرمة^(٤).

= العدد ٧، بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع، العدد ١٢.

(١) بنك التاجر: الذي يقوم بمتابعة تسديد فواتير البيع للتجار مع البنوك المصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية البيع؛ إما أن يكون هو نفس البنك الذي أصدر البطاقة، أو لا، فقد يكون البنك الذي أصدر البطاقة بنكاً محلياً أو بنكاً أجنبياً في بلد آخر، وبالتالي فإن التاجر سوف يقدم فاتورة البيع إلى البنك الذي يتعامل معه، والذي بدوره يقدم هذه الأوراق إلى البنك الذي أصدر البطاقة إن كان بنكاً محلياً، وسوف يتقاسم بنك التاجر مع البنك المصدر للبطاقة العمولة التي تؤخذ من التاجر.

(٢) بطاقات الائتمان والتكليف الفقهي لها، د. ديبان محمد الديبان

(٣) بطاقات الائتمان، الشيخ حسن الجواهري، مجلة المجمع، ع ٨.

(٤) بطاقات الائتمان، د. محمد القري عيد، مجلة المجمع، ع ٧.



الراجع:

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يبدو لي - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأن العمولة التي يحصلها مصدر البطاقة من التاجر جائزة وذلك لما يلي:

١ - دفعا للخرج فالخرج مرفوع بنصوص الشريعة وهذه النسبة التي تحدد تكون مقابل الخدمات المقدمة للتاجر، والمتمثلة في تحصيل فواتير الشراء، وجذب العملاء إليه، وتسهيل تعامله معهم.

٢ - أن الدعاية والترويج، وتأمين الزبائن وتحصيل قيمة البضائع بحاجة إلى الإنفاق الكبير، بالإضافة إلى تخصيص موظفين لتحصيل قيمة المبيعات من قبل حاملي البطاقات، وهو جهد وخدمة تحتاج للمال.

٣ - أن حقيقة عمل البنك هو الوكالة في تحصيل الدين وتوصيله، وعلى هذا فإن النسبة التي يأخذها البنك إنما هو أجره على الوكالة في تحصيل الدين وتوصيله، والوكالة بأجر جائزة.

وبهذا القول صدر قرار:

١ - الهيئة الشرعية لشركة الراجحي وجاء فيه ما نصه: (لا نرى مانعا من الحصول على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة، مادامت هذه النسبة تستقطع من ثمن خدمة أو سلعة، وقد تم التعارف على استقطاعها من البائع لصالح البنك الذي أصدر البطاقة وشركة الفيزا العالمية).

٢ - الهيئة الشرعية لكل من بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني، حيث عدت (العمولة التي يأخذها البنك من التاجر المتعامل بالبطاقة أجر وكالة على



الوساطة بين التاجر وحامل البطاقة وما ينتج بسببها من ترويج التعامل معه، وتأمين الزبائن وتحصيل الديون).

٣- المجمع الفقهي الإسلامي فجاء فيه ما نصه: (يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك: - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون يبيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

عمولة السحب النقدي ببطاقات الائتمان:

تعريف بالسحب النقدي بالبطاقة: هو عبارة عن سحب حامل البطاقة نقودا من البنك المصدر عن طريق مكائن السحب الآلي مقابل عمولة^(١).

صورة المسألة: أن يقوم العميل بسحب مبلغ معين من رصيده ببطاقة الائتمان فيخصم من رصيده مبلغا من المال كرسوم على الخدمة، كأن يسحب حامل البطاقة ١٠٠٠ ج فيصم منه ١٠١٠ ج فالعشرة زيادة على السحب^(٢).

أنواع السحب النقدي: للسحب النقدي نوعان:

الأول: السحب اليدوي: يحصل بإبراز البطاقة لموظف البنك والحصول على النقود مناولاً، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ أي رسوم في مقابل السحب؛ لأن ذلك يكون ربا، فهذه الرسوم لا يقابلها تكاليف فعلية.

وأكدت فتاوى الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية على حرمة استخدام

(١) بطاقات الائتمان غير المغطاة د. نزيه حماد ع ١٢.

(٢) الموسوعة الميسرة، المعاملات ١/ ٣٧٧.

البطاقة الائتمانية في السحب اليدوي من البنوك الربوية؛ لأن هذه البنوك تحتسب فائدة ربوية عبارة عن نسبة مئوية من المبلغ المسحوب^(١).

الثاني: السحب الآلي: وهو ما يكون عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وهذا النوع من السحب عادةً ما يكون له تكاليف من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع.

حكم العمولة على السحب النقدي الآلي:

اختلف العلماء المعاصرون: في حكم الرسوم المأخوذة على السحب النقدي الآلي ببطاقة الائتمان ولهم قولان في ذلك.

القول الأول: يرى من ذهب إليه عدم جواز تحصيل البنك عمولة على السحب النقدي، وهذا قول د. محمد القري، د. عبد الستار أبو غدة، د. عبد الوهاب أبو سليمان^(٢).

القول الثاني: يرى من ذهب إليه جواز السحب النقدي لقاء عمولة وللقائلين به ثلاث اتجاهات.

الاتجاه الأول: جواز أخذ الرسوم سواء كانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً^(٣).

(١) البطاقات الائتمانية د. صالح الفوزان،

<http://www.islamfeqh.com>

(٢) مجلة المجمع: ع ٧/١، البطاقات الافتراضية، د. عبد الوهاب ص ١٥٧.

(٣) هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي مجلة مجمع الفقه (الوثيقة رقم ١) ع ٧ ج ١ ص ٤٧٢، فتوى ندوة البركة قرارات وتوصيات الندوة: ص ٢٠٦. د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع ع ١/٧، ١٢٤/٢.



الاتجاه الثاني: يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية. والمبلغ المقطوع يكون في مقابل النفقات الفعلية لعملية الإقراض، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية. وهو قول كثير من العلماء المعاصرين^(١).

وهذا ما صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي^(٢)، جاء في قرار الهيئة العمولة المشار إليها: هي أجر على الوكالة لقضاء الدين المترتب على العميل جرّاء سحب المبالغ في الخارج بواسطة البطاقة وهي جائزة شرعاً.

الاتجاه الثالث: يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون هناك تغطية في حساب حامل البطاقة، لوقوع المقاصة بين الدينين فوراً^(٣).

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

من المعقول هو: أن عملية السحب قرض، والزيادة على القرض ربا^(٤).

ويمكن أن يناقش: بأن ذلك غير مسلم؛ فأى زيادة لا تعد من الربا؛ فقد تكون الزيادة من تكلفة القرض، فالسحب يتطلب أجهزة، كما يتطلب إجراء اتصالات ونحو ذلك وهذا بتكاليف مالية، أما المنفعة المحرمة هي المنفعة الزائدة المشروطة

(١) د. نزيه حماد د. علي السالوس، د. أحمد بن علي سير المباركي، مجلة المجمع ع ١/٧، د. خالد

المشيّق، مجلة لواء الشريعة، دروس الدورة العلمية بجامعة الراجحي بريدة لعام ١٤٢٥هـ.

(٢) بطاقات الائتمان المصرفية والتكليف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي إعداد مركز تطوير

الخدمة المصرفية بيت التمويل الكويتي مجلة المجمع ع ١/٧.

(٣) بطاقات الائتمان غير المغطاة، د. نزيه حماد، ع ١٢.

(٤) د. محمد علي القري، مجلة المجمع ع ١/٧/ ٣٩٣.



للمقرض^(١).

أدلة القول الثاني:

من المعقول:-

أولاً: الاتجاه الأول: أن رسوم السحب النقدي عبارة عن أجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها مصدر البطاقة لحامل البطاقة^(٢).

ويناقش: بأن حامل البطاقة قد يستخدمها في الحصول على بعض الخدمات كالاتّعام عن الرصيد ونحوه فهي كالسحب النقدي من حيث التكلفة، وهذا يدل على ارتباط هذه الرسوم بالمقرض^(٣).

ثانياً: أدلة الاتجاه الثاني المعقول من أوجه:

الأول: أن أخذ رسم المالي متغير بتغير المبلغ المسحوب فيه شبهة الربا، وهذا غير متحقق في حالة كون الرسم مبلغاً مقطوعاً في كل حالة من حالات السحب.

الثاني: أن السحب النقدي من حامل البطاقة في حقيقته اقتراض من (مصدر البطاقة)، فما يأخذه مصدر البطاقة من زيادة ربا محرم شرعاً، ويستثنى من ذلك التكلفة الفعلية للإقراض فهي غير داخلية في المنفعة المحرمة^(٤).

(١) البطاقات الائتمانية، موقع صيد الفوائد.

(٢) هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي مجلة مجمع الفقه (الوثيقة رقم ١) ع ٤٧٢/١/٧.

(٣) البطاقات المصرفية ص ١٨٤.

(٤) د. نزيه حماد: ع ٥٢١/٣/١٢.



ويناقش: بأن هذا العقد عقد مركب من عقدين: أحدهما: القرض، والآخر: الإجارة، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد الإجارة، فأخذ العمولة على هذا القرض من قبيل الربا المحرم^(١).

أدلة الاتجاه الثالث المعقول وهو: أن أخذ الرسوم من حامل البطاقة مقابل السحب النقدي في مقابل تقديم هذه الخدمة، هي أجرة على توصيل النقود إلى حيث يريد حامل البطاقة سحبها^(٢).

الرأي الراجح:

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يبدو لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني - الاتجاه الثالث - وذلك لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا.

يؤكد ذلك نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٣ (١/٣) في دورته الثالثة بعمان (أكتوبر ١٩٨٦م) بخصوص أجور خدمات القروض:

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً: كل زيادة على النفقات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً. ومما تجدر الإشارة إليه: أن بعض الهيئات الشرعية رأت أن تضع صندوقاً خاصاً لهذه الفوائد المحتسبة، ثم تتخلص منها في وجوه الخير.

(١) بطاقات الائتمان، الشيخ محمد الديان، <http://www.alukah.net>

(٢) بطاقات الائتمان غير المغطاة، د. نزيه حماد، ع ١٢.



يقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمته الله: "هذه المشكلة قد تدوركت بأن البنك الإسلامي الذي يريد أن يصدر بطاقة يشترط عليه أن ينشئ صندوقا خاصا لديه لتلك الفوائد التي تحتسب له رغما عنه، وليس بطلب منه، وتأتيه على المبالغ التي استعملت فيها البطاقة، وهذا الصندوق ما يتجمع فيه يوجه إلى جهات الخير الإسلامية شأن سائر الفوائد التي تحتسب لبعض المودعين في البنوك، ولا يريدون أن يقعوا في المحرم، فهم يصرفونها كما في فتوى المجمع الفقهي في مكة"^(١).

شراء الذهب والفضة بطاقة الائتمان:

صورة المسألة:

يذهب حامل بطاقة الائتمان إلى محل الحلبي، ثم يشتري الحلبي الذي يرغب فيه، وبدلا من دفع الثمن نقدا يقدم بطاقة الائتمان للبائع لدفع ثمن الحلبي، ويقوم البائع بالتأكد من صلاحية البطاقة، ثم يدون بعض المعلومات المتعلقة بالبطاقة؛ ويوقع حامل البطاقة على السند الذي يختمه البائع ثم يعيد البائع البطاقة إلى صاحبها مع صورة من السند الذي يحتفظ بنسخة منه، ويبعث النسخة الثالثة لمصدر البطاقة ليتحصل التاجر على قيمة السند.

شروط صحة بيع النقد بمثله:

اشترط جمهور الفقهاء^(٢) لصحة بيع النقد بمثله شرطان:

(١) بطاقات الائتمان، الشيخ ديبان محمد الديان،

<http://www.alukah.net>

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥/ ٢١٥، فتح القدير ٦/ ٢٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٥١، جواهر

الشرط الأول: التماثل إذا اتحد الجنس كأن يكون ذهباً بذهب، إذا اختلف الجنس كبيع الذهب بالفضة، فإنه يصح البيع والشراء بالزيادة على قيمته أو بنقصها بشرط التقابض في مجلس العقد، وذلك لما روى عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.. مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" (١)

فقوله ﷺ: "يدا بيد" دليل صريح على اشتراط التقابض بين البائع والمشتري قبل أن يتفرقا.

الشرط الثاني: التقابض (٢) في مجلس العقد، وعدم تأجيل أحد البديلين إلى وقت آخر (٣) وذلك استدلالاً:

١ - بحديث عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لى ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلى فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح. قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال "ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا" (٤).

= الإكليل ١٠/٢، مغني المحتاج ٢٥/٢، المغني لابن قدامة ٤١/٤، كشف القناع ٣/٢٦٦.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الربا - باب الصرف ربيع الذهب بالورق نقداً - ج ٣ - ص ١٢١١ - برقم ١٥٨٧.

(٢) القبض في اصطلاح الفقهاء: حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي.

(٣) بدائع الصنائع ٥/٢١٥، فتح القدير ٦/٢٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٥١، جواهر الإكليل ١٠/٢، مغني المحتاج ٢/٢٥، المغني لابن قدامة ٤١/٤، كشف القناع ٣/٢٦٦.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الربا - باب النهي عن بيع الورق بالذهب - ج ٣ - ص ١٢١٢ - برقم ١٥٨٩.



٢- وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز "(١).

والإجماع قال ابن المنذر: (وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف (٢) فاسد) (٣).

حكم شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين ولهم في ذلك ثلاثة أقوال.

القول الأول: يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة ذهب لذلك د. عبد الستار أبو غدة، د. نزيه حماد، د. يوسف الشبيلي (٤) وبه صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

القول الثاني: لا يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة ذهب لذلك الشيخ عبد الرحمن بن عجيل، الشيخ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الربا - باب النهي عن بيع الورق ج ٣ - ص ١٢٠٨ - برقم ١٥٨٤.

(٢) الصرف: في اللغة يقال: صرفت الدراهم بالدنانير. وبين الدرهمين صرف، أي زيادة ومنه سميت العبادة النافلة صرفاً، يأتي الصرف بمعنى التحويل، قال تعالى: ﴿وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ﴾ [البقرة: ١٦٤]. في الاصطلاح: مبادلة الأئمان بعضها ببعض. أي بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس: أي بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، مصوغاً أو نقداً. بدائع الصنائع ٥/ ٢١٥.

في الاقتصاد: مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية.

(٣) الإجماع ص ٧٩.

(٤) بطاقات الائتمان مجلة المجمع ع ٧/ ١/ ٦٦٣، ع ١٢، قضايا فقهية معاصرة د. نزيه حماد ص ١٦٠.

المختار السلامي، الشيخ عبد الرحمن السحيم، الشيخ الصديق محمد الأمين الضير^(١).

القول الثالث: يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين إذا كانت البطاقة مغطاة ذهب لذلك د. محمد عثمان شبير، د. وهبة الزحيلي، د. عبد الستار أبو غدة^(٢)

وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي فقد جاء فيه ما نصه: (لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين العلماء المعاصرين إلى أمرين:

الأول: اختلافهم في ماهية القبض هل مجرد قبول الجهاز للبطاقة، وتوقيع العميل على عملية الشراء يعد قبضاً حقيقياً أم لا؟^(٣).

(١) مناقشات بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، ع ١٢

<http://al-ershaad.com>

(٢) بطاقات الائتمان د. وهبة مصطفى الزحيلي، ع ١٥/٣/٢٧، ١١-٦-٣-٢٠٠٤ م. مسقط سلطنة عُمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، ٥٤٥، المعاملات المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير، دار النفائس، ص ١٩٣، بطاقات الائتمان تصورها والحكم عليها د. عبد الستار أبو غدة ع ١٢/٢، البند (٤) من قرار رقم ١٠٨ المتخذ في دورته الثانية عشرة في الرياض التي انعقدت في الفترة من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى ١ رجب ١٤٢١ هـ الموافق ٢٣ - ٢٨ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠.

(٣) والذي يجري في واقع البنوك أن عمليات البيع والشراء ببطاقات الصرف الإلكتروني، والبطاقات الائتمانية المقاصة آلياً من البنوك في نهاية اليوم، وبالتالي لا يدخل المبلغ في حساب التاجر إلا بعد =



الثاني: الشراء ببطاقة الائتمان هل يعد من قبيل الصرف أم لا .

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقاً مغطاة أم لا بأدلة من المعقول وذلك من وجهين:

الأول: أن تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة يعد قبض حكمي، كقبض الشيك، وقد ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى القول بأن الشيك إذا كان محرراً من قبل البنك، فإنه يقوم مقام قبض محتواه^(١)، وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (بجواز شراء الذهب والفضة بالشيك على أن يتم التقابض في المجلس)^(٢).

ويناقش: بأن الشيك أداة وفاء في الحال، فيكون قبضه قبضاً حكماً لمحتواه، وبطاقة الائتمان أداة وفاء في المستقبل؛ لأن التاجر لا يستطيع أن يحصل على ثمن الذهب الذي اشترى بها إلا بعد فترة من الزمن^(٣).

الثاني: أن التاجر عند تمرير البطاقة على الجهاز الآلي، يقوم على الفور بقراءة

= الساعة الثانية عشرة ليلاً، فهل يعد هذا امتداداً لمجلس العقد حتى يعتبر قبضاً حكماً؟ التقابض في الفقه الإسلامي، مجلة المجمع ع ٧/ ١ / ٤٥٩.

(١) البطاقة الائتمانية د. يوسف الشبيلي، مجلة المجمع ع ١٢.

(٢) قرار رقم ٨٤ (٩/ ١) بشأن تجارة الذهب (الدورة التاسعة - أبو ظبي/ أبريل ١٩٩٥ م)، التقابض في الفقه الإسلامي د. علاء الدين عبد الرزاق ص ٢٧٠.

(٣) بطاقة الائتمان الشيخ الصديق محمد الضير، مجلة المجمع ع ٢١.



شريط المعلومات فيها، وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في البنك المصدر، الذي يتولى قيد المبلغ على حساب العميل، وتحويل المبلغ إلى حساب التاجر^(١).

أدلة القول الثاني:

من السنة والمعقول

أما السنة: فعن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)^(٢).

وجه الدلالة من هذا الحديث: دل الحديث على أن التقابض الفوري في النقدين شرط، وإن كل تأخير في أحد البديلين مخالف لنص الحديث؛ فيكون استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين غير جائز^(٣).

ويمكن أن يناقش: بأن قوله ﷺ: (يداً بيد) لا يدل على اشتراط القبض باليد، وإنما المقصود أن يتم القبض الحكمي في المجلس.

أما المعقول فوجه الاستدلال به: أن شرط القبض المأمور به شرعاً غير متحقق؛ فإن التقابض شرط في شراء الذهب والفضة، وتسديده بواسطة البطاقة لا يتم في

(١) التكيف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف باتوبارة، ص ١٨٦، بطاقة الائتمان د. يوسف الشيبلي، مجلة المجمع ع ١٢.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) مناقشات بطاقات الائتمان، الشيخ عبد الرحمن بن عقي، مجلة المجمع ع ١٢.



الحال^(١).

ويناقش: بأن القسيمة تصرف فوراً حال تقديمها إلى البنك المصدر للبطاقة.
وأجيب: بأن شرط التقابض في المجلس لا يكون متحققاً؛ لأن حامل البطاقة عندما يقدم البطاقة للتاجر يتسلم الذهب، ويوقع على القسيمة، ولا يدفع الثمن للتاجر، والذي يدفع الثمن للتاجر هو البنك المصدر للبطاقة عندما يقدم التاجر إليه القسيمة بعد فترة يتفق عليها^(٢).

أدلة القول الثالث:

من المعقول ووجه الاستدلال به: - أن الشراء بالبطاقة المغطاة فيه تقابض حكمي معتبر شرعاً، إذا دفع البنك المصدر المبلغ إلى التاجر بدون أجل، على أنه وكيل للمشتري^(٣).

أما شراء الذهب ببطاقة الائتمان غير المغطاة؛ فلا يجوز؛ لعدم تحقق القبض في مجلس العقد.

فإن قيل: إن وجود فاتورة الدفع الموقعة من قبل حامل البطاقة قبض حكمي.
أجيب: بأن التاجر بهذه القسيمة ضمن حقه فقط، ولم يقبض المال، إنما يقبضه بعد فترة، وضمن الحق لا يعني القبض.

(١) مناقشات بطاقات الائتمان، الشيخ المختار السلامي، مجلة المجمع ع ١٢.

(٢) مناقشات بطاقات الائتمان، الشيخ الصديق محمد الضير، مجلة المجمع، ع ١٢.

(٣) بطاقات الائتمان، الدورة الخامسة عشرة ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م. مسقط سلطنة عُمان، الدكتور وهبة



ويرد ذلك: بأن التفريق بين أن تكون البطاقة مغطاة أو غير مغطاة، هذا لا تأثير له في حقيقة القبض، فالبنك لم يكن مجرد كفيل في هذه المعاملة، بل هو كفيل ووكيل بالدفع، وخصم المبلغ لمصلحة البائع، لا يختلف بين أن يكون الرصيد مغطى أم لا^(١).

الراجع:

بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بجواز شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقاً مغطاة أم لا، وذلك لما يلي:

أولاً: أن القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي صحيح، لأن القبض هو إثبات اليد، والقبض يستند في كثير من أحكامه إلى العرف.

ثانياً: أن البطاقة الائتمانية أصبح لها من القبول عند الناس ما يفوق الأوراق النقدية والتجارية.

البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان غير المغطاة:

اقترح العلماء المعاصرون بديل شرعي يحقق ما تحققه بطاقات الائتمان لحاملها ولمصدرها؛ والغرض من ذلك:

١ - اجتناب المحظور في المعاملة، وتنقيتها من المحاذير الشرعية

٢ - الدعوة إلى إيجاد حلٍّ بعيداً عن التبعية الأجنبية.

(١) بطاقات الائتمان، الشيخ محمد الديان، <http://www.alukah.net>



٣- محاولة تحويل هذه المعاملة من القرض بفائدة إلى معاملة معاصرة أبحاثها بعض الهيئات الشرعية: كالبيع بالتقسيط، أو تطور الصيغة المقترحة إلى المراجعة للأمر بالشراء، أو تطور أكثر إلى التورق المنظم.

وبيان هذه البدائل على النحو التالي:

أولاً: بطاقة البيع بالتقسيط: بأن ينشئ البنك الإسلامي متاجر للبيع بالتقسيط على الأفراد أو المشاركة، ويستفيد من ربح البيع، والفارق بين البيع الحال والمقسط^(١). وهذا البديل لا يصلح في الحصول على النقود (السحب الآلي)^(٢).

ثانياً: بطاقة المراجعة للأمر بالشراء: بأن يوكل البنك العميل بأن يشتري ويقبض عنه، ويسدد البنك، ثم يبيع على العميل بزيادة^(٣).

وهذا البديل لا يسهم في توفير خدمات كثيرة؛ كخدمات المطاعم والفنادق؛ حيث أن العميل ينتفع بالخدمة قبل السداد^(٤).

ثالثاً: بطاقة (الخصم) الشهري: وهي البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية على أن يتم تحديد قيمة المسحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري، على ألا يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلك.

فتقوم على أساس الوكالة إذا كان حساب العميل يفي بجميع المبلغ الذي تم

(١) العقود المالية المركبة، للعمري، ص ٣٧٧، مجلة البحوث الفقهية ع ١٤ / ١٩٨.

(٢) بطاقات الائتمان د. الصديق الضير، مجلة المجمع ع ١٢.

(٣) وقد طرحه د. وهبة الزحيلي، ومحمد القري، مجلة المجمع، العدد ١٢، (٣/ ٦٣٣).

(٤) بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة: ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م. مسقط (سلطنة



سحبه عن طريق بطاقة الائتمان، أما إذا كان حساب العميل لا يفي بالمبلغ، فإن المصرف يقوم بتسديده على أساس القرض الحسن الذي يقدمه المصرف لعميله، بضمان الراتب الشهري، وهذا مشروع ومندوب إليه^(١).

رابعا: تجديد الدين عن طريق التورق^(٢) المصرفي^(٣): حيث يأخذ العميل مبلغا يسدد عن طريقه مديونية البطاقة ويسدد للمصرف مديونية التورق^(٤). في حالة تأخر العميل عن السداد، يقوم البنك ببيع سلعة بثمن أكبر من المديونية على العميل، ثم يبيعها عنه لطرف آخر (غير المشتري منه)، ويسدد القرض الأول، ويجدول الدين الثاني الأكثر إلى أقساط جديدة^(٥).

وهذه البدائل لم تسلم للخلل من الجهة الشرعية، ومن عدم القدرة على تلبية احتياجات أطراف البطاقة في الواقع العملي.

(١) بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م. مسقط (سلطنة عُمان).

(٢) التورق في اللغة: التورق طلب الورق أي الدراهم. مختار الصحاح ٢٩٩. وفي الاصطلاح الفقهي لم يذكر الفقهاء تعريفاً للتورق، وإن كان هذا المصطلح قد شاع عند الحنابلة ويراد به: أن يشتري المرء السلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد. الانصاف ١٩/١١.

(٣) التورق المصرفي: اتجهت كثير من المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم، كبديل شرعي للقرض الربوي الذي تقدمه البنوك التقليدية. التورق المصرفي وتطبيقاته:

<http://www.alukah.net>

(٤) بطاقة الائتمان المتجدد.. البدائل الشرعية، عثمان ظهير، مجلة المجمع ع ١٥، ١٠٨/٣.

<http://muntada.islammmessage.com>

(٥) وقد نوقش في المجمع، العدد ١٥، ١٠٨/٣.



ويوجد الآن أنموذجين لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما^(١):

الأول:- فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا الاسم.

الثاني:- فيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ملخص الموضوع:

١ - عرف علماء مجمع الفقه الإسلامي بأنها: بطاقات الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

٢ - تحقق بطاقات الائتمان منافع لمصدرها وحاملها والتاجر.

٣ - بطاقة الائتمان لها أثر إيجابي وآخر سلبي على الفرد والمجتمع وعلى الفرد الموازنة بين المصالح والمفاسد.

٤ - لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

٥ - يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

٦ - جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار، أو

(١) بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ١١:٦-٣-٢٠١٤م. مسقط (سلطنة عُمان).



التجديد إذا كان أجرا فعليا على الخدمات المقدمة منه.

٧- جواز أخذ مصدر البطاقة من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة هو السعر الذي يبيع به بالنقد.

٨- السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيل ذلك الرسوم المقطوعة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا.

٩- لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير

١٠- اجتهد العلماء في إيجاد بدائل الشرعية للمحاذير التي ترد في بطاقات الائتمان.

المراجع:

١- أبحاث مجمع الفقه الإسلامي، وهي مجلة تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مكة المكرمة، الأعداد الثالث، السابع، الثامن، العاشر.

٢- بطاقات الائتمان المصرفية، مركز تطوير الخدمات المصرفية في بيت التمويل الكويتي، مجلة المجمع، العدد ٧.

٣- بطاقات الائتمان محمد علي القري مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٧.

٤- بطاقات الائتمان وتكييفها الشرعي، د. عبد الستار أبو غدة، ضمن أبحاث مجلة المجمع العدد ٧، جدة في الفترة ما بين ١٧ إلى ١٢ من ذي القعدة ١٤١٢ هـ (٩-١٤ مايو ١٩٩٢ م).

- ٥- البطاقات البنكية الاقتراضية والسحب المباشر من الرصيد: د. عبد الوهاب أبي سليمان، دار القلم-دمشق، ط١، ١٩٩٨م.
- ٦- دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية: د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس -الأردن، ط١، ٢٠٠٩م.
- ٧- فقه النوازل، د محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٧هـ. ٢٠٠٦م.

نماذج أسئلة:

- | | |
|---|----|
| <p>اذكري أطراف بطاقة الائتمان؛ مع بيان المنافع التي تقدمها بطاقة الائتمان لحاملها، والجهات المصدرة لها؟</p> | س١ |
| <p>وضحى الفرق بين بطاقة الائتمان المغطاة، والغير مغطاة مع ذكر خصائص كل منهما؟</p> | س٢ |
| <p>بينى حكم العمولة التي يأخذها مصدر البطاقة من حاملها مقابل السحب النقدي، مع بيان أنواعه؟</p> | س٣ |
| <p>بينى حكم شراء الذهب والفضة بطاقة الائتمان؟ مع الأدلة؟ والقول المختار؟</p> | س٤ |
| <p>وضحى حكم اشتراط مصدر البطاقة عند إصدارها أن له الحق في إلغائها؟</p> | س٥ |

أكملى مكان النقاط بإجابة مناسبة:

- ١- يتولى إصدار بطاقات الائتمان العالمية جهتان رئيسيتان هما.....،.....
- ٢- من أطراف بطاقة الائتمان.....



- ٣- من المنافع التي تقدمها بطاقة الائتمان لحاملها.....،.....،.....
- ٤- خرج العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر على أنها.....،.....،.....
- ٥- من البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان غير المغطاة.....

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:-

- ١- من البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان الغير مغطاة.....
(بطاقة البيع والشراء - بطاقة الاستثمار - بطاقة الخصم الشهري -
لا شيء مما سبق)
- ٢- مصطلح مُصدر البطاقة يطلق على.....
(البنك - العميل - التاجر - لا شيء مما سبق)
- ٣- يمكن أن تُكيف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها عقد
(حوالة - ضمان - وكالة - جميع ما سبق)
- ٤- تصدر بطاقة الائتمان المغطاة
(لمن له رصيد - لمن ليس له رصيد - أ، ب معاً - لا شيء مما سبق)
- ٥- دفع نسبة معينة على تسديد الدفع للعمليات النقدية
(جائز - باطل - مكروه - لا شيء مما سبق)

ضعي علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة

الخاطئة:

- ١- من أطراف بطاقة الائتمان الحساب الجاري في البنك ()
- ٢- من البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان غير المغطاة بطاقة البيع
بالتقسيط ()



- ٣- في السحب النقدي يتحمل العميل رسوماً مالية عند استخدام البطاقة
()
- ٤- يصح أن يشترط مصدر البطاقة على العميل فتح حساب بالبنك
()
- ٥- اتفق الفقهاء على جواز أخذ رسوم تجديد من حامل البطاقة
()



الموضوع الثاني:
الشرط الجزائي (غرامات التأخير)

ويحتوي على وحدتين:



مقدمة:

لم يدون مصطلح الشرط الجزائي في كتب الفقهاء المتقدمين لعدم قيام الحاجة إليه في ذلك الوقت، لكن في هذا الزمن أصبحت الحاجة إليه ملحة جداً؛ لأن تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها المشروطة مضر بالطرف الآخر في وقته وماله أكثر مما كان عليه في الزمن الماضي.

وهذا الموضوع يلقي الضوء على التعريف بالشرط الجزائي والتكييف الشرعي له، وأنواعه وحكم كل نوع.





الوحدة الأولى: تعرف الشرط الجزائى؁ والعوامل التى ساعدت على العمل به وصوره

المعلومات والمفاهيم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على:

- ١ - ذكر أقوال العلماء فى الشرط الجزائى.
- ٢ - فهم العوامل التى ساعدت على العمل بالشرط الجزائى.
- ٣ - اكتساب الطالب ملكة قياس الفروع على الأصول.
- ٤ - ترسخ لديه مبدأ إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران؁ وإذا أخطأ فله أجر.
- ٥ - إجادة استخدام الوسائل الحديثة فى استقصاء آراء المعاصرين فى الشرط الجزائى.
- ٦ - استشعار وجوب الاجتهاد فى بيان الحكم الشرعى لهذه القضايا المعاصرة.

تعريف بالشرط الجزائى:

أولاً: تعريف الشرط وأقسامه؁ وبيان معنى الجزاء.

تعريف الشرط:

لغة: إلزام الشىء والتزامه؁ والجمع شروط؁ والشرط بالتحريك: العلامة.



قال الفيروز آبادي هو: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، وجمع الشرط الشروط، وجمع الشريطة: الشرائط^(١).

الشرط في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته^(٢).

تقسيم الشروط من حيث الحكم

تنقسم الشروط من حيث الحكم إلى قسمين:

الأول: الشرط الصحيح^(٣):

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدهما: شرط يقتضيه العقد. بأن كان لهذا الشرط أثر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، كاشتراط تسليم المعقود عليه، أو رده بالعيب علي صاحبه، ونحو ذلك فهذا الشرط صحيح، ويجب الوفاء بمقتضاه، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء.

الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة مباحة في المعقود عليه فهذا الشرط صحيح باتفاق الفقهاء.

الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافياً فإن الفقهاء اختلفوا في حكم العقد مع هذا الشرط فمنهم من يري عدم

(١) لسان العرب مادة شرط، القاموس المحيط، ص ٨٦٩.

(٢) حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٢٠.

(٣) الموافقات، الشاطبي، ١/ ٢٨٣ - ٢٨٥.



صحة العقد والشرط في هذه الحالة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأن هذا الشرط مفسد للعقد من يري صحة العقد مع الشرط الذي اقترن به.

الثاني: الشرط الباطل: وهو الشرط الذي لا يقتضيه العقد، بل هو أمر زائد عليه، ولا يلائمه ولا وَرَدَ به نص، ولا جرى بع عرف، ولا منفعة فيه لأحد^(١).

ثانيا: تعريف الجزاء:

وهو المكافأة على الشيء، جزاه به وعليه جزاء، والجزاء يكون ثوابًا ويكون عقابًا ويستعمل في الخير والشر^(٢).

ثالثا: تعريف الشرط الجزائي باعتباره مركبا إضافيا.

مصطلح الشرط الجزائي من المصطلحات المعاصرة التي لم يرد ذكره عند الفقهاء القدماء، وقد أخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية، وأدخلت عليه بعض التعديلات^(٣).

ويعرف بأنه: اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيذ، أو التأخير فيه^(٤).

وعرفه علماء المجمع الفقهي: بأنه اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه، من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم

(١) المذهب، الشيرازي، ٤٠٤ / ١.

(٢) لسان العرب ٢٤٣ / ١.

(٣) الشرط الجزائي د. محمد الأمين الضير، مجلة مجمع الفقه ع ٤٩١ / ٢.

(٤) النظرية العامة للالتزامات، الأحكام، د. عبد المنعم البدر اوي، ص ٨٠.



به، أو تأخر في تنفيذه^(١).

صور الشرط الجزائي وشروطه:

أولاً: صور الشرط الجزائي:

ذكر الدكتور السنهاوري صور للشرط الجزائي ومنها:

- ١ - المقاوله: شروط المقاوله قد تتضمن شرطاً جزائياً يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو أسبوع يتأخر فيه المقاول عن تسليم العمل.
- ٢ - لائحة المصانع قد تتضمن شروطاً جزائية، تقضي بخصم مبالغ معينة من أجره العامل، جزاء له على الإخلال بالتزاماته المختلفة.
- ٣ - اشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين في دفع قسط منها^(٢).

ثانياً: العوامل التي أدت إلى العمل بالشرط الجزائي.

ساعد على العمل بالشرط الجزائي عدة عوامل منها:

- ١ - تطور أساليب التجارة الداخلية والصنائع.
- ٢ - أصبحت القيمة المالية للمشاريع كبيرة جداً مما يضاعف الخسائر عند التأخر، أو الإخلال بالعقد حيث تكون الخسائر فادحة.
- ٣ - اتساع دائرة التجارة بين الأفراد والدول حيث أصبحت العقود تتم بين ناس

(١) مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم ١٠٩ (١٢/٣)

(٢) الوسيط القسم الثاني نظرية الالتزام ص ٨٥٢ ف ٤٧٧.



بعيدين لا يعرفون بعضهم مما يزيد الحاجة إلى وجود شروط جزائية تعطي المشترط طمأنينة إلى التزام الطرف الآخر بالعقد وأنه سيحصل على التعويض المناسب عند الإخلال.

٤- ظهور عدد كبير من العقود والحقوق الجديدة كعقود الامتياز، والاستصناع الحديثة، والنقل الجوي والبحري والتوريد، والمقاولات وغيرها مما يحتاج معه إلى تضمين العقود شروطاً جزائية.

٥- أن المماثلة أصبحت سمة كثير من الناس بحيث لم يعد المتعاقدان يطمئنان إلى بعضهم البعض^(١).

ثالثاً: شروط تطبيق الشرط الجزائي:

يشترط لتطبيق الشرط الجزائي شروط منها:

١- ثبوت الضرر^(٢): فالتعويض المستحق بسبب الشرط الجزائي لا يكون إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

٢- ألا يكون في الشرط الجزائي مبالغة، فإذا كان الشرط الجزائي مبالغاً فيه بالنسبة لقيمة الالتزام الأصلي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من قيمة الالتزام الأصلي.

(١) الشرط الجزائي د. محمد بن عبد العزيز اليميني، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد، السعودية ص ٢٦/٢٧.

(٢) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند الخامس الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاتته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي.

٣- ارتكاب المدين خطأ أو غشاً جسيماً تسبب في ضرر ويتمثل الخطأ في عدم تنفيذ الالتزام، أو التأخير فيه أو تنفيذه معيباً^(١).

٤- إغذار المدين^(٢): أي التنبيه عليه بالتنفيذ.

رابعاً: الأحوال التي لا ينفذ فيها الشرط الجزائي ما يلي:

١- إذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فلا يعمل به، ويرجع في تقدير الضرر إلى أهل الخبرة والشأن في ذلك، ولا بد من مراعاة قواعد العدل ورفع الضرر عن الناس، لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»^(٣)

٢- إذا كان هنالك عذر في الإخلال بالالتزام فيكون العذر الشرعي مسقطاً لوجوبه حتى يزول العذر.

وهذا ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء جاء فيه ما نصه: "أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.

(١) الشرط الجزائي، د. محمداتي شبيبها العين، مجلة مجمع الفقه ع ١٢.

(٢) ماهية الإغذار: دعوة يوجهها الدائن للمدين تتضمن مطالبته بتنفيذ التزامه فوراً بحيث يعد المدين متأخراً بعد هذه الدعوى.

(٣) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ج ٢ ص ٧٨٤ برقم ٢٣٤٠. قال البوصيري: هذا الحديث اسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع. يُراجع: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ج ٣ ص ٤٨.



وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا يراد به التهديد المالي ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: الآية ٥٨]. وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: الآية ٨]، وبقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار" وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند السادس: "لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد" (١).



(١) قرارات المجمع " (ص ٣٧١) طبعة وزارة الأوقاف القطرية.



الوحدة الثانية:

التكييف الفقهي للشرط الجزائي وذكر أنواعه وحكمه

✍ المعلومات والمفاهيم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على:

- ١ - إدراك التكييف الفقهي للشرط الجزائي.
- ٢ - يفرق بين الشرط الجزائي في الأعمال والديون.
- ٣ - الافتخار بشمول أحكام الشريعة لهذه القضايا مع حداثتها.
- ٤ - الاعتزاز بشمولية أحكامها لكل المستجدات.





التكليف الفقهي للشرط الجزائي:

اختلف العلماء المعاصرون في التكليف الفقهي للشرط الجزائي ولهم في ذلك اتجاهان:-

الاتجاه الأول: الشرط الجزائي من العقود المسماة له ما يشبهه في الفقه فيخرج عليه ولهم في ذلك تخريجان.

التخريج الأول: أن الشرط الجزائي شبيه بالعربون^(١).

التخريج الثاني: الشرط الجزائي شبيه بالرهن^(٢).

الاتجاه الثاني: الشرط الجزائي ليس من العقود المسماة فهو معاملة مستجدة ليس لها ما يشبهها في الفقه^(٣) وبيان ذلك على النحو التالي.

أولاً: أدلة الاتجاه الأول

التخريج الأول: الشرط الجزائي شبيه بالعربون^(٤).

(١) الوسيط للسنهوري: ٩٠ / ٤، اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الشرط الجزائي مجلة

البحوث الإسلامية ع ٢ ص ١٣٨ والمدخل الفقهي د. الزرقا / ٥٦٥ - ٥٦٦.

(٢) قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة القرار رقم ٢٥، تاريخ ٢١ / ٨ / ١٣٩٤.

(٣) الشرط الجزائي، د. محمد الضير، مجلة مجمع الفقه ع ١٢.

(٤) تعريف العربون: لغة: بفتح العين والراء هو: أن يشتري الرجل شيئاً أو يستأجره ويعطى بعض الثمن أو الأجرة ثم يقول إن تم العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منك، وسمى بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد لثلاً يملكه باشرائه. المصباح المنير ٢ / ٤٠١ شرعاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

صوره: ذكر الفقهاء لبيع العربون صورتين.

الأولى: وهي أن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال على أنه إن أمضى البيع احتسبه من الثمن، وإن



وجه الشبه بين الشرط الجزائري والعربون من وجهين:

الأول: أن كلا منهما تقدير للتعويض، فالشرط الجزائري تقدير للتعويض في حالة الإخلال بالعقد، والعربون تقدير للتعويض في حالة العدول عن العقد.

وبناقش:

بأن قياس الشرط الجزائري على بيع العربون قياس مع الفارق،

والفرق بين الشرط الجزائري وبيع العربون ما يلي:

أولاً: العربون هو المقابل لحق عدول المشتري عن العقد، أما الشرط الجزائري فهو تعويض عن ضرر وقع فعلاً.

ثانياً: العربون يدفع عند عدول المشتري ولو لم يترتب على العدول ضرر؛ لأنه مقابل العدول، أما الشرط الجزائري فلا يستحق إلا إذا وقع ضرر عخمق على الدائن، لأنه تقدير للتعويض عن الضرر.

= لم يمضه أخذ ما دفعه فهذا بيع صحيح والضرر الذي فيه مغتفر.

الثانية: أن يشتري الرجل شيئاً فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئاً على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة وإن لم ينفذ ترك المشتري ذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به. وللفقهاء في هذه الصورة قولان القول الأول: عدم صحة البيع ذهب لذلك جمهور الفقهاء ومنهم المالكية، والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، والزيدية ووافقهم بعض العلماء المعاصرين. القول الثاني: جواز هذه الصورة من بيع العربون وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ورجح العمل به من المعاصرين د. مصطفى الزرقا، د. السنهوري د. وهبة الزحيلي، والراجح القول الثاني وذلك: لما في ذلك من تحقيق مصالح العباد وخاصة أنه لم يثبت النهي عن بيع العربون عن الرسول ﷺ، وعملاً بالعرف. بداية المجتهد ٢/١٦٣ نهاية المحتاج ٣/٤٧٦، الفروع ٤/٦٢، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط (٤)، ٢٠٠٤م، ٥/٣٤٣٥.



ثالثاً: العربون لا يجوز تعديله من القاضي، والشرط الجزائي يجوز تخفيضه وزيادته حتى يكون متناسباً مع الضرر^(١).

الثاني: أن الشرط الجزائي يشبه بيع العربون في أن كلا منهما يوجب على من أخل بالشرط عقوبة مالية^(٢).

ويناقد:

بأن هذا القول إذا صح بالنسبة للعربون؛ فإنه لا يصح بالنسبة للشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي ليس عقوبة، وإنما هو تقدير للتعويض^(٣).

التخريج الثاني: الشرط الجزائي شبيه بالرهن^(٤).

وجه الشبه بين الشرط الجزائي والرهن.

أن الرهن والشرط الجزائي يؤكدان موجب العقد ولا يستقلان عنه؛ لأنهما تابعان.

(١) الشرط الجزائي، د. محمد الضير ١٢ / ٤٩١ الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله ص ١٨٩.

(٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نقلا عن الشرط

الجزائي د. الضير، مجلة المجمع ١٢.

(٣) الشرط الجزائي د. الضير، مجلة المجمع ١٢.

(٤) الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، والرَّهَانُ والمُرَاهَنَةُ المَخاطرة، ويأتي بمعنى الحبس يقال هذا رهنٌ

لك أي دائم محبوس عليك. شرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر

الوفاء حكمه: الرهن مشروع وثبتت مشروعيته بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

فَرِهْتُمْ مَقْبُوضَةً﴾ سورة البقرة / ٢٨٣ وأن النبي ﷺ: (اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا

من حديد) أخرجه البخاري في صحيحه، باب شراء النبي ﷺ ٧٢٩ / ٢ برقم ١٩٦٢. وقد أجمعت الأمة

على مشروعية الرهن، وتعاملت به من لدن عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا، ولم ينكره أحد وحكى

ابن قدامة الإجماع فقال: (لا نعلم خلافا في ذلك، لأنه وثيقة بدين) لسان العرب ١٣ / ١٨٨. نهاية

المحتاج ٤ / ٢٣٣، المغني ٤ / ٣٦٢.



جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء: (أنه ظهر لها أن الشرط الجزائي من الشروط التي تحقق مصلحة العقد، إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته فكان شبيهًا باشتراط الرهن)^(١).

ويناقش:

بأن كون الشرط الجزائي من مصلحة العقد لا نزاع فيه، ولكن تشبيهه بالرهن غير مسلم؛ لأن الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر.^(٢) فظهر أن القياس مع الفارق من عدة أوجه وبيانها على النحو التالي:

أولاً: الشرط الجزائي تعويض عن الضرر فهو مرتبط بوقوع الضرر، خلافاً للرهن الذي لا علاقة له بالتعويض بالضرر.

ثانياً: أن الرهن عين يستوفي منها الدين أو من ثمنها، بينما الشرط الجزائي في غالب الأمر مبلغ مقدر مسبقاً.

ثالثاً: أن الرهن عين معلومة مقبوضة قبل المماطلة في السداد، والشرط الجزائي ليس متقدماً بل ظهوره يكون عند الإخلال بالعقد^(٣).

وبهذا يظهر أن لا يمكن تكييف الشرط الجزائي كعقد رهن.

(١) القرار رقم ٢٥، تاريخ ٢١/٨/١٣٩٤.

(٢) الشرط الجزائي د. محمد الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ١٢.

(٣) الشرط الجزائي وأثره، د. محمد بن عبد العزيز اليماني، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٥-١٤٢٦، ص ١٤٧.



أدلة الاتجاه الثاني: الشرط الجزائي معاملة مستجدة^(١).

وجه كون الشرط الجزائي معاملة مستحدثة:

أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه.

قال ابن القيم: (الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح، فإن الحكم بطلانها حكم بالتحريم والتأثير، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثير إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله،... فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم)^(٢).

الراجح في تخريج الشرط الجزائي:

بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن الشرط الجزائي معاملة مستحدثة وذلك لما يلي:

أولاً: أن الشرط الجزائي إن وجد بينه وبين بعض العقود وجه شبه، فإنها أوجه شبه ظاهرة لا يمكن تكييف الشرط الجزائي عليها.

ثانياً: أن الشرط الجزائي من المعاملات، والمعاملات (الأصل فيها الإباحة) فيباح التعامل به؛ لأن الشروط الجزائية تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى

(١) الشرط الجزائي د. الضير، مجلة المجمع ع ١٢، الشرط الجزائي وأثره، د. محمد اليميني، ص ١٥٩.

(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣٤٤.

والتلاعب بحقوق العباد، وسبب من أسباب الحث على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: الآية (١)].

أنواع الشرط الجزائي وحكمه:

الشرط الجزائي نوعان:

الأول: نوع على التأخير في العمل والتنفيذ.

الثاني نوع على الديون.

وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً: الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال وحكمه

صور الشرط الجزائي على تأخير الأعمال من أهمها^(١):

١ - عقد الاستصناع^(٢): يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان.

٢ - عقد البيع: إذا كان المبيع عيناً له منفعة كالعقارات والآلات، فيجوز

(١) مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السابع بالقرار رقم ٦٥/٣/٧، مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة القرار رقم ٥١/٢/٦، في قرارات المجمع رقم (٤٠-٤١) في دورة مؤتمره الخامس (١٩٩٨م)

(٢) الاستصناع في اللغة: طلبُ صنْعِ الشيء وعمله لأنه غير موجود. لسان العرب مادة صنع. وهو في الاصطلاح الفقهي: عقد على مبيع في الذمة يُطلب عمله. بدائع الصنائع ٢/٥ وعقد الاستصناع مما انفرد الحنفية في القول به، وفي تسميته "الفقهية"، وميزوه عن عقد السلم في كون الشيء مستصنعاً من آدمي كالأواني، والأسلحة، والأحذية، لا كونه موجوداً بخلق الله تعالى وإيجاده كالحبوب.



للمشتري أن يشترط على البائع إذا لم يسلم المبيع في الوقت المحدد، فعليه كذا عن كل يوم تأخير.

٣- الاعتماد المستندي: تشترط المصارف إذا ألغى العميل استيراد البضاعة، وقد فتح له البنك اعتمادا وفي حالة الإلغاء أن يتحمل العميل تكاليف فتح الاعتماد.

٤- عقد الشركة والإجارة: إذا أدخل الشريك أو الأجير في استمرارية العقد واشترط المؤجر عليه شرطا جزائيا وجب الشرط الجزائي على المشروط عليه إذا لحق الشرط ضررا.

٥- عقود التوريد: وذلك بتقديم المواد الأولية للمصانع كالحبوب الغذائية للمصانع الغذائية، ولوازم الدوائر الحكومية والشركات والمعامل والمدارس والملابس العسكرية للثكنات... يجوز الشرط الجزائي على المشروط عليه إذا لحق الشرط ضررا فعليا بسبب إخلال أو إهمال المشروط عليه.

٦- عقود النقل وعقود العمل ما دام الشرط لا يخالف الشرع، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا^(١).

٧- الشرط الجزائي المقترن بعقد المقاول، المتضمن دفع مبلغ محدد عن كل يوم، أو شهر من التأخير عن الموعد المحدد للتنفيذ والتسليم.
ب- حكم الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال.

اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ولهم في ذلك قولان.

القول الأول: يرى من ذهب إليه جواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ

(١) الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، إعداد الدكتور ناجي شفيق عجم، جامعة الملك عبد العزيز - جدة، مجلة المجمع ١٢ع.

الأعمال ذهب لذلك بعض من العلماء المعاصرين وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المنعقدة ما بين ٥ - ٢٢ / ٨ / ١٣٩٤، قرار دار الإفتاء المصرية، فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي^(١).

القول الثاني: يرى من ذهب إليه عدم جواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال ذهب لذلك بعض من العلماء المعاصرين^(٢).

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

الكتاب والسنة والآثار والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ الآية [المائدة: الآية (١)].

وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب الوفاء بالعقود، والشرط الجزائي سبب من أسباب الوفاء بالعقود.

أما السنة: فعن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال للمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حراماً حلالاً، أو أحل حراماً^(٣).

(١) قرار هيئة كبار العلماء قرار رقم (٢٥) بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٣٩٤ هـ.

(٢) الشرط الجزائي د. السالوس مجلة مجمع الفقه ١٢ / ٥٢٧، الشرط الجزائي مجلة مجمع الفقه د. التسخير ١٢ / ٨١، أحكام عقود التأمين للشيخ محمود آل زيد ص ٧٥، مصادر الحق ٦ / ١٦٨، الضمان للشيخ على الخفيف ص ١٧، النظريات الفقهية د. الدريني ص ١٩٦، النظرية العامة للالتزام د. شفيق شحاته ص ٩١.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح



وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب التزام المسلمين بشروطهم، والشرط الجزائي شرط من الشروط فكان تنفيذه مباحا.

أما الأثر فمنه:

١ - عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقه فقال عمر المسلمون عند مشارطتهم عند مقاطع حدودهم^(١).

٢ - عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ رَجُلٌ لِكُرَيْبٍ: (٢): أَزْجِلُ رِكَابَكَ (٣) أَزْجِلُ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَأْتِهِمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ» (٤).

٣ - عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الْأَرْبَعَاءُ فَلَيْسَ بَيْنِي

= بين الناس ج ٣ ص ٢٨ رقم ١٣٥٢. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح - يُراجع: جامع الأصول في أحاديث الرسول ج ٢ ص ٦٣٩.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، ٢ / ٩٨١، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الشرط في النكاح، ٦ / ٢٢٧.

(٢) لكريه: الذي أكرهه والمكاري الذي يؤجر الدواب للسفر.

(٣) ركابك: الإبل التي يسافر عليها.

(٤) ووجه ذلك: أن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع تاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيا للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف بالوعد. فتح الباري ٥ / ٣٢٤. (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، ج ٣ ص ١٩٨).



وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ»^(١).

وجه الدلالة:

دلت الآثار بمجموعها على مشروعية الشرط الجزائي لوجوب التزام المسلمين بشروطهم.

أما المعقول فمن أوجه:

الأول: أن الأصل في الشروط الصحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً^(٢).

الثاني: أن الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له^(٣).

أدلة القول الثاني:

السنة والمعقول.

أما السنة فمنها.

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)^(٤)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، ج٣ ص ١٩٨.

(٢) قرار هيئة كبار العلماء قرار رقم (٢٥) وتاريخ (٢١/٨/١٣٩٤هـ).

(٣) المرجع السابق.

(٤) أخرجه الترمذي في سننه أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ج٢ ص ٥٢٤ برقم



وجه الدلالة:

دل الحديث على النهي عن بيع بيعتين في بيعة^(١)، والشرط الجزائي من قبيل ذلك لأنه اشتمل على بيعتين في بيعة واحدة.

وبناقش:

بأن الاستدلال غير مسلم: لأن الشرط الجزائي ليس من قبيل بيعتين في بيعة، فليس من قبيل "بعثك على أن تقرضني أو تزوجني أو تؤجرني"؛ لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلاً عن العقد الأصلي بخلاف الشرط الجزائي فإنه لا يقع مستقلاً^(٢).

٢- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ «نهى عن بيع وشرط»^(٣)

وجه الدلالة:

دل الحديث صراحة على النهي عن بيع وشرط في بيعة، والشرط الجزائي من قبيل ذلك؛ لأنه اشتمل على بيع وشرط فيكون فاسداً.

= ١٢٣١. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. يُراجع: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ج٢ ص٢١٧.

(١) تحفة الأحوذى ٤/٣٥٨.

(٢) الشرط الجزائي د. الرويشد ص٦١٨.

(٣) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، باب العين، باب من أسمه عبد الله، ج٤ ص٣٣٥ برقم ٤٣٦١.

قال الحافظ: أخرجه الطبراني من هذا الوجه وهو غريب. يُراجع: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ج٣ ص١١٨٦.



٣- عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما)^(١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على هدم مشروعية الشرط الذي يحل حراما، والشرط الجزائي يحل الربا المحرم فكان محرما.

أما المعقول:

فإن الشرط الجزائي يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد، وزيادة منفعة مشروطة لأحد المتعاقدين تكون ربا؛ لأنها زيادة لا يقابلها عوض، والعقد الذي فيه ربا أو شبهة الربا فاسد لأن شبهة الربا كحقيقته^(٢).

الراجع:

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم أرى - والله أعلم - أن القول الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال، وذلك لما يلي:

١ - لقوة أدلتهم، وضعف دليل القول المخالف.

٢ - يحقق ضمانا لعاقدي العقود، أو التي يتعهدون بها، مخافة نكول أحدهم عما عقد عليه أو التزمه أو تعهد به.

(١) سبق تخريجه.

(٢) دراسات ميسرة في قضايا معاصرة د. علي محمد قاسم ص ٢٦٣.



٣- الشرط الجزائي يحقق مصلحة، ويسد أبواب الفوضى، والتلاعب بحقوق العباد، وإلحاق الضرر بهم.

٤- عملاً بقوله ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) فمفهوم الضرر عام وشامل لكل ما يتأذى به المرء في كل حقوقه التي كفلها له الشارع.

٥- جريان العرف بالتعامل بالشرط الجزائي والعادة محكمة، وإذا كان الأمر كذلك، ولم يكن في هذا الشرط ما يوجب تحريمه من رباً، أو ظلم، أو ميسر، فلا وجه لتحريمه، بل هو جائز وصحيح.

وبهذا القول جاء نص قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: ١٠٩ (٣/ ١٢) بشأن موضوع الشرط الجزائي إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م)

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

ومما قرره ما يلي:

ثالثاً: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترباً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح



وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط - مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

ولا يجوز - مثلاً - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاتته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادساً: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعاً: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه).

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجرى اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر ويجب.

*** كما نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٥) وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢١هـ على**

ما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد ،،،

فبناءً على ما تقرر في الدورة الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فيما



بين ٢٨/١٠، ١٤/١١/١٣٩٤ هـ من الرغبة في دراسة موضوع الشرط الجزائي فقد جرى إدراجه في جدول أعمال الهيئة في دورتها المنعقدة فيما بين ٥، ٢٢/٨/١٣٩٤ هـ في مدينة الطائف.

ثم جرت دراسة الموضوع في هذه الدورة بعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي ومناقشته وتوجيه قياسه على تلك المسائل والإيراد عليه. فقد قرر الأخذ بالشرط الجزائي ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقطاً لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ وبقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار). والله أعلم.





ملخص قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فقد جاء فيه

ما نصه.

(وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدود له، والاستئناس بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: أدخل ركابك فإن لم أر حل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتاك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى عليه.

وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع. وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة.



ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ وبقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم^(١).

الشرط الجزائي على التأخير في سداد الديون:

العقود التي يكون الالتزام فيها بالشرط الجزائي ديناً ثلاثة:

أولاً: عقد القرض.

ثانياً: عقد البيع بالتقسيط.

ثالثاً: عقد السلم.

وقبل بيان حكم الشرط الجزائي في الديون أعرض بصورة موجزة حقيقة الدين والمدين، وصور الشرط الجزائي في الديون وذلك على النحو التالي:

حقيقة الدين والمدين.

الدين لغة: دان الرجل (يدين) (ديناً) من المداينة وأيضاً (دان) الرجل إذا استقرض فهو (دائن)^(٢).

(١) مجلة البحوث الإسلامية ٢/ ١٤٠ - ١٤٢.

(٢) المصباح المنير ١/ ٢٠٥.



اصطلاحاً: الدين لزوم حق في الذمة^(١).

فالمال الثابت في الذمة يسمى ديناً، سواء كان بدلاً من: مبيع أم من قرض، أم من مال أهلكه أو استهلكه، أو كان التزاماً مالياً أثبتته الشرع كالمهر^(٢) أو اقتضته الضرورة مع نية الرجوع على المتتفع، وأكثر ديون المصارف الإسلامية ناتجة عن البيوع الآجلة: كبيع المrabحة بالتقسيط، والسلم، والقرض الحسن، ويسمى مستحق المال الثابت في ذمة الآخر دائناً، ومن ثبت في ذمته المال مديناً، والمال الثابت ديناً^(٣).

المدين: وهو إما أن يكون المدين معسراً أو موسراً.

أما المعسر: وهو الشخص الذي لا يجد ما يقضي به دينه عديماً كان أو ممن يضر به الأداء^(٤).

واتفق الفقهاء^(٥) على وجوب إنظار^(٦) المعسر استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ

(١) فتح الغفار شرح المنار ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٥٥هـ، ٣/ ٢٠.

(٢) صيانة المديونيات، د. محمد عثمان شبير ص ٨٤٠، الشرط الجزائي في الديون، د. علي محمد الحسين الصوا،

<http://www.islamfeqh.com>.

(٣) الشرط الجزائي في الديون، د. علي محمد الحسين الصوا،

<http://www.islamfeqh.com>.

(٤) قوانين الأحكام الشرعية، ص ٣٣٢، ٣٣٣.

(٥) المبسوط ٢٤/ ١٦٤؛ الحاوي ١٥/ ٨٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٨.

(٦) ضابط الإعسار: أن لا يكون له مال فائض عن حوائجه الأصلية يفني به دينه. د. رفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٧/ ٦٤٣.



كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿٢٨٠﴾ [من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة].

ولحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قال له بكل يوم صدقة قبل ان يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة) (١).

وأما الموسر: وهو المدين القادر على الوفاء ولكنه يماطل فهو ظالم لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ) (٢) ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) (٣).

تعريف الشرط الجزائي في الديون وخصائصه:

ويعرف الشرط الجزائي في الديون: بأنه اتفاق مقترن بعقد، يحدد بموجبه العاقدان مسبقاً مبلغاً من المال، عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه. -كفرض غرامة على سداد دين مثل أقساط بيع سيارة ونحو ذلك.

خصائص الشرط الجزائي في الديون.

من خصائص الشرط الجزائي في الديون ما يلي:-

(١) أخرجه أحمد في المسند، ٥/ ٦٣٠. قال الهيثمي روى ابن ماجه طرفا منه. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٤/ ١٣٥.

(٢) مطل: المطل التسويف وعدم القضاء. (الغني) المتمكن من قضاء ما عليه.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم مطل الغني، ٥/ ٣٤، برقم (٤٠٨٥).



١ - الشرط الجزائي تقدير جزافي لمبلغ من المال، عن ضرر قد يلحق بالدائن عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه، وقد يكون المبلغ أكبر من الضرر، أو مساوياً له، أو أقل منه^(١).

٢ - الشرط الجزائي في الديون: اتفاق بين الدائن والمدين في ذات العقد أو في عقد لاحق، يرتب على المدين عند إخلاله بالتزامه دفع مبلغ مالي يحدده العاقدان بعد وقوع الضرر^(٢).

حكم الشرط الجزائي في الديون:

يختلف حكم الشرط الجزائي في الديون تبعاً لصوره وفي ذلك مسألتان.

المسألة الأولى:

أن يكون مبلغ الشرط مستحقاً عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه دون أن يتوقف ذلك على شريطة أخرى، كأن يقول: إذا لم يوفه دينه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا من المال، ولا خلاف بين الفقهاء على تحريم هذا الشرط وأنه مبطل للعقد لأن ذلك ربا صريح، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَاؤَ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٠].

دلت الآية على تحريم الزيادة على أصل الدين قال ابن العربي: (إن الناس في

(١) الوسيط د. السنهوري ٢/ ٨٥٢.

(٢) الشرط الجزائي د. الرويشد ص ١٢١.



الجاهلية كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفا يبايع الرجل الرجل إلى أجل. فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلا آخر. فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة^(١).

وأما السنة: فحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة)^(٢) وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع^(٣) (٤).

قال النووي: (في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها، وقوله في الربا إنه موضوع كله، معناه الزائد على رأس المال، كما قال تعالى ﴿وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال)^(٥).

أما الإجماع:

فقد حكى الإجماع ابن عبد البر فقال: (أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو: أن يأخذ الدائن لتأخير دينه بعد حلوله عوضاً عينياً أو عرضاً، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي وإما أن تربي)^(٦).

(١) الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١ سنة ٢٠٠٠، ٦/ ٤٨٨.

(٢) أي الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء.

(٣) كل ربا الجاهلية موضوع أبطله النبي ﷺ وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه ربا عباس بن عبد المطلب ﷺ غنياً يرابي فوضع النبي ﷺ رباة كله.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة الوداع ٤/ ٣٩ برقم ٣٠٠٩.

(٥) شرح صحيح مسلم ٨/ ١٨٢.

(٦) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢١.



وقال النووي: (أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر)^(١).

ولا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريم الشرط الجزائي مقابل التأخير في سداد الديون: إذا كان مبلغ الشرط مستحقاً عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه، دون أن يتوقف ذلك على شريطة أخرى^(٢).

وقد صدرت عدة فتاوى شرعية صادرة عن المصارف الإسلامية، تؤكد حرمة الشرط الجزائي على الديون، وتعهده ربا نسيئة^(٣).

وقد نص قرار: مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، على تحريم الشرط الجزائي في الديون وعدم صحته في القرار الثامن، حيث

(١) المجموع ٩/ ٤٤٢.

(٢) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، عدد (٢) مجلد (٢)، ص ٩٥، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، عدد (١) مجلد (٣)، ص ١١٢ سنة ١٤٠٥ هـ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، عدد (١) مجلد (٣)، ص ١١٢ سنة ١٤٠٥ هـ. منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المدين المماطل، د. زكي الدين شعبان، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٤٤، ص ٢٢، ٢٣، المعاملات المالية المعاصرة د. وهبة الزحيلي، ص ١٧٨، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي الشيخ الزرقاء مجلد (٢) عدد (٢)، ص ١٥٤. نظرية الالتزام في الشريعة والتشريعات العربية، عبد الناصر العطار، ص ٢٣١، ٢٣٢، د. علي جمعة جريدة الراية القطرية. نقلا عن د. على الصوا، الشرط الجزائي في الديون.

<http://www.islamfeqh.com>

(٣) الفتاوى الشرعية، ج ٢، ص ١٦، طبعة سنة ١٩٩٤ م، الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ج ١، إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة.. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية مصرف قطر الإسلامي، فتوى رقم (١٨). فتاوى هيئة الرقابة الشرعية، بنك فيصل الإسلامي المصري، فتوى رقم (١٤). هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان، نقلا عن د. على الصوا، الشرط الجزائي في الديون.



جاء فيه: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة في الفترة من يوم الأحد ١٣ إلى ٢٠ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق من ١٩ إلى ٢٩ فبراير ١٩٨٩ م، قد نظر في موضوع السؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟". الجواب: "وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه".

المسألة الثانية: أن يتضمن العقد شرطاً يلزم المدين المماطل بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً.

ويثار تساؤل: هل يحق للبنوك أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد توقيع شرط جزائي أو غرامة التأخير في حالة التأخير عن سداد الديون في المدة المحددة لسداد الدين أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة ولهم في ذلك قولان.

القول الأول: يرى من ذهب إليه جواز اشتراط الشرط الجزائي عن الضرر الواقع فعلاً، وإلزام المدين المماطل بالوفاء به^(١).^(١) ذهب لذلك د. مصطفى

(١) ولكن بشرط نص في العقد بأن هذه الغرامة سوف تصرف في وجوه الخير وهذا يؤصل فقهيًا بالتزام الشخص بالتبرع طوعاً فيكون ملزماً بما التزم به وهذا مبني على رأي للمالكية أجازوا الالتزام

الزرقاء، د. الصديق الضير، د. عبد الله بن منيع، وأفتى به علماء لجنة الفتوى في المصرف الإسلامي الدولي بمصر، ولجنة الفتوى في مجموعة دلة البركة الفتوى، كما صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حيث جاء فيها ما نصه: (فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له^(٢)). كما أجازت التعويض التأخيري: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية^(٣).

القول الثاني: يرى من ذهب إليه تحريم^(٤) الشرط الجزائي عن الضرر الواقع فعلا في الديون، وبه قال الشيخ على الخفيف، د. زكي الدين شعبان، د. نزيه حماد،

= بالتطوع والخير، د. على القرعة داغي، حكم غرامات التأخير، <http://www.qaradaghi.com>

(١) صيانة المديونيات، محمد شبير، ص ٨٦٣، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد (٢)، مجلد (٢)، ص ٩٧، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد ١٠ مجلد ٣، ص ١١٢، أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت ٣٠-٣١ أكتوبر ١- نوفمبر ١٩٩٥م، ص ٢٢٣، ٢٣٨، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد ١٠ مجلد ٣، ص ١١٢، أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت ٣٠-٣١ أكتوبر ١- نوفمبر ١٩٩٥م، ص ٢٢٣، ٢٢٨، المصرف الإسلامي الدولي - مصر - فتوى رقم ٣، ٤، أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مجلد ١، ص ٢١٤. دار أولي النهى - الرياض، ط ٢ سنة ١٩٩٢م.. نقلا عن الشرط الجزائي د. علي الصوا، <http://www.islamfeqh.com>.

(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مجلد ١، ص ٢١٤. دار أولي النهى - الرياض، ط ٢ سنة ١٩٩٢م.

(٣) معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية والإسلامية ص ١٧١.

(٤) أيدهم في ذلك من الاقتصاديين د. رفيق المصري، د. عبد الناصر العطار.



د. محمد شبير، د. وهبة الزحيلي^(١).

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

السنة والأثر والمعقول.

أما السنة فممنها:-

١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (مطل الغني ظلم)^(٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المدين المماطل ظالم، فهو بامتناعه عن سداد الدين مع القدرة عليه كالغاصب فوجب تحمله الشرط الجزائي عند المماطلة في السداد^(٣).

ويناقش:

بأن الأصول الشرعية تقضي بأن أخذ المال لا يكون إلا تبرعاً، أو في مقابلة مال، وإلا كان أكلاً له بالبطل؛ لأن أصل التعويض في نظر فقهاء الشريعة هو مقابلة

(١) الضمان في الفقه الإسلامي، الشيخ علي الخفيف ص ١٩، ٢٠، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، دار القلم - دمشق ط ١، ٢٠٠١، ص ٣٥١، المعاملات المالية المعاصرة د. شبير، ٢، ٨٧٣ نقلاً عن الشرط الجزائي د. علي الصوا،

<http://www.islamfeqh.com>

(٢) سبق تخريجه.

(٣) لجنة الفتوى في المصرف الإسلامي الدولي سابقا. المصرف المتحد حالياً.



المال بالمال^(١).

٢- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قَالَ «لِيُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ»^(٢) وَعُقُوبَتَهُ»^(٣).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المدين الغني المماطل ظالم يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة لفظ يشمل: الحبس والضرب ونحو ذلك، فيقاس على ذلك الغرامة المالية.

وتناقش جهة الاستدلال بالحديث بما يلي:

أن مقصود قوله ﷺ "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" أي شكايته وحبسه لا تغريمه بالمال؛ لأن التغريم من الربا الحرام وهو ربا النسيئة^(٤)

قال النووي: "قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني وعقوبته الحبس والتعزير"^(٥).

(١) الضمان، الشيخ علي الخفيف، ص ٢٠.

(٢) يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته يحبس له.

(٣) ذكره البخاري تعليقا في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، ج ٣ ص ١١٨ / واخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة ج ٢ ص ٨١١ برقم ٢٤٢٧. قال

الحاكم: هذا الحديث صحيح. يُراجع: البدر المنير ج ٦ ص ٦٥٦.

(٤) صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠/ ٢٢٧.

(٥) المعاملات المالية المعاصرة د. وهبة الزحيلي ص ١٧٩.



٣- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قضى أن (لا ضرر ولا ضرار)^(١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على النهي عن الضرر والضرار، ومطل الغني يضرّ بالبنك الدائن ضرراً كبيراً حيث يحبس ماله عن الاتجار فيه، لذلك يمكن أن يؤخذ بالغرامة المالية لمنع هذا الضرر، لأن القاعدة تقضي بأن الضرر يزال، وإزالة هذا الضرر إنما يتحقق بالتعويض عنه وذلك يتم عن طريق الغرامة المالية^(٢).

وبناقش:

بأن وجه الاستدلال غير مسلم: - لأن قواعد إزالة الضرر هي العموم الذي لا يتعارض مع أساس الشريعة القائم على منع الربا، وإن تضرر الدائن^(٣).

أما الأثر: فعن ابن سيرين: أن رجلاً قال لكرّيه: أرّجل ركابك، فإن لم أرّجل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح "من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه"^(٤).

أما المعقول فمن أوجه.

الأول: تعويض الدائن عن ضرره الناتج عن التأخير مبدأ مقبول شرعاً؛ لأنه

(١) سبق تخريجه.

(٢) تأصيل غرامة التأخير والشرط الجزائي، موقع ملتقى أهل الحديث:

www.ahlalhddeeth.com.

(٣) المعاملات المالية المعاصرة د. وهبة الزحيلي ص ١٧٩.

(٤) سبق تخريجه.



لا ينافي نصوص الشريعة ومقاصدها العامة^(١).

الثاني: قياس وجوب تضمين المدين على تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة^(٢)، إذ لكل منهما مال أزيلت عنه يد مالكة بغير حق^(٣).

ويناقش: بأن هناك فروقاً جوهرية بين النقود وبين الأعيان من عدة أوجه من أهمها: أن الأعيان يمكن الاستفادة من منافعها كالسكنى في العقارات والركوب في الحيوانات ولذلك يجوز تأجيرها بمال، ولكن النقود ليست لها منافع بذاتها، ولذلك لا يجوز تأجيرها.

الثالث: أن الشرط الجزائي في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع، وفي القول بصحة الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، وسبب من أسباب الحث على الوفاء بالعقود^(٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز الشرط الجزائي في الديون بالسنة والمعقول.

(١) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد (٢)، مجلد (٢)، ص ٩٧.

(٢) ذهب لذلك جمهور الفقهاء وخالفهم الحنفية في ذلك.

(٣) تأصيل غرامة التأخير والشرط الجزائي، www.ahlalhddeeth.com

(٤) أبحاث هيئة كبار العلماء، ١/ ٢١٤.



أما السنة فأحاديث منها:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة)^(١)

وجه الدلالة:

دل الحديث على النهي عن بيع بيعتين في بيعة، والشرط الجزائي من قبيل ذلك لأنه اشتمل على بيعتين في بيعة واحدة.

ويناقش:

بأن الاستدلال غير مسلم: لأن الشرط الجزائي ليس مستقلا عن العقد الأصلي، وإنما هو من قبيل الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط.

٢- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ (نهى عن بيع وشرط)^(٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث دلالة صريحة على النهي عن بيع وشرط؛ لأنه بيع فاسد؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن، والنهي يقتضي تحريم المعاملة ولما كان الشرط الجزائي تابعا للعقد؛ فإنه يكون منهى عنه.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.



ويناقدش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث في إسناده مقال، قال ابن حجر: "واستغربه النووي وقال غريب^(١)".

الوجه الثاني: أن اجتماع البيع والشرط يؤدي إلى الربا أو الغرر، واشتراط الشرط الجزائي لا يترتب عليه ذلك؛ لأن الشروط الصحيحة التي لا يؤدي اجتماعها مع البيع إلى ربا أو غرر، فإنها تبقى صحيحة ويصح معها العقد^(٢).

أما المعقول:

فإن الشرط الجزائي نوع من أنواع ربا النسيئة المحرم، لأنه يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد، وزيادة منفعة مشروطة لأحد المتعاقدين ربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض^(٣).

ويناقدش من وجهين:

الأول: أن هناك فرق بين الشرط الجزائي والفائدة الربوية منها:

١ - أن الفوائد الربوية مثبتة في البداية، فالمدين يدفع الزيادة على أصل الدين ولو لم يتأخر، أما الشرط الجزائي فيدفع عند التأخير والمماطلة في السداد.

٢ - أن الفوائد الربوية تلزم المدين مطلقاً سواء كان معسراً أو موسراً، أما الشرط الجزائي فلا يلزم إلا عند المماطلة إذا كان المدين موسراً.

(١) التلخيص الحبير لابن حجر ٣/ ٣٢.

(٢) الشرط الجزائي، د. علي السالوس، مجلة مجمع الفقه ١٢٤.

(٣) دراسات ميسرة في قضايا فقهية معاصرة، د. علي محمد قاسم ص ٢٦٣.



وأجيب: بأن هذه الفروق ليست جوهرية وغير مؤثرة في الحكم الشرعي.

الثاني: أن الفوائد الربوية في المداينات تعقد من البداية، فتكون طريقاً استثمارياً أصلياً يلجأ إليها المرابون، مما يخل بالتوازن الاقتصادي بين العاقلين، بخلاف الشرط الجزائي، فإنه ليس طريقاً استثمارياً، وإنما هو إعادة لتوازن العقد الأصلي الذي أحل به المدين المماطل^(١).

الراجع:

بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم يبدو لي - والله أعلم - أن الرأي الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون بتحريم الشرط الجزائي في الديون وذلك لأن: الشرط الجزائي في الديون ربا؛ لأن كل زيادة في الدين مشروطة هي ربا صريح، ولأن مشكلة تأخر الديون ليست وليدة عصرنا، بل كانت موجودة، ومع ذلك لم ينقل إلينا أن أحداً أجاز اشتراط الزيادة على الديون، والبدائل الشرعية كثيرة^(٢).

(١) الحكم على المدين المماطل بالتعويض، منشور بمجلة الاقتصاد ص ٩٦، صيانة المديونيات، د.

محمد شبير، ص ٨٧٢.

(٢) وضع الإسلام تدابير وضمانات عديدة لحفظ أموال الدائنين من مماطلة المدينين، وذلك من غير حاجة إلى التعامل بغرامة تأخير وفاء الدين، لما فيها من أضرار ومفاسد ومن البدائل ما يلي: إنظار المدين إذا كان معسراً، تعاون البنوك الإسلامية فيما بينها في المعلومات المتوافرة عن المستثمرين والاتفاق على جعل المدين المماطل في القائمة السوداء، إشهار اسم المماطل في وسائل الإعلام، الأخذ بالوسائل الفنية للجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة، أخذ ضمانات كافية من الكفالة والرهن ونحوهما. غرامة تأخير وفاء الدين وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الستار أبو غدة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة <http://www.fiqhia.com.sa>، دراسة فقهية لغرامات التأخير والبدائل د.



وهذا الرأي صدر به قرار المجمع رقم ٥١ (٦/٢)، ومما جاء فيه:

- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء.
- وجاء في القرار نفسه في الفقرة الخامسة: "يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخير المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد".
- كما أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١-٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ، ١-٦ نيسان (إبريل) ١٩٩٥م القرار رقم ٨٥/٢/٩ بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة جاء فيه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عن التأخير".

-





ملخص الموضوع:

- ١- الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له، وذلك عن الضرر الفعلي الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.
- ٢- الشرط الجزائي من العقود المستحدثة، والأصل في العقود الجواز، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه.
- ٣- أن الشرط الجزائي لا يستحق إلا إذا تحققت شروط استحقاق التعويض.
- ٤- يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض، إذا وجدت مبرراً لذلك.
- ٥- الشرط الجزائي نوعان نوع على التأخير في الأعمال وهو جائز بضوابط. النوع الثاني على التأخير في الديون وهو محرم لا يجوز العمل به. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





نماذج أسئلة:

س١: اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي للشرط الجزائي وضحي ذلك مع ذكر الأدلة وبيان الرأي الراجح.

س٢: عرفي الشرط الجزائي؟ ثم أذكر أدلة من قال بعدم جواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال مع المناقشة وبيان القول الراجح في المسألة؟

س٣: اختلف الفقهاء المعاصرون في توقيع الشرط الجزائي عن الضرر الواقع من التأخير في سداد الديون وضحي ذلك مع ذكر الأدلة والمناقشة وبيان الرأي الراجح في المسألة؟

س٤: أكمل مكان النقط:

١- من العوامل التي ساعدت على العمل بالشرط الجزائي.....،.....،.....

٢- الشرط الجزائي هو.....

٣- الراجح في الشرط الجزائي أنه من العقود.....

٤- الشرط الجزائي نوعان نوع على التأخير في..... وهو.....

ونوع في التأخير في..... وهو.....

س٥: عيني الصواب مع تصحيح الخطأ وتعليل الصواب:

١- الشرط الجزائي لا يطبق إذا كان مبالغاً فيه.



- ٢- للقاضي سلطة في تعديل الشرط الجزائي.
- ٣- من صور الشرط الجزائي على تأخير الأعمال عقد الرهن
- ٤- الراجع في الشرط الجزائي في الديون التحريم
- ٥- التعويض المستحق بسبب الشرط الجزائي لا يكون إلا إذا ثبت الضرر

س٦ اختاري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١ - من أسماء الشرط الجزائي
(التعويض الاتفاقي - البند الجزائي - جميع ما سبق).
- ٢ - ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
(الشرط - التوريد - المزايدة).
- ٣ - من التكييف الفقهي للشرط الجزائي
(شبيه بعقد الاستصناع - شبيه بعقد الإجارة - شبيه بعقد الرهن)
- ٤ - من العقود التي يكون الالتزام فيها بالشرط الجزائي ديناً
(عقد القرض - عقد البيع بالتقسيط - عقد السلم - جميع ما سبق).





المراجع:

- ١ - أبحاث الشرط الجزائي منشورة بمجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد الرابع عشر.
- ٢ - أبحاث هيئة كبار العلماء، ١، ٢١٤.
- ٣ - الحكم على المدين المماطل بالتعويض، مجلة الاقتصاد.
- ٤ - دراسات ميسرة في قضايا فقهية معاصرة، د. علي محمد قاسم.
- ٥ - قرارات المجمع رقم (٤٠-٤١) في دورة مؤتمره الخامس (١٩٩٨م)
- ٦ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة السادسة والسابعة ج ٢/ قرار رقم ٦٥ (٣/٧).





الموضوع الثالث: الإجارة المنتهية بالتمليك

ويحتوي على ثلاث وحدات:



الوحدة الأولى:

مدخل لدراسة عقد الإجارة المنتهية بالتملك:

أهداف الوحدة الأولى:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - التعرف على مفهوم عقد الإجارة ومشروعيته.
- ٢ - الوقوف على مفهوم الإجارة المنتهية بالتملك، وما يطلق عليها من مصطلحات.
- ٣ - ذكر نشأة هذا العقد، مع توضيح الفرق بين هذا العقد وغيره من بعض عقود المعاملات المالية مثل البيع بالتقسيط
- ٤ - إيضاح مزايا عقد الإجارة المنتهية بالتملك.





بسم الله الرحمن الرحيم

الوحدة الأولى:

مدخل لدراسة عقد الإجارة المنتهية بالتملك

تمهيد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى رحمة للناس وآتاه الحكمة وجوامع الكلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فإن من نعم المولى ﷺ علينا أن هدانا لدينه فأتمه وأكمله، فما من قضية أو نازلة إلا ولها في شريعتنا حكما.

لذلك فقد اتجه العلماء المعاصرون إلى بحث العقود المستجدة من وجهة نظر الفقه الاسلامي ووضعوا لها من الشروط والضوابط التي تتوافق مع قواعد الشريعة في تحقيق المصالح العامة نافية لكل ظلم أو فساد، ومن هذه العقود الإجارة المنتهية بالتملك، والتي أفادت المؤسسات الإسلامية من مشروعيتها وذلك باتخاذها كآلية من آليات النشاط الاقتصادي الذي تقوم به تلك المؤسسات لصالح الشركات والأفراد الذين لا يملكون السيولة المالية لتملك ما يحتاجون إليه من معدات وأجهزة، إضافة إلى ما في هذا العقد من مزايا لكل من المؤجر وهو البائع والمستأجر وهو المشتري؛ مما يدل على أن غرض المتعاملين بهذا العقد لا يتحقق في البيع



بالتقسيط.

منهج البحث:

تقتضي طبيعة البحث استخدام المنهج الاستدلالي والاستنباطي: الذي يقوم على الاستقراء من خلال ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال السلف والأئمة وأقوال المعاصرين في هذا الموضوع:

والله الموفق ،،،

أولاً: تعريف الإجارة:

الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، والفعل: أجر يأجر، ولها معنيان:

الأول: الكراء على العمل.

والثاني: جبر العظم الكسير، فيقال أجزت يده والمعنى الجامع بينهما: أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله^(١).

جاء في التعريفات: أن الإجارة عقد على المنافع بعوض هو مال، أو تمليك المنافع بعوض إجارة وبغير عوض إعارة^(٢).

(١) لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ، مقاييس اللغة ج ١ ص ٦٢-٦٣.

(٢) التعريفات ص ٢٣.



الإجارة شرعاً:

- عرف الحنفية الإجارة: بأنها عقد على المنفعة بعوض هو مال^(١).
- وعرفها المالكية: بأنها تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض^(٢).
- وعرفها الشافعية بقولهم: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم^(٣).
- وعرفها الحنابلة: بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم^(٤).

من خلال تعريفات الفقهاء للإجارة يتضح ما يلي:

- أن تعريف الحنفية للإجارة قد جاء خالياً من عدة قيود:
- أولهما: كون المنفعة مباحة.
- ثانيهما: مدة الانتفاع معلومة.
- ثالثهما: كون الأجرة معلومة.
- أما تعريف المالكية فقد جاء خالياً من قيد كون المعوض معلوماً.
- أما تعريف الشافعية فقد جاء مقيداً بكون المنفعة مقصودة أي ليست بتافهة.

(١) المبسوط ج ١٥ ص ٧٤.

(٢) حاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢.

(٣) أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٠٣.

(٤) شرح منتهى الإرادات ج ٣ ص ٦٤.



أما تعريف الحنابلة فأرى أنه تعريفًا جامعًا: فقد جاء شاملاً لنوعي الإجارة وهى إجارة المنافع وإجارة الأعمال، كما شمل إجارة العين المرئية، والعين الموصوفة في الذمة، وإن جاء خالياً من قيد كون المنفعة مقصودة أي منفعة ليست بتافهة.

ثانياً: مشروعية الإجارة:

ثبتت مشروعية الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول:

أما الكتاب فأيات منها ما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَأْتِبِ اسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَ أَلْقَوِىَ الْآمِينَ﴾ (٦) (١).

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

ذكر المولى ﷺ أن نبيناً من أنبيائه ﷺ أجر نفسه حججاً مسماة يملك بها بضع امرأة، فدل ذلك على جواز الإجارة؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ (٢). فدل ذلك على أن الإجارة بينهم وعندهم مشروعية وهى كذلك في كل ملة، فهى من ضرورات الخليقة (٣).

(١) سورة القصص آية ٢٦.

(٢) الإمام الشافعي: أحكام القرآن ج ١ ص ٢٦٥، د/ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٥ ص ٤٥٣.

(٣) الإمام ابن العربي: أحكام القرآن ج ٣ ص ٤٩٤.



٢- قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾^(١).

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

دلت الآية الكريمة على جواز الإجارة ففى قوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ دليل على جواز الإجارة على الرضاع مع جهالة مقدراه حيث إنه يختلف بكثرة إرضاع المولود وقلته، وكثرة لبن المرضعة وقلته، لكن لما جازت الإجارة عليه، جازت الإجارة على ما هو مثله وما هو في معناه^(٢).

٣- قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾^(٣).

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

دلت الآية الكريمة على مشروعية الإجارة، ففى قوله تعالى: ﴿سُخْرِيًّا﴾ أي ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم ويستخدمهم في مهنتهم ويسخروهم في أشغالهم حتى يتعاشوا^(٤).

٤- قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٥).

(١) سورة الطلاق آية ٦.

(٢) الإمام الشافعي: أحكام القرآن ج ١ ص ٢٦٣، الحاوي الكبير ج ٧ ص ٩٤٣.

(٣) سورة الزخرف آية ٣٢.

(٤) الألوسي: روح المعاني ج ٢٥ ص ٧٨.

(٥) سورة البقرة آية: ٢٣٣.



وجه الدلالة من الآية الكريمة:

في الآية الكريمة نفى المولى ﷺ الجناح عمن يسترضع لولده ظئراً، وفي قوله تعالى ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي إذا سلمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف^(١) وفي هذا دليل على مشروعية الإجارة.

٥ - قال تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٧٧) (٢).

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

دلت الآية الكريمة على جواز الإجارة، وهي سنة الأنبياء^(٣).

أما السنة فأحاديث منها:

١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)^(٤) وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف: دل ظاهر الأمر الرسول

(١) الماوردي: النكت والعيون ج ١ ص ١٧٢.

(٢) سورة الكهف آية: ٧٧.

(٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ١١ ص ٣٢.

(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الأحكام - باب أجر الأجراء - ج ٣ ص ٥١١ برقم (٢٤٤٣)، وعلق

عليه: شعيب الأرناؤوط بقوله: حسن لغيره، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وله شاهد قوي من حديث أبي هريرة، وفي كشف الخفاء ج ١ ص ١٤٣: رواه ابن ماجه بإسناد جيد عن

ابن عمر وأبو يعلى عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ﷺ في الحديث بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل، على جواز الإجارة^(١).

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»^(٢)

٣- عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ (وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا)^(٣) وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ^(٤).

٤- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ)^(٥).

(١) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٧٤.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجارة - باب إثم من منع الأجير - ج ٣ - ص ٩٠ - برقم (٢٢٧٠).

(٣) الخريت: الدليل الحاذق بالدلالة. المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٦٦.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجارة - باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام - ج ٣ - ص ٨٩ - برقم (٢٢٦٤).

(٥) المرجع السابق - كتاب الطب - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم - ج ٧ - ص ١٣٢-١٣٣، برقم



وجه الدلالة من هذه الأحاديث الشريفة:

دل ظاهر الأحاديث السابقة من قول الرسول صلى الله عليه وفعله على جواز الإجارة ومشروعيتها.

أما الإجماع: فقد نقله ابن قدامة في المغني، والكاساني في البدائع وغيرهم، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذئ سبق في الأعصار وسار في الأمصار^(١).

قال الكاساني في البدائع: فان الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضى الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير فلا يعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع^(٢).

أما القياس: فهو قياس عقد الإجارة على عقد البيع فلما جاز العقد على الأعيان وجب جواز العقد على المنافع؛ لأن حاجة الناس إلى المنافع كحاجتهم إلى الأعيان^(٣).

أما المعقول: فلأن كل واحد لا يكون له داراً مملوكة يسكنها أو أرضاً مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن، ولا بالهبه

= (٥٧٣٧).

(١) المغني ج ٦ ص ٥.

(٢) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٧٤.

(٣) المغني ج ٦ ص ٥.



والإعارة؛ لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإعارة فجوزت، لأن التشريع الإسلامي، شرع لكل حاجة عقداً يختص بها فشرع لتمليك العين بعوض عقداً وهو البيع، وشرع لتمليكهها بغير عوض عقداً وهو الهبة، وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقداً وهو الإعارة، فلو لم يشرع الإعارة مع مساس الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلاً، وهذا خلاف موضوع الشرع^(١).

ثالثاً: أنواع عقد الإعارة: ينقسم عقد الإعارة باعتبار المعقود عليه إلى نوعين:

النوع الأول: عقد الإعارة الوارد على منافع الاعيان:

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إعارة العقار كالدور والأراضي.

القسم الثاني: إعارة العروض كالملابس والأواني.

القسم الثالث: إعارة الدواب.

كما ينقسم عقد الإعارة الوارد على منافع الاعيان إلى:

أ- إعارة على أعيان مرئية حيث يشترط فيها ما يشترط لصحة عقد البيع.

ب- إعارة أعيان موصوفة في الذمة حيث يشترط لها ما يشترط للسلم^(٢) بأن

(١) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٧٤.

(٢) أما عن شروط المسلم فيه: أن يكون معلوم الجنس كحنطة أو شعير أو تمر، والنوع: كحنطة سقية أو



لوصف بما لضبطها حتى لا يقع تنازع بين المتعاقدين^(١).

النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على الأعمال مثل: استئجار أصحاب الحرف والصنائع، كإعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل، فإن كان الثوب من عند الخياط كان عقد استصناع.

وينقسم إلى: أ- أجير خاص وهو الذى يعمل لواحد.

أ- أجير مشترك وهو الذى يعمل لعامة الناس.



= نحسبة، وإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع، وأن يكون معلوم الصفة: كجيد أو وسط أو رديء، ومعلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضيه إلى المنازعة ومفسدة للعقد. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ٢٠٧.

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ١ ص ٤٥٢-٤٥٣، شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٥٢ وما بعدها، كشف القناع ج ٣ ص ٥٦١ وما بعدها.

المبحث الأول:

في تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتملك
مع بيان ما يميز هذا العقد عن غيره

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: في تعريف الإجارة المنتهية بالتملك وما يطلق عليه من
مصطلحات

المطلب الثاني: نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتملك.



المطلب الأول: في تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وما يطلق عليه من مصطلحات

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يعتبر من العقود المعاصرة لم يكتب عنه أحد من الفقهاء المتقدمين، بينما كتب فيه كثير من العلماء المعاصرين وفيما يلي بيان لمفهوم هذا العقد:

أولاً: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

أ- باعتبار مفرداته

قد سبق تعريف عقد الإجارة أما تعريف التمليك فكما يلي:

التمليك لغة: مصدر ملك: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، والملك: هو كل ما يملك من مال^(١).

والملك اصطلاحاً: هو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه وحاجزاً عن تصرف غيره فيه^(٢).

وعرفه القرافي: بأنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من

(١) مقاييس اللغة ج ٥ ص ٣٥١-٣٥٢.

(٢) التعريفات ص ٢٩٥.



يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك.

شرح التعريف: أما القول بأنه حكم شرعي فبالإجماع ؛ ولأنه يتبع الأسباب الشرعية، وأما إنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع ، والتعلق عديمي ليس وصفاً حقيقياً ، بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المفيدة للملك، وقولنا في العين أو المنفعة فإن الأعيان تملك كالبيع والمنافع كالإجارات.^(١) والتملك قد يكون للعين وقد يكون للمنفعة، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض، فإذا كان بغير عوض فهو هبة، وإذا كان تملكاً للعين بعوض فهذا بيع، وإذا كان تملكاً لمنفعة بعوض فهذه إجارة، وإذا كان تملكاً للمنفعة بغير عوض فهذه عارية^(٢).

ب- مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك باعتباره مصطلح مركب:

١- هي عقد إجارة يقترن بها وعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثنائها.

٢- بأنه عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجر معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد^(٣).

ويمكن أن يعرف بأنه: عقد تملك لمنفعة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تملك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم.

(١) أنوار البروق في أنواع الفروق ج ٣ ص ٢٠٨-٢٠٩.

(٢) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٥ ص ٣٧٥.

(٣) الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ص ٧ نقلاً من د / خالد الحافي: الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي ص ٦٠.



ثانياً: المصطلحات التي تطلق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يطلق على هذا العقد عدة مصطلحات منها ما يلي:

- البيع الإيجاري.
- الإيجار السائر للبيع.
- الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
- الإيجار المقترن بوعء بالبيع^(١).



(١) د/ فهد الحسنون: الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ص ١٥، ٢١.



المطلب الثاني:

نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتملك

نشأ هذا العقد في إنجلترا عام ١٨٤٦م وأول من تعامل به تاجر للآلات الموسيقية كان يؤجر آلاته إجارة يتبعها تملك، ثم انتقلت الفكرة من الأفراد إلى الشركات والمصانع، فعمل بالفكرة شركة سنجر لآلات الخياطة حيث كان يتم التعامل مع العملاء عن طريق عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين يمثل في حقيقته ثمنًا لها، ثم تطور هذا العقد، وما لبث أن تزايد مما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونية، وذلك منذ بداية هذا القرن، فقد تناولته فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع، أو البيع الإيجاري، أو الإيجار المملك، وذلك عند شرحهم للمواد القانونية الخاصة به مثل المادة (٤٣٠) من القانون المدني المصري، ثم انتقل بعد ذلك إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية والتي جعلت هذا العقد جزءاً من العمليات الأساسية التي تقوم بها، ومن البنوك الإسلامية التي طبقت هذا العقد - بنك ماليزيا الإسلامي - ، كما قام - بنك مصر إيران للتنمية - بالاشتراك مع هيئة سوق المال بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بمثل هذا النشاط، وذلك بالاستعانة بهيئة التمويل التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير نظراً لخبرتها في هذا المجال، وعلى أثر النتائج الإيجابية لهذه



الدراسة قام بنك مصر إيران بتأسيس أول شركة تأجير مالي في مصر بالاشتراك مع هيئة التمويل الدولية وشركة مانوفاكتشورز ليسينج الأمريكية^(١).



(١) د/ ياسر بن طه: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي ص ١٣٠، د/ سعد بن عبدالله السبر: الإيجار المنتهئ بالتملك ص ١٢ نقلاً من بحث د/ القره داغي: ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ج ١، الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي نقلاً من البيع بالتقسيط والبيع الائتمانية الأخرى د ابراهيم دسوقي ص ٣٢-٣٤، د/ خالد الحافي: الإجارة المنتهية بالتملك ص ٦٢-٦٥.

المبحث الثاني:

الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتملك
وبين بعض عقود المعاوضات مع مزايا هذا العقد

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتملك وبين عقدي
البيع والإجارة التشغيلية والبيع بالتقسيط
المطلب الثاني: مزايا عقد الإجارة المنتهية بالتملك.



المطلب الأول:

الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك وبين عقدي البيع والإجارة التشغيلية والبيع بالتقسيط

أولاً: أهم الفروق بين عقدي البيع والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك كما يلي:

- ١ - أنهما من العقود اللازمة، إلا أن عقد البيع وارد على العين ومنفعتها، بحيث يملك المشتري العين ومنفعتها، بينما عقد الإجارة تنتقل فيه ملكية المنفعة فقط للمستأجر في مدة العقد دون العين حيث تبقى على ملك المؤجر^(١)..
- ٢ - أن عقد الإجارة لا يلتزم فيه المستأجر بشراء العين، بل يمكنه إنهاء العقد بغير أي تبعات مالية.
- ٣ - لعل من أهم الفروق ما يتعلق بمسألة المخاطر وتحمل نفقاتها حيث هي من مسؤولية المؤجر بدون خلاف.
- ٤ - أن مدة الإجارة التشغيلية قد تقصر إلى حد كبير عن العمر الإنتاجي للأصل، وقد تصل إلى عمر الأصل.
- ٥ - أن الأعيان المؤجرة في الإجارة التشغيلية تعود إلى حيازة البنك المؤجر بعد

(١) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ١ ص ١١٠، الفواكه الدواني ج ٢ ص ٧٣، المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ٢٠٧، شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٦٣.



انتهاء مدة العقد، ويبدأ البنك بالبحث عن مستخدم آخر يرغب في استئجار العين، ويتميزها الأسلوب بأن المالك يتحمل مخاطر ركود السوق وانخفاض الطلب على تلك الأعيان مما يؤدي إلى خطر عدم استغلالها.

أهم ما يتميز به عقد الإجارة المنتهية بالتملك عن عقدي البيع والإجارة ما يلي:

١- يعتبر عقداً مركباً يجمع بين الإيجار والوعد بالبيع، في بعض صورته. ٢- يلتزم فيه المستأجر بسداد الأقساط المتفق عليها وإذا لم يتمكن من ذلك قد يتعرض لخسارة ما دفعه؛ لأن هذه الأقساط قد تتضمن جزءاً من ثمن السلعة.

٢- نفقات الصيانة هي من مسؤولية المستأجر.

٣- أن هذا العقد في معظم صورته ينتهي بتملك المستأجر للعين سواء من خلال الوعد أو العقد، وسواء كان ذلك بغير ثمن محدد بعد الأقساط أو بثمن محدد رمزياً أو حقيقياً، أو يحدد حسب سعر السوق عند انتهاء الإجارة، أو من خلال منح المستأجر الحق في اختيار الشراء أو عدمه بانتهاء مدة الإيجار.

٤- أن مدة الإيجار قد تصل أو تقارب العمر الإنتاجي للسلعة^(١).

٥- بعد انتهاء مدة العقد تنتقل العين إلى ملكية المستأجر في أغلب صورها^(٢).

ثانياً: الفرق بين الإجارة المنتهية بالتملك والبيع بالتقسيط:

(١) د/ سعد بن ترك الخثلان: المعاملات المالية المعاصرة ص ١٢١. د/ شوقي دنيا: الإجارة

المنتهية بالتملك دراسة اقتصادية وفقهية بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي ج ١٢ ص ٣٩٠.

(٢) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، مجموعة دلة البركة،

ص ٢٠٩، ٢١٠.



١ - البيع بالتقسيط عقد تنتقل فيه ملكية العين إلى المشتري بمجرد إبرام العقد، وله حرية التصرف في المبيع على أن يتم سداد الثمن على أقساط وهو عقد واحد لا يتجدد بانتهاء الأقساط، وهذا بخلاف الإجارة المنتهية بالتملك فلا تنتقل الملكية إلا بعد انتهاء الإجارة وإبرام عقد التملك^(١).

٢ - في البيع بالتقسيط تعتبر الأقساط ديناً لازماً في ذمة المشتري بعد إبرام العقد، أما في الإجارة المنتهية بالتملك تعد دفعات الإجارة ديوناً غير مستقرة إلا بعد التمكن من استيفاء المنفعة.

٣ - في البيع بالتقسيط تثبت ملكية البائع بعد البيع للدين الذي في ذمة المشتري، ولذا لا يجوز بيع هذا الدين ولا تصكيكه؛ لأنه من تداول الديون بينما في الإجارة المنتهية بالتملك تبقى ملكية المؤجر للأعيان المؤجرة ولذا يجوز تصكيكه هذا الحق^(٢).



(١) د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) ص ٣٩٥-٣٩٦.

(٢) د/ يوسف الشبيلي: دورة عقد التأجير التمويلي، ص ٩.



المطلب الثاني:

مزاي عقد الإجارة المنتهية بالتملك

ما يحققه التأجير المنتهي بالتملك من مزاي:

يحقق عقد الإجارة المنتهي بالتملك العديد من المزايا سواء بالنسبة للمستأجر أو للمؤجر أو للاقتصاد القومي، وذلك على النحو:

بالنسبة للمستأجر:

يحقق الإيجار المنتهي بالتملك بصيغته المقبولة الكثير من المزايا بالنسبة للمستأجر، وأهمها ما يأتي:

١- حيازة المستأجر للأصل والاستفادة منه بالرغم من عدم قدرته على دفع الثمن نقداً.

٢- عدم الحاجة إلى تجميد جزء كبير من رأس ماله وذلك في حالة قدرته على السداد مما يحسن مركز السيولة لديه.

٣- يعمل على اقتناء معدات حديثة قد لا تتوافر للمستأجر إمكانية شرائها لضعف الموارد الذاتية لديه، أو عدم القدرة على الاقتراض.

٤- يقدم أسلوب التأجير المنتهي بالتملك تمويلاً كاملاً للأصول المستأجرة، إذ أنه لا يتطلب أن يدفع المستأجر جزءاً من ثمنه مقدماً.

٥- تفادى القيود التي تلتزم بها البنوك في تمويلها للمشروعات أو إقراضها، وهو يعد أسلوب تمويلي أفضل من الاقتراض بالفوائد الربوية المحرمة.

٦- عدم التعرض لمخاطر التمويل عن طريق الاقتراض.

٧- أنه يحقق ميزة مهمة للمستأجر وهو تجنب الضرائب التي قد تفرض على بعض الملاك في بعض الأنظمة، إذ يعمل على أن تكون الضرائب منخفضة بأكبر قدر ممكن، حيث يتم خصم قيمة الأقساط الإيجاري من أرباح المستأجر وصولاً إلى صافي الربح الخاضع للضريبة.

٨- عدم إرهاب المستأجر بالديون، إذ في حالة التأجير لا تظهر قيمة الأصل في ميزانية المستأجر، وإنما تنعكس عملية التأجير مالياً في حساب الأرباح والخسائر فقط حيث تمثل الأقساط إحدى بنود المصروفات، وهذا على العكس فيما إذا اقترضت الشركة لشراء هذا الأصل فعندئذ تظهر قيمة الأصل في جانب الأصول من الميزانية، وتظهر المبالغ المقترضة في جانب الخصوم، وهذا يؤثر على النسب التحليلية المستخرجة من المركز المالي.

بالنسبة للمؤجر:

يحقق الإيجار المنتهي بالتملك بصيغته المقبولة الكثير من المزايا بالنسبة للمؤجر، وأهمها ما يأتي:

١- يحمل هذا الأسلوب المستأجر كل تكاليف الصيانة اللازمة للمحافظة على الأصول المؤجرة مع تحمل تكلفة التأمين.

٢- يحتفظ من خلال هذا العقد بحق الرقابة بحيث يمكنه استرجاع الأصل في



- حالة عدم سداد المستأجر لباقي الأقساط أو عند الإخلال ببعض شروط التعاقد.
- ٣- عدم مزاحمة الغرماء في العين المؤجرة في حالة إعسار المستأجر فتعود له العين ولا تدخل ضمن ما يملكه المستأجر حتى تدخل في المحاصة
- ٣- توفر شروط التعاقد في التأجير المنتهي بالتمليك مرونة كبيرة بين المؤجر والمستأجر بحيث يمكن للمؤجر اختيار العميل الذي تتوافق احتياجاته مع طبيعة الخدمة التي يقدمها المؤجر.
- ٤- بتمليك المعدات المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط يوفر على المؤسسة المالية كثيراً من التكاليف فيما لو كانت هذه المعدات تحتاج إلى تفكيك وإرجاع إليها.

بالنسبة للاقتصاد القومي:

- تحقق الإجارة المنتهية بالتمليك العديد من المزايا بالنسبة للاقتصاد القومي ، ومن أهمها ما يأتي:
- ١- إتاحة الأصول والمعدات عن طريق هذا العقد مما يساعد على إنشاء مزيد من المشروعات الانتاجية في البلاد، أو على تبنى الوحدات القائمة بمشروعات للتوسع، وهذا له أثره البارز في احداث التنمية الاقتصادية.
- ٢- زيادة فرص تشغيل العمالة في المجتمع ، وهو ما يحد من البطالة.
- ٣- التعجيل بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية^(١).

(١) د/ سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهي بالتمليك ص ١٥، نقلاً من: بيع التقيسيط للتركي ص (١٩٤)، د/ محي الدين القره داغي، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني



الوحدة الثانية:

في ذكر صور الإجارة المنتهية بالتملك
مع بيان بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها
التكييف الفقهي لتلك الصور

أهداف الوحدة الثانية:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن:

١ - فهم واستيعاب صور هذا العقد.

٢ - الإلمام ببعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها التكييف الفقهي لتلك الصور، وتتمثل تلك المسائل: في اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد - نفقات الصيانة والتأمين - بيع العين المؤجرة للمستأجر - وحكم الوفاء بالوعد.



= عشر، دكتور عصام أبو النصر: دور صيغة الإيجار المنتهي بالتملك (في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة) ص ٨.



الوحدة الثانية:

صور الإجارة المنتهية بالتملك مع بيان بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد

أولاً: صور عقد الإجارة المنتهية بالتملك:

للإجارة المنتهية بالتملك صور عديدة نذكر منها ما يلي:

الصورة الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر - إذا رغب المؤجر في ذلك - مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالِكاً للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.

ويمكن صياغة هذا العقد على النحو التالي:

أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر أو عام هي كذا لمدة ثلاث سنوات مثلاً، على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الثلاث، كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات، ويقول الآخر قبلت.

فالعقد في هذه الصورة إجارة تنتهي بتملك العين دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية المتفق عليها^(١).

(١) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهي بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد =



الصورة الثانية: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل دفع مبلغ هو كذا.

ويمكن تصور صياغة هذا العقد على النحو التالي:

أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر أو عام هي كذا، لمدة ثلاث سنوات - مثلاً - على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في المدة المحددة بعتك هذه السلعة إذا رغبت في ذلك بثمان هو كذا، ويقول الآخر قبلت.

من خلال عرض تصور لصياغة العقد في هذه الصورة نجد أن العقد اشتمل على إجارة للعين في المدة المحددة ثم بيعها في نهاية المدة بثمان إما رمزي أو حقيقي.

والثمان إذا كان رمزياً فإنه قد روعي فيه عند الاتفاق على الأقساط الإيجارية أنها تعادل في مجموعها ثمن السلعة الحقيقي مع ما أضيف إليه من ربح، وقد وضع هذا الثمن رمزياً لهدفين:

الأول: إظهار الاتفاق بأنه كان في البداية عقد إجارة.

الثاني: أنه في النهاية عقد بيع.

ولا شك بأن العقد في هذه الصورة قد اشتمل على عقدين، وإذا كان الثمن حقيقياً فهي صورة جمعت بين عقدين أيضاً:

= الخامس، د/ فهد بن علي الحسون: الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص ١٢.



الأول: عقد ناجز وهو عقد الإجارة، اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده عقد البيع.

الثاني: عقد بيع معلق على شرط^(١).

الصورة الثالثة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً - إذا وفي المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة - ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين.

ويمكن تصور صياغة العقد على النحو التالي:

أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر - أو عام - هي كذا لمدة ثلاث سنوات مثلاً، وأعدك وعداً ملزماً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، ويقول الآخر قبلت^(٢).

فالعقد بهذه الصورة هو إجارة مقترنة بوعد بالبيع.

الصورة الرابعة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد وعداً ملزماً بهبة العين للمستأجر إذا وفي بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة في نهاية العقد.

(١) د/ فهد بن علي الحسون: الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص ١٢، د/ أحمد نصار: عقد الإجارة فقهاً وتطبيقاً ص ٢٢، د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهي بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس.

(٢) الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص ١٩، سعد بن عبد الله السبر: التأجير المنتهي بالتملك ص ١٣-١٤ نقلاً من الإيجار المنتهي بالتملك للشاذلي. والإجارة تطبيقاتها المعاصرة للقرعة داغى ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس، الثاني عشر.



ويمكن تصور صياغة هذه الصورة بأن يقول المؤجر: أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر مثلاً هي كذا لمدة ثلاث سنوات مثلاً، وأعدك وعداً ملزماً بهبة العين لك إذا وفيت جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، ويقول الآخر قبلت، فالعقد في هذه الصورة إجارة مقترنة بوعد بهبة العين^(١).

الصورة الخامسة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، مع وعد ملزم من المؤجر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور:

الأول: تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي دفعها المستأجر كأقساط للإجارة. وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.

الثاني: مد عقد الإجارة لفترة أخرى.

الثالث: إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها^(٢)

نجد أن عقد الإجارة في هذه الصورة مقترن بوعد التخير بالتملك أو مد مدة الإجارة أو إعادة العين المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها.



(١) د/ سعد بن عبد الله السبر: التأجير المنتهي بالتمليك ص ١٤، د/ فهد بن علي الحسون: الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ص ١٩.

(٢) الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ص ١٣، التأجير المنتهي بالتمليك ص ١٤ نقلاً من بحث للدكتور حسن علي الشاذلي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي جدة - الدورة الخامسة ٤/ ٢٦١٣ - ٢٦١٧، د/ خالد الحافي: والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي ص ٦٦ - ٧٠.



ثانياً: بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد ومنها ما يلي:

أولاً: حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد

قبل البدء ببيان حكم عقد الإجارة المنتهية بالتملك يلزم بحث بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد فإذا عرف الحكم في هذه المسائل تبين التكيف الفقهي الصحيح لهذا العقد:

وذلك بأن يتراضى العاقدان على إبرام معاهدة تشتمل على عقدي البيع والإجارة بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما جملة واحدة، أي بمثابة آثار العقد الواحد.

وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على رأيين:

الرأي الأول: يرى جواز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد سواء كان محل العقد واحداً أو مختلفاً بثن واحد وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المالكية^(١) عدا سحنون، وأصح القولين عند الشافعية^(٢)، والمذهب عند الحنابلة^(٣)، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٤).

بينما اشترط ابن القاسم في مذهبه وروايته عن مالك: أن جواز اجتماع البيع

(١) شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤.

(٢) المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ٣٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥١.

(٣) الإنصاف ج ٤ ص ٣٢١.

(٤) مجموع الفتاوى ج ٢٩ ص ٦٢.



والإجارة في عين واحدة في إجارة الأعمال، وعلى منافع ما يعقل: أن يعرف وجه خروج هذا العمل - على أي وجه كان من كونه رديئاً أو جيداً، بأن كان المستأجر متقناً في صنعه فيخرج جيداً، أو لا فيخرج رديئاً -، أو لا يعرف وجه خروجه، ولكن يمكن إعادته - أي كما كان إن لم يرضى به المؤجر -^(١).

الرأي الثاني: يرى عدم جواز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد، وقول الحنفية^(٢)، والشافعية في وجه^(٣)، ورواية للحنابلة^(٤)، ووافقهم سحنون من فقهاء المالكية فيما إذا كان محل العقد واحداً، في الإجارة على الأعمال، أما إذا كان محل العقد مختلفاً جاز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد سواء كانت الإجارة على منافع أو أعمال^(٥).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء في حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد إلى التردد في فهم حديث "النهي عن بيعتين في بيعة" بين العمل بمفهومه أو العمل بظاهره، فمن حمّله على معنى أعمق من معناه الظاهر ذهب إلى الجواز، ومن حمّله على ظاهره ذهب إلى منع اجتماع العقود في صفقة واحدة^(٦).

(١) شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤ د / حسن الشاذلي: الإيجار المنتهئ بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٦٠٢.

(٢) المبسوط للسرخسي ج ١٢ ص ١٩٦.

(٣) المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ٣٨٨، السيوطي: الأشباه والنظائر ص ١٥١.

(٤) الإنصاف ج ٤ ص ٣٢١.

(٥) منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤٤٣.

(٦) د/ أحمد فخري: حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة. موقع دار



الأدلة والمناقشة:

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بالمعقول من عدة أوجه:

الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه، وإبطاله نص أو قياس^(١).

الثاني: أن الأصل في العقود رضى المتعاقدين ونتيجته هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد.

الثالث: أن البيع والإجارة كل منهما عقد يصح إفراده فصح جمعهما^(٢).

الرابع: أنه ليس في اجتماع العقدین أكثر من اختلاف حكمهما، وهذا لا يمنع صحة العقد، ونقسم العوض عليهما^(٣).

أدلة الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول:

= الافتاء الاردنية.

(١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ٤ ص ٧٩، مجموع الفتاوى ج ٢٩ ص ٣٢.

(٢) المغنى والشرح الكبير ج ٤ ص ٥٢.

(٣) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٠ ص ٣٤٧.



أما السنة فأحادث منها:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)^(١)، أي صفقة واحدة وفي عقد واحد.

٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)^(٢).

وجه الدلالة من هذين الحديثين الشريفين: دل ظاهر الحديث على أن اشتراط عقد في عقد آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عيناً أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد به العقد. وفي الحديث أنه ﷺ (نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) وهذا منه^(٣).

نوقش الاستدلال بهذين الحديثين من عدة أوجه:

الأول: أن المراد من نص الحديث هو أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن التبرع إنما كان لأجل المعاوضة^(٤).

الثاني: أن المراد من بيعتين في بيعه: أن يملك الرجل السلعة بثمانين عاجل وآجل.

(١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعه - ج ٣ - ص ٥٢٥ - برقم (١٢٣١)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح - كتاب البيوع - باب بما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - ج ٣ - ص ٥٢٧ - برقم (١٢٣٤). قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

(٣) المقدسي: الكافي في فقه ابن حنبل ج ٢ ص ٢٢.

(٤) مجموع الفتاوى ج ٢٩ ص ٦٢ - ٦٣.



الثالث: أن الحديث لا يؤخذ على ظاهره؛ لأن الأصل في العقود الإباحة، فبقي أصل اجتماع العقود على الإباحة ما لم يؤد إلى مآل ممنوع^(١).

وأما المعقول فمن عدة أوجه:

الأول: أن اشتراط الإجارة مع البيع يتضمن زيادة منفعة مشروطة في عقد البيع وهي زيادة لا يقابلها عوض، فهي ربا أو فيها شبهة الربا وبالتالي فهو فاسد.

الثاني: أن اشتراط عقد في عقد آخر لا يقتضيه أحدهما، قد تضمن منفعة تجوز المطالبة بها، فصار في ذاته عقد آخر - إجارة أو إعارة أو بيعاً - تضمنه عقد البيع^(٢)؛ لأنه إذا كان بعض البدل في مقابلة العمل المشروط عليه فهو إجارة مشروطة، وإن لم يكن في مقابلة العمل شيء فهو إعارة مشروطة في البيع وهذا مفسد للعقد^(٣).

الثالث: لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل فيهما؛ وذلك لأن البيع فيه خيار ولا يشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يفسخ العقد بتلف العين، بخلاف الإجارة حيث يفسخ العقد فيها بتلف العين^(٤).

نوقش ذلك: بأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما ليس فيه فإنه يصح مع اختلاف حكمهما فيجوز اجتماع

(١) د/ أحمد فخري: حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة. موقع دار الافتاء الاردنية.

(٢) مجلة البحوث الاسلامية العدد الثاني ج ٢ ص ١١١.

(٣) المبسوط ج ١٥ ص ٢٨٧.

(٤) الكافي في فقه أحمد ج ٢ ص ٢٠.



عقد البيع، والإجارة سواء كان محل العقد واحداً أم مختلفاً^(١).

الراجع:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد أرى- والله أعلم - رجحان الرأي الأول القائل بالجواز: لما فيه من التيسير على الناس في معاملاتهم ولقوة ما استدلووا به، وبالتالي فاذا ترجح اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد فانه يشترط لذلك:

١ - تحديد مدة الإجارة.

٢ - الشروع في العمل كخياطة الثوب، أو الشروع في العمل حكماً كتأخيرته ثلاثة أيام.

٣ - العلم بصفة العمل أي خروجه على أي وجه كان من كونه جيداً أو رديئاً^(٢).

لكن هل اجتماع عقد إجارة على عين مع عقد بيع على هذه العين الواحدة المؤجرة معلق على الوفاء بكامل ثمن المنفعة يصح قياساً على ذلك، أم لا يصح؟ إن الصورة التي ذكرها الفقهاء هنا هي إجارة بآلة ناجزة، وبيع بات ناجز ليس معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل على محلين مختلفين، ومن ثم فلا يصح القياس على ذلك؛ لأن هذه العقود لا تقبل عندهم التعليق على شرط ولا الإضافة إلى أجل^(٣).

(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٠.

(٢) شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤، الانصاف ج ٧ ص ٣٤٣.

(٣) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهي بالتمليك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس.



كما أن الضوابط التي ذكرها الفقهاء هي في الإجارة على العمل، فلا يلزم تحققها في الإجارة المنتهية بالتملك^(١).

ثانياً: حكم إلزام المستأجر نفقات الصيانة والتأمين.

اتفق الفقهاء^(٢) على أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، فإذا تلفت العين بلا تعد أو تقصير لم يضمنها.

لما روي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: (لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ)^(٣).

ولأن العين المؤجرة قبضها المستأجر ليستوفي منها منفعتها فلم يضمنها بالقبض.

كما اتفق الفقهاء^(٤) على أنه لا يجوز للمؤجر اشتراط الضمان على المستأجر وإلا كانت الإجارة فاسدة.

والعلة التي من أجلها ذهب الفقهاء إلى القول بفساد الإجارة إذا اشترط على المستأجر ضمان العين: هو أن تكاليف هذا الضمان مجهولة، فقد يتكلف الكثير أو

(١) د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة.

(٢) بدائع الصنائع ج ٤ ص ٢١٠، التاج والإكليل ج ٧ ص ٥٣٦، أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٢١، تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٩، المغني ج ٦ ص ٥٣.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب وضع الجوائح - ج ٣ - ص ١١٩٠ - برقم (١٥٥٤).

(٤) المدونة" ج ٣ ص ٤٥٠، المغني ج ٥ ص ٣١١.



القليل من المال، أو لا يتكلف شيئاً، وذلك حسب الأعطال التي قد تحصل للعين، وهذه جهالة مفسدة للعقد، لأن من شروط صحة العقود العلم بالأجرة المدفوعة.

فقد جاء في "الموسوعة الفقهية ما يدل على ذلك: "ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر، لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب"^(١)

بينما خالف في ذلك الزيدية^(٢) حيث ذهبوا إلى أن المستأجر ضامن للعين المؤجرة عملاً بقول الرسول ﷺ فيما رواه سمرة: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَ)^(٣).

ولأن المستأجر لها رضي لنفسه الانتفاع بالعين فكان هذا الرضا الصادر منه محللاً لماله الذي دفعه في ضمانها ولا حجر في مثل هذا^(٤).

وبناءً على ما قال به جمهور الفقهاء من أن ضمان العين المؤجرة على المالك لها فقد ذهب أكثر العلماء المعاصرون إلى: أن نفقات الصيانة غير التشغيلية، والتأمين للعين في عقد الإجارة المنتهية بالتملك لا تجب على المستأجر، وإنما تجب على المؤجر سواء كان مصرف أو شركة فهو مطالب بالإبقاء على العين المؤجرة بحالة يستطيع معها المستأجر استيفاء منافعها، وللمؤجر أن يوكل المستأجر

(١) الموسوعة الفقهية ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) السيل الجرار ص ٥٧٤.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب البيوع - باب ما جاء في أن العارية مؤداة - ج ٣ - ص ٥٥٨ - برقم (١٢٦٦)، وقال: هذا حديث حسن.

(٤) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص ٥٧٤.



للقيام بذلك ثم يخصم ذلك من قيمة الأجرة، ولا مانع أن يزيد في الأجرة لتغطية تلك النفقات، أما إذا قام به المستأجر دون إذن من المؤجر فهو في ذلك يعتبر متبرعاً^(١).

بينما أجازا كل من د/ منذر قحف^(٢)، د/ محي الدين القره داغي^(٣): اشتراط ضمان العين المؤجرة ونفقات الصيانة الجوهرية والتي تتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين على المستأجر عند التعاقد؛ لأنه شرط لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة بحيث يكون الشرط جزءاً من التعاقد، وإن كان الأفضل والأحرى أن يخصم المبلغ من الإجارة، خروجاً من الخلاف، أما ما هو غير معلوم من نحو نفقات إصلاح كجدار أو سقف انهدما فإنه لا يصح اشتراطه على المستأجر؛ لأنه يدخل جهالة في مقدار الأجرة مما يفسد العقد.

كما أن ما يتعلق بنفقات التأمين إذا كانت معلومة فهي ما يجوز اشتراطه على المستأجر واعتباره جزءاً من الأجرة؛ لأن التأمين التعاوني قائم على التبرع؛ ولا بأس

(١) د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة ص ٤٠٣، علي محيي الدين القره داغي: الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، (الإجارة المنتهية بالتملك)، د/ محمد جبر الألفي: الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد ١٢، د/ محمد عبدالله بربكان: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك - دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية - رسالة ماجستير - جامعة الشرق الأوسط - كلية الحقوق - قسم القانون الخاص ص ٨٢، د/ حامد عبدالله العلي/ تيسير بعض أحكام البيوع ص ٥٥.

(٢) د/ منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة - مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر نقلاً من المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات. حسين حامد حسان. بحث غير مطبوع.

(٣) د/ القره داغي: الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، (الإجارة المنتهية بالتمليك) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر.



بتبرع غير المالك.

وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير معتمداً ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر، وجاء في قرار آخر للمجمع بأن الصيانة التي يتوقف عليه استيفاء المنفعة تلزم المؤجر، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، بخلاف الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عُينت تعييناً نافياً للجهالة^(١).

ثالثاً: حكم بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر:

لا خلاف بين الفقهاء^(٢) على صحة بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر مستدلين على ذلك بما يلي:

أولاً: أن العين المؤجرة في يد المستأجر لا حائل دونها فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب؛ لأن الملك بالشراء لا ينافي الإجارة^(٣).

ثانياً: أن ملك الرقبة حق خالص للبائع، وعقد الإجارة ورد على المنفعة فلا يمنع من بيع الرقبة^(٤).

(١) قرار رقم: ١١٠ (٤/١٢)، والصادر في دورة انعقاده الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م).

(٢) مواهب الجليل ج ٧ ص ٥٢٣، تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٧، المغنى ج ٦ ص ٥٣، السيل الجرار ص ٤٨٧.

(٣) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨.

(٤) شرح منتهى الإرادات ج ٤ ص ٦٢.



بينما اختلف الفقهاء في أثر ذلك على عقد الإجارة على رأيين:

الرأي الأول: ذهب إلى أن عقد الإجارة لا يفسخ بل يستوفي المستأجر المنفعة بالإجارة إلى انتهاء مدتها، ثم يملكها بعقد البيع، فإن تلفت المنافع قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت ورجع المشتري بالأجرة لما بقى على البائع وهذا قول للمالكية^(١)، والشافعية في الأصح^(٢)، ورواية للحنابلة^(٣). بينما اشترط المالكية لجواز ذلك: أن يبقى من مدة الإجارة ما لا يكون غرراً يخاف تغييرها في مثله^(٤).

الرأي الثاني: يرى فسخ الإجارة فيما بقي من المدة، ويسقط عن المشتري الأجر فيما بقي من مدة الإجارة ويحسب من الثمن وهذا ما ذهب جمهور الفقهاء الحنفية^(٥) وبعض المالكية^(٦)، والشافعية في وجه^(٧)، والحنابلة في رواية^(٨).

الأدلة:

دليل الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بالمعقول من وجهين:

-
- (١) القوانين الفقهية ص ١٨٣.
 - (٢) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨.
 - (٣) المقدسي: الكافي ج ٢ ص ١٧٧، المغنى ج ٦ ص ٥٣، الإنصاف ج ٦ ص ٣.
 - (٤) المعونة على مذهب عالم المدينة ج ٢ ص ١١٠٦.
 - (٥) الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٤٦٤، وقد جاء فيها: " وإذا ملك المستأجر العين المستأجرة بميراث أو هبة أو نحو ذلك بطلت الإجارة كذا في فتاوى قاضي خان "
 - (٦) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج ٧ ص ٥٢٢.
 - (٧) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨.
 - (٨) المغني لابن قدامة ج ٥ - ص ٣٤٨، الكافي في فقه ابن حنبل ج ٢ - ص ١٧٧.



الأول: أن المستأجر ملك المنافع أولاً ملكاً مستقراً فلا يبطل مما يطرأ من ملك العين، وإن تبعها المنافع لولا الملك الأول^(١).

الثاني: أن المستأجر تملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد ثم يملك الأصل بعقد آخر، وكذا لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز فعلى هذا يكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره^(٢).

أدلة الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني لما ذهبوا إليه بالقياس والمعقول:

أما القياس: فمنه ما يلي:

أولاً: قياس فسخ الإجارة بملك العين المؤجرة على فسخ النكاح بملك اليمين^(٣).

وأما المعقول: فلأن الإجارة عقد على منفعة الرقبة، فإذا ملك الرقبة بطل العقد على منفعتها؛ لأن إذا ملك الرقبة حدثت منافعها على ملكه، وإذا كانت المنافع مملوكة له لم يبق عقد الإجارة.

كما استدلوا على سقوط الأجرة فيما بقي من مدة الإجارة بالقياس على ما لو

(١) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨.

(٢) المغنى ج ٦ ص ٥٣.

(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج ٧ ص ٥٢٢.



تلفت العين، فكما تسقط بذلك لبطلان العقد بتلف العين، فكذلك هنا^(١).

الراجع:

الرأي الراجع - والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني وهو فسخ الإجارة فيما بقي من المدة، وذلك لقوة ما استدلووا به وضعف دليل الرأي الأول.

رابعاً: حكم الوفاء بالوعد:

اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد على أربعة آراء:

الرأي الأول: الوفاء بالوعد مستحب فلو ترك الوفاء به فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة، لكن لا يأثم وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية [إذا لم يكن معلقاً]^(٢)، وبعض المالكية^(٣)، والشافعية^(٤)، والحنابلة في رواية^(٥)، ووافقهم الظاهرية^(٦).

حيث نجد أن الحنفية قالوا بلزوم الوفاء بالوعد فيما لو كان معلقاً^(٧)، كما لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك الثمن فأنا أعطيه لك، فلم

(١) شرح مختصر خليل للخرشي ج ٧ - ص ٢٨، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة

٣١٩ - ٧

(٢) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٢٤٧، المبسوط ج ٤ ص ١٣٢.

(٣) التمهيد ج ٣ ص ٢٠٨، منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤٢٢.

(٤) نهاية المحتاج ج ٥ - ص ٣٢٩، أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٨٦، المجموع ج ٤ ص ٦٥٣.

(٥) المبدع ج ٩ ص ٣٢٢، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣٣١، كشف القناع ج ٦ ص ٢٧٩.

(٦) المحلى ج ٦ ص ٢٧٨.

(٧) غمز عيون البصائر ج ٣ ص ٢٣٧.



يعط المشتري الثمن، لزم الواعد أداء الثمن وفاء بوعده.

الرأي الثاني: وجوب الوفاء بالوعد إذا ارتبط بسبب ودخل الموعد في السبب، أما إذا لم يباشر الموعد السبب فلا شيء على الواعد، كما لو قال الواعد: اهدم دارك وأنا أسلفك فهدمها، أو اخرج للحج، فخرج، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، فتزوج اعتماداً على هذا الوعد، فيلزم الواعد بإنجاز وعده قضاء، بخلاف ما إذا لم يباشر الموعد السبب، فلا يلزم الواعد بشيء.

وهذا هو القول المشهور والراجح في مذهب مالك، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون^(١).

الرأي الثالث: وجوب الوفاء بالوعد قضاء إذا ارتبط الوعد بسبب، سواء دخل الموعد في السبب أو لم يدخل فيه، كما: لو قال شخص لآخر: أعدك بأن أقرضك كذا لتزوج. أو قال الموعد لغيره: أريد أن أقضي ديني أو أتزوج، فأقرضني مبلغ كذا. فوعده بذلك، ثم بدا له فرجع عن وعده قبل أن يباشر الموعد السبب. فإن الواعد يكون ملزماً بالوفاء ويحكم عليه به وبه قال أصبغ من فقهاء المالكية^(٢).

الرأي الرابع: الوفاء بالوعد واجب إلا لعذر وهذا قول بعض المالكية منهم ابن العربي^(٣)، والإمام أحمد في رواية ثانية^(٤)، وهو قول بعض علماء السلف منهم

(١) الفروق ج ٤ ص ٢٥، فتح العلي المالک ج ٢ ص ١٢٩، منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤٢٢، البيان والتحصيل ج ٨ ص ١٨.

(٢) الفروق ج ٤ ص ٢٥، الجامع لمسائل المدونة ج ١٨ ص ٤٤٧.

(٣) ابن العربي: أحكام القرآن ج ٤ ص ٢٠٧، هامش الفروق ج ٤ ص ٤٧.

(٤) الاختيارات الفقهية ص ٣٣١.



عمر بن عبد العزيز، واسحاق بن رهواة^(١)، وابن شبرمة حكاه عنه ابن حزم^(٢)،
وبه قال الإمام الغزالي^(٣)

الأدلة والمناقشة:

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول:

أما السنة فمنها ما يلي:

١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نَيْتِهِ أَنْ يَفِيَّ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَحِمْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)^(٤).

٢ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ) فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْهَا وَأَقُولُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ)^(٥).

(١) فتح الباري ج ٥ ص ٢٩٠.

(٢) المحلى ح ٦ ص ٢٧٨.

(٣) إحياء علوم الدين ج ٣ ص ١٣٣.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العدة - ج ٧ - ص ٣٤٦، برقم (٤٩٩٥)، وجاء في التعليق عليه: إسناده ضعيف لجهالة أبو النعمان وأبي وقاص، وأخرجه الترمذي - باب ما جاء في علامة المنافق ج ٥ ص ٢٠، برقم (٢٦٣٣) بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.

(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ - كتاب الجامع - باب ما جاء في الصدق والكذب - ج ٢ - ص ٩٨٩ -



وجه الدلالة من هذين الحديثين:

دل ظاهر الحديثان على عدم لزوم الوفاء بالوعد وذلك لنفي الإثم عنه.
نوقش الاستدلال بالحديثين: بأن ذلك يحمل على أنه لم يف مضطراً جمعاً بين الأدلة، وأن حملة على هذا المعنى أولى^(١).

أما المعقول: فهو ما استدل الحنفية على لزوم الوفاء بالوعد إذا كان معلقاً ووجهه: بأن الوعد إذا كان معلقاً، فإنه يلزم لقوة الارتباط بين الشرط والجزاء، من حيث إن حصول مضمون الجزاء موقوف على حصول شرطه، وذلك يكسب الوعد قوة، كقوة الارتباط بين العلة والمعلول، فيكون لازماً.

هذا إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه بالشرط شرعاً حسب قواعد مذهبهم، حيث إنهم أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط الملائم دون غيره، أما التمليكات وكذا التقييدات، فإنه لا يصح تعليقها بالشرط عندهم^(٢).

أدلة الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني على ما قالوا به بما يلي: بأن النصوص الشرعية لما تعارضت فمنها ما أوجب الوفاء بالوعد مطلقاً، وهي الأدلة التي استدل بها من أوجب الوفاء بالوعد، ومنها ما لم يجعل إخلاف الوعد من الكذب كأدلة أصحاب الرأي الأول: حيث إن الآية ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

= برقم (١٥).

(١) حاشية ابن الشاط = إدرار الشروق على أنواء الفروق ج ٤ ص ٢٢.

(٢) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٣٢٠، مجلة الأحكام ص ٧٧.



﴿٣﴾^(١) نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأبلىنا ولم يفعلوا^(٢)، وهذا لا شك أنه محرم؛ لأنه كذب، وأما كون مخلف الوعد منافقاً فهو محمول على حالة كون الإخلاف سجية له أو تعمد^(٣)، فكان لا بد من حمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها وأن يجمع بين الأدلة، فوافق هذا الرأي من أوجب الوفاء بالوعد إذا كان الوعد على سبب وباشره^(٤).

دليل الرأي الثالث:

استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بالمعقول ووجهه: بأن ذكر السبب مرتبطاً بالوعد يتأكد به العزم على الدفع.

أدلة الرأي الرابع:

استدل أصحاب الرأي الرابع على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٥).

وجه الاستدلال من الآية الكريمة: قال أبو بكر: يحتج به في أن كل من أُلزم نفسه

(١) سورة الصف من الآية: ٣.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١٨ ص ٧٨.

(٣) الفروق ج ٤ ص ٢٥.

(٤) د/ محمد رضا عبد الجبار العاني: قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون بحث منشور بمجلة مجمع

الفقه الاسلامي، العدد الخامس ج ٢ ص ٩٠٤٧.

(٥) سورة الصف آية ٢.



عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقداً لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلاً ما لا يفعل وقد ذم الله فاعل ذلك وهذا فيما لم يكن معصية فأما المعصية فإن إيجابها في القول لا يلزمه الوفاء بها^(١).

وقال ابن كثير في معنى الآية الكريمة: "إنكار على من يعد عدةً، أو يقول قولاً لا يفي به"، ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً، سواء ترتب عليه غرم للموعد أم لا^(٢).

بينما رد ابن حزم الظاهري على الذين استدلوا بالآية الكريمة على وجوب الوفاء بالوعد: بأن المراد بها الذين يقولون ما لا يفعلون في الأمور الواجبة كإنصاف من دين، أو أداء حق فقط^(٣).

أما السنة فأحاديث منها ما يلي:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ)^(٤).

وجه الدلالة من هذا الحديث:

دل ظاهر الحديث على وجوب الوفاء بالوعد وحرمة إخلافه؛ لأن النبي ﷺ

(١) الجصاص: أحكام القرآن ج ٥ ص ٣٣٤.

(٢) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج ٨ ص ١٠٥.

(٣) المحلى ج ٦ ص ٢٧٩، قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون: الدكتور/ محمد رضا عبد الجبار

العاني: بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب علامة المنافق - ج ١ - ص ١٦، برقم (٣٣).

عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين وصفاتهم، والنفاق مذموم شرعاً، فذكر إخلاف الوعد في سياق الذم دليل على التحريم^(١).

٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِزْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفْهُ)^(٢).

وجه الدلالة من هذا الحديث:

أفاد هذا الحديث النهي عن إخلاف الوعد وتقدم أنه من صفات المنافقين وظاهره التحريم وقد قيده حديث أن تعده وأنت مضمر لخلافه، وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت النهي^(٣).

ناقش ابن حزم هذا الاستدلال بقوله: أنهما ليسا على ظاهرهما؛ لأن من وعد بما لا يحل، أو عاهد على معصية، فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك، كمن وعد بزني، أو بخمر، أو بما يشبه ذلك، فصح أن ليس كل من وعد فأخلف، أو عاهد فغدر، مذموماً، ولا ملوماً^(٤).

الراجع:

بعد عرض آراء الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد أرى - والله أعلم - رجحان

(١) الفروق ج ٤ ص ٤٣ بتصرف.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في المراء - ج ٤ - ص ٣٥٩، برقم (١٩٩٥)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.

(٣) سبل السلام ج ٤ ص ١٩٦-١٩٧.

(٤) المحلى ج ٦ ص ٢٧٩.



وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً إلا لعذر ويجبر الواعد على الوفاء بوعدده قضاء إذا
ترتب عليه ضرر يلحق بالموعود جمعاً بين الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب
الوفاء بالوعد، والذين ذهبوا إلى خلاف ذلك.





الوحدة الثالثة:

التكييف الفقهي مع بيان الحكم الشرعي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك

أهداف الوحدة الثالثة:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - معرفة التكييف الفقهي لبعض صور الإجارة المنتهية بالتمليك.
- ٢ - بيان الصور الصحيحة من الصور الباطلة للإجارة المنتهية بالتمليك.
- ٣ - ذكر الضوابط الشرعية لصحة الإجارة المنتهية بالتمليك.





الوحدة الثالثة:

التكليف الفقهي والحكم الشرعي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك

الصورة الأولى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك تلقائياً:

في هذه الصورة تنتقل ملكية العين إلى المستأجر بمجرد الانتهاء من دفع آخر قسط، وذلك دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد.

ويمكن صياغة هذا العقد على النحو التالي:

أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر كذا لمدة ثلاث سنوات مثلاً، على أنك إذا وفيت بكامل هذه الأقساط، كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط، ويقول الآخر قبلت.

فالعقد في هذه الصورة إجارة تنتهي بتمليك العين دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية المتفق عليها^(١).

بالنظر إلى هذه الصورة يتضح:

١ - أن العقد صيغ في البداية على أنه إجارة لوجود لفظ -أجرتك-، بالإضافة

(١) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهي بالتمليك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس، د/ فهد بن علي الحسون: الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ص ١٢.



لذلك نجد أن المؤجر من حقه سحب العين المؤجرة من يد المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط الإيجارية المحددة، مما يدل على أنه عقد إجارة.

٢- في الوقت نفسه اجتمع مع عقد الإجارة عقد بيع، ويدل على ذلك:

- أن المستأجر ضامن لنفقات الصيانة والتأمين أي كل تبعات التلف والهلاك يتحملها المستأجر، أما في عقد الإجارة فإن يد المستأجر يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا تم سداد الأقساط فإن ملكية العين تنتقل تلقائياً للمستأجر، حيث تعتبر تلك الأقساط في الحقيقة ثمن هذه السلعة.

- وصورة العقد بهذه الصياغة عليها عدة مأخذ:

أولاً: أن كل مبيع لا بد له من ثمن، وفي هذه الصورة لا يوجد ثمن وقت تمام البيع، وتحويل هذه الأقساط بعد ذلك إلى ثمن للعين المؤجرة بعقد لاحق لا يسير مع القواعد الشرعية في أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور إنعقاده.

ثانياً: أن أجرة المنفعة لتلك السلعة ليست أجرة المثل، بل روعي فيها أن تكون ثمن للسلعة.

ثالثاً: أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إيجارها^(١).



(١) سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهي بالتمليك ص ٢٣، د/ خالد المشيقح: المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٨.



التكليف الفقهي لهذه الصورة:

اختلف العلماء في التكليف الفقهي لهذه الصورة وذلك على رأيين:

الرأي الأول:

أنَّ العقد بهذه الصورة هو عقد بيع بالتَّسْطِيط، وبه قال بعض العلماء المعاصرون منهم د/ عبد الله محمد عبد الله^(١)، د/ رفيق يونس^(٢)، والشيخ إبراهيم أبو الليل^(٣)، د/ أحمد دنيا^(٤).

ووجه ذلك:

إذا نظرنا إلى أنَّ العقد بهذه الصورة نجد من آثاره المِلْكِيَّة، وهي لا تكون بلا ثمن، والأقساط المدفوعة لا تتناسب مع أجرة المثل، بل رُوِيَ فيها قيمة المبيع مؤجَّلاً موزَّعة على أقساط، وأنَّ إرادة المتعاقدين في هذا العقد تتجه إلى تَمَلُّك السلعة وليس إيجارتها، والذي دَفَعَهُمَا إلى جعل هذا العقد بهذه الصورة هو خَوْف

(١) د/ عبد الله محمد عبد الله: التأجير المنتهي بالتَمَلِّك والصور المشروعة فيه، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٥٨٠.

(٢) د/ رفيق يونس المصري: بيع التَّسْطِيط - تحليل فقهي واقتصادي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ج ٢ ص ١١٦١٢.

(٣) الشيخ ديان محمد الديان: الإجارة المنتهية بالتَمَلِّك نقلاً من: "البيع بالتَّسْطِيط والبيع الاتمانيَّة الأخرى"، لإبراهيم دسوقي أبو الليل (ص ٣١٥ - ٣١٧). موقع الملتقى الفقهي.

(٤) د/ شوقي أحمد دنيا بحث منشور: الإجارة المنتهية بالتَمَلِّك دراسة اقتصادية وفقهية منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ج ٢ ص ٢٢٥٧٦.



المالك من عدم حصوله على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلاً، والمشتري يرغب في شراء هذه السلعة، وهو لا يملك ثمن شرائها بالنقد، فصاغوا العقد بهذه الصورة؛ لحماية حق المالك من نكول المشتري من دفع ثمن السلعة، فلا يمكن أن يوصف العقد إلا على أنه عقد يتملك فيه العاقد الرقبة والمنفعة، وهذا هو حقيقة البيع المقسط^(١)

الرأي الثاني:

أنها تشتمل على عقدين: عقد إجارة، وعقد بيع معلق على سداد الأجرة^(٢).
اعترض على ذلك: بأن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دُفعت على أنها أجرة للعين المؤجرة، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجرة في نهاية المدة؟
فلما كان العقد بهذه الكيفية؛ وتوارد على العين عقدان مختلفان لاختلاف حكمهما كان العقد محل خلاف بين العلماء المعاصرون رأيين:

الرأي الأول: عدم جواز الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً وهو قول أكثر العلماء المعاصرون منهم: د/ عبدالله محمد عبدالله^(٣)، د/ حسن الشاذلي^(٤)، ود/

(١) الشيخ ديبان محمد الديان: الإجارة المنتهية بالتملك. موقع الملتقى الفقهي.

(٢) دورة عقد التأجير التمويلي (دراسة شرعية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي) د/ يوسف الشبيلي ص ٤، د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهى بالتملك، عبدالله الشيخ بن بيه: الإيجار الذي ينتهى بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس.

(٣) الإجارة المنتهى بالتملك د/ عبدالله محمد عبدالله - ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

(٤) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهى بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ج ٢.

عبد الله الشيخ المحفوظ ابن ييه^(١)، د/ وهبه الزحيلي^(٢)، د/ سعد بن تركي الحثلان^(٣)، الشيخ/ حامد بن عبدالله العلي^(٤)، د/ خالد المشيقح^(٥)، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي^(٦) وأفتت به اللجنة الدائمة.

الرأي الثاني: جواز الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً ودون الحاجة إلى إبرام عقد جديد وبه أفتى بعض العلماء المعاصرون منهم: الشيخ محمد بن جبير^(٧)، والدكتور/ محمد جبر الألفي^(٨)، والدكتور/ سعد بن ناصر الشثري^(٩).

(١) د/ عبد الله الشيخ المحفوظ بن ييه: الإيجار الذي ينتهي بالتملك: بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٦٤٤ وما بعدها.

(٢) د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية ص ٤١٢.

(٣) الإجارة المنتهية بالتملك د/ عبدالله محمد عبدالله - ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

(٤) الشيخ حامد بن عبدالله العلي: تيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة ص ٥٦.

(٥) المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٧.

(٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٦٤٨ وما بعدها.

(٧) ورقة الشيخ محمد بن جبير: رحمه الله التي قدمها لهيئة كبار العلماء، مخالفاً فيها قرار الهيئة بتحريم

الإجارة المنتهية بالتملك، فتوى رقم: ٨٨٦٢. موقع الشيخ على الرابط:

<http://www.ibn-jebreen.com>

(٨) أ. د. محمد جبر الألفي: الإيجار: أهميته، مشروعيته، خصائص عقده، موقع:

<http://www.alukah.net/>.

(٩) ونصه: أن يكون عقد الإجارة ينقلب بسداد جميع الأقساط إلى كونه عقد بيع ذاتياً بلا حاجة لعقد

جديد، فهذه الصورة أرى جوازها وإن كان الأغلبية يرون المنع منها. فتاوى واستشارات الإسلام

اليوم - (ج ٨ ص ٣٣٨، د/ سعد ابن ناصر الشثري بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٢٥ هـ. موقع الملتقى الفقهي.



الأدلة والمناقشة:

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بنفس الأدلة التي استدل بها المانعون لاجتماع العقود والمانعين لتعليق البيع على شرط مستقبل ومنها ما يلي:

الدليل الأول: أن العقد بتلك الصورة اشتمل على بيع وإجارة في آن واحد والمعقود عليه عين واحدة، فكان ممنوعاً شرعاً^(١) لحديث: (لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا يَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)^(٢)... (وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)^(٣) وهذا منه^(٤).

الدليل الثاني: أن العقدان مختلفان؛ لاختلاف أحكامهما وآثارهما، فعقد البيع تنتقل فيه ملكية العين للمشتري والضمان عليه، وأما عقد الإجارة فالملك للمؤجر والضمان عليه ما لم يتعد المستأجر أو يفرط.

فكيف يجمع على المستأجر الضمان وهو تبعات عقد البيع - ويجمع عليه

(١) اللجنة الدائمة: دورة الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض بتاريخ ٢٩/١٠/١٤١٠هـ - موقع صيد الفوائد، د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية ص ٤٠٦.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه - أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - ج ٣ - ص ٥٢٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ج ٣ - ص ٥٢٨، أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٢ - ص ٢١ - برقم ٢١٨٥، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي بلفظ آخر. المستدرک على الصحيحين للحاكم ج ٢ - ص ١٥

(٣) أخرجه الترمذي في سننه - أبواب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - ج ٣ - ص ٥٢٨ - برقم ١٢٣١، وقال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ج ٣ - ص ٥٩٣

(٤) المقدسي: الكافي في فقه ابن حنبل ج ٢ ص ٢٢.



أيضاً تبعات عقد الإجارة وهو سحب السلعة إذا قصر^(١)

الدليل الثالث: أن العقد بهذه الخصائص هو عقد غرر ومجازفة، لأن المشتري قد يعسر في آخر قسط، وقد دفع أقساط لا تناسب الإجارة وهي في الأصل قيمة للرقبة، فقد خسر الثمن والمثمن واللذين قد ربحهما البائع، خلافاً للقاعدة الشرعية التي ذكرها العلماء في أن: الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد لأنه بمعنى العبث وأكل أموال الناس بالباطل^(٢).

الدليل الرابع: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء^(٣).

الدليل الخامس: أن من المعلوم أن ثمن المبيع إما أن يكون حالاً أو مؤجلاً عند تمام العقد والمدفوع كأقساط أخذت تحت ظل عقد الإجارة، فهو ثمن للمنفعة التي استوفاها المستأجر، أما تحويل هذه الأقساط بعد ذلك إلى ثمن للعين المؤجرة بعقد لاحق لا يسير مع القواعد الشرعية في أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده.

وبالتالي فإن حقيقة العقد فيها مبهمة هل هو بيع أم إجارة؟^(٤)

الدليل السادس: إن عقد الإجارة في هذه الصورة حيلة على البيع بالتقسيط،

(١) المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٨.

(٢) د/ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه: الإيجار الذي ينتهي بالتملك: بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الخامس ج ٢ ص ٢ ص ١٠٦٣٩.

(٣) د/ سعد بن تركي الحثلاثن: فقه المعاملات المالية المعاصرة ص ١٢٥ وما بعدها.

(٤) د/ عبدالله الشيخ بن بيه: الإيجار الذي ينتهي بالتملك - مجلة المجمع.



والأصل أن يبنى العقد على الوضوح^(١).

أدلة الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول: أن هذا العقد في حقيقته أنه بيع بالتقسيط، وأن الصيغة في العقد، ستر للعقد الحقيقي، فهو إجارة صورية، والعبرة في العقود بالحقائق، ويترتب على هذا التكييف الفقهي للعقد انتقال ملكية الشيء من المؤجر - البائع إلى المستأجر - المشتري - بمجرد العقد^(٢).

الدليل الثاني: بيع أدرج فيه شرط جزائي، وهو عدم انتقال الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بكافة الأقساط، وحينئذ يصبح مالكا بأثر رجعي، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه^(٣). وهذا بناء على ما روي عن الإمام أحمد بجواز تعليق البيع على شرط.

فقد جاء في المغني: "فإن قال بعتك على أن تنقضي الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع الصحيح نص عليه"^(٤).

(١) د/ عبدالله محمد: التأجير المنتهي بالتملك والصور المشروعة فيه - مجمع الفقه الإسلامي.

(٢) أ. د. محمد جبر الألفي: الإيجار: أهميته، مشروعيته، خصائص عقده، موقع:

<http://www.alukah.net>.

(٣) نفس المرجع السابق، د. مرضي بن مشوح العنزي: الإجارة المنتهية بالتملك، موقع:

<http://www.alukah.net>.

(٤) المغني ج ٤ ص ١٢٩.



نوقش ذلك من عدة أوجه:

الأول: أن العين المؤجرة من ضمان المؤجر، مما يدل على أن المقصود من العقد الإجارة، وليست الإجارة صورية^(١).

الثاني: أن القول بأنه بيع تقسيط مشروط بعدم نقل الملكية إلا بعد سداد الأقساط غير مسلم به؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد، فإن مقتضى عقد البيع هو نقل الملكية للمشتري بمجرد العقد.

يجاب: بالشرط المنافي لمقتضى العقد شرط صحيح، إذا كان لأحد المتعاقدين قصد صحيح في اشتراطه، فالمشتري ينتفع بالعين في هذه الفترة، لكنه لا يتصرف بها في بيع أو هبة فهو كرهن العين، وفيه قصد صحيح للبائع ليحفظ حقه، وشرط التجارة التراضي، فإذا رضي المشتري بذلك فهذا له، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل يمنع منه^(٢).

الدليل الثالث: أن عقد الإجارة المنتهية بالتملك لا يخرج عن كونه عقد بيع بأقساط مؤجلة، ورهن للعين، فلا يتصرف فيها المشتري ببيع أو هبة حتى يسدد كامل الثمن، وهما عقدان صحيحان لازمان^(٣).

(١) دورة عقد التأجير التمويلي (دراسة شرعية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي) د/ يوسف الشبيلي ص ٤.

(٢) مرضي بن مشوح العنزي: الإجارة المنتهية بالتملك، نقلاً من مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٥٦، المناظرات الفقهية، للسعدي، ص ٨٦ موقع: <http://www.alukah.net>

(٣) ورقة الشيخ محمد بن جبير: ﷺ التي قدمها لهيئة كبار العلماء، مخالفاً فيها قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتملك، فتوى رقم: ٨٨٦٢. موقع الشيخ على الرابط: <http://www.ibn->
=

الراجح:

من خلال ما سبق عرضه من مسائل بنيت عليها مسألة الاجارة المنتهية بالتملك تلقائياً وبيان الراجح فيها، وبيان آراء العلماء المعاصرون في ذلك وأدلة كل رأي تبين لي - والله أعلم - رجحان الرأي الأول القائل بعدم جواز عقد الاجارة المنتهية بالتملك تلقائياً بتلك الصيغة السابقة.

لكن ممكن ايجاد بديل شرعي لتلك الصورة وهو أن يفصل بين العقدين بحيث يتبع عقد الإجارة عقد البيع فيستقل كل منهما عن الآخر، وذلك وفق شروط معينة؛ لأن الأصل في المعاملات الصحة إلا إذا دل الدليل على المنع، ولم يثبت دليل ينص صراحة على منع الإجارة المنتهية بالتملك إلا إذا كانت أحكام العقدين تسري على المعقود عليه في وقت واحد.

أما عن الشروط: فقد وضع جمع من العلماء^(١) عدة شروط للخروج من هذه المسألة بصورة مقبولة وهي كما يلي:

١ - أن يكون ضمان العين من المؤجر المالك لها، ويمكن أن يتحملة المستأجر نيابة عن المؤجر على أن يخصم من القيمة الايجارية، وليست على المستأجر الا في

= jebreen.com

(١) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهي بالتملك، د/ منذر قحف مجلة - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهي بالتملك ص ١٨، د/ فهد بن علي الحسون: الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص ١٢، بحث الإيجار المنتهي بالتملك للشاذلي - مجلة المجمع - العدد الخامس، المعاملات المالية المعاصرة للمشيقح ص ٥٩-٦٠، المعاملات المالية د. وهبة الزحيلي ص ٤٠١ وما بعدها.



حالتين: التعدي أو التقصير من المستأجر.

- وأما ما يتعلق بنفقات التشغيل فتكون على المستأجر مثل الزيت والبنزين، وما عدا ذلك فالأصل أن يكون على المالك المؤجر للعين؛ لأنه قد سبق وأن بينت آراء الفقهاء في ضمان العين المؤجرة وأنها أمانة في يد المستأجر لا تضمن إلا بالتعدي.

٢- الشرط الجزائي: للمؤجر أن يشترط على المستأجر شرطاً جزائياً تعويضاً له عن الضرر الذي يلحقه في حالة عدم الوفاء بسداد الأقساط؛ على أن يكون ذلك بقدر ما يرفع عنه الضرر؛ عملاً بالقواعد الشرعية في دفع الضرر^(١).

٣- يجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً.

٤- كما يمكن صياغة العقد على أنه عقد بيع له غنمه وعليه غرمه معلق على شرط الوفاء بجميع الثمن، وفي نهاية المدة إذا تم سداد الأقساط جميعها ينطلق حق الملكية ليضاف إلى حق المنفعة الذي هو موجود عند المستأجر، ومن حق المالك استرداد العين منه إذا لم يف بالأقساط، على أن يخصم القيمة الحقيقية لإجارة العين في تلك المدة السابقة عن الامتناع عن دفع باقي الأقساط، ويرد على المشتري ما زاد على ذلك وهو الفرق (بين ثمن المنفعة و ثمن العين) عملاً بالقواعد الشرعية في دفع الضرر (يدفع الضرر بقدر الامكان ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام).

(١) د/ حسن الشاذلي: الايجار المنتهى بالتملك بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس، د/ خالد المشيقح: المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٩-٦٠، د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية ص ٤٠١ وما بعدها، د/ منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتملك وصكوك الأعيان المؤجرة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد الثاني عشر.

وتعليق البيع على شرط موافق لما ذهب إليه بعض المالكية^(١)، وأحمد في رواية^(٢) من جواز اشتراط عدم نقل الملكية في عقد البيع إلا بعد الوفاء بكامل الثمن عملاً بعموم قول الرسول ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)^(٣)، كما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعَفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ)^(٤) فالنبي ﷺ علق عقد الولاية على أمر في المستقبل. ولأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم؛ وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة.

٥- أو أن يضاف لهذا العقد، وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.

والعقد بتلك الشروط يحقق مصلحة مشروعة وهي ضمان حق البائع في حصوله على ثمن السلعة، وحفظ الأموال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه أرشد إلى المخرج الذي يتحقق به الغرض من غير الوقوع في المحذور فيما رواه عنه أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرٍ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ: (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْرٍ هَكَذَا) قَالَ لَا وَاللَّهِ

(١) مواهب الجليل ج ٤ ص ٣٧٤.

(٢) المغنى ج ٤ ص ١٢٤، الروض المربع ص ٣٢١، الفتاوى الكبرى ج ٥ ص ٣٨٩، إعلام الموقعين ج ٣ ص ٣٨٨.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الإجارة - باب أجر السمسرة - ج ٣ - ص ٩٢

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة مؤتة من أرض الشام - ج ٥ - ص ١٤٣، برقم (٤٢٦١).

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ (لَا تَفْعَلْ بَعْجُ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنْبِيًّا)^(١) بالرغم من أن النتيجة واحدة وهو بيع صاعين من تمر رديء بصاع واحد من تمر جيد، هي نفسها بيع الصاعين من التمر الرديء بدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم صاع من تمر جيد، إلا أن الأولى ممنوعة، والثانية جائزة^(٢).

وهو ما أقره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة^(٣).

الصورة الثانية: الإجارة المنتهية بالتملك بضمن أما أن يكون بضمن رمزي

أو بالضمن الحقيقي للسلعة:

أولاً: حكم الإجارة المنتهية بالتملك بضمن رمزي:

لا خلاف بين جمهور الفقهاء الحنفية^(٤)، والمالكية^(٥)، والشافعية^(٦)، والحنابلة^(٧) على أن عقد البيع إذا صدر ممن هو أهل للتصرف، وذلك بأن كان العاقد (البائع والمشتري) بالغاً، عاقلاً، مختاراً، رشيداً أى يحسن التجارة -أى الأخذ

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه - ج ٣ - ص ٧٧، برقم (٢٢٠١).

(٢) د/ سعد بن تركي الحثلان: فقه المعاملات المالية المعاصرة ص ١٣٥.

(٣) قرار رقم: ١١٠ / ٤ / ١٢.

(٤) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٣٥.

(٥) مواهب الجليل، حاشية الصاوي ج ٣ ص ١٨-١٩.

(٦) المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ١٤٩.

(٧) الإنصاف ج ٧ ص ٢٣٤.



والإعطاء - وكان تصرفه فيما يملك كان عقد البيع صحيحاً، سواء كان البيع بثمن المثل أو أقل.

عملاً بعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(١).

وإذا كان البيع بأقل من ثمن المثل بكثير كأن يبيع ما يساوي مائة بدرهم صح العقد إذا عرف العاقدان الثمن الحقيقي للعين ورضيا بذلك.

لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾^(٢).

وجه الدلالة:

قال القرطبي: اعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن قوله تعالى ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك... والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب^(٣)، ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره^(٤).

(١) سورة البقرة آية ٢٧٥.

(٢) سورة النساء آية ٢٩.

(٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٥٢.

(٤) الباب في شرح الكتاب ج ١ ص ٤١٢.



- أما من باع سلعته وهو غير بصير بقيمتها فقد ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة^(١)، ومالك^(٢)، والشافعي^(٣) إلى أنه لا خيار له بالغبن، بينما المشهور من قول المالكية^(٤)، والحنابلة^(٥): أن له القيام بالغبن غير المعتاد وحدوده الثلث - ففي حق البائع أن يبيع بما ينقص عن ثمن المثل الثلث فأكثر، وفي حق المشتري أن تزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر -، وأما ما دون الثلث فلا قيام له.

فبناء على آراء الفقهاء في صحة البيع بثمن رمزي متى صدر العقد ممن هو أهل للتصرف، مع علم المتعاقدين بالثمن الأصلي للسلعة، هل تصح الإجارة المنتهية بالتملك بثمن رمزي للعين؟ بالنظر لصورة الإجارة المنتهية بالتملك بثمن رمزي نجد:

أنه اشتمل على عقدين:

الأول: عقد إجارة ناجز قد تم فيه تحديد ثمن المنفعة، ومدة الإجارة وتوزيع الثمن على أقساط معلومة.

الثاني: عقد بيع معلق على شرط وهو سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة.

(١) غمز عيون البصائر ج ١ ص ٢٥٧، تنقيح الفتاوى الحامدية ج ١ ص ٢٥٧ ط / دار المعرفة، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ط / دار الجيل - الطبعة الأولى - ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م، ج ١ ص ٣٦٧، ٣٦٨.

(٢) إكمال أعمال المعلم على صحيح مسلم ج ٤ ص ١٩٨ - ١٩٩، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج ٦ ص ٤٠٤.

(٣) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٢ ص ٣٢٦.

(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج ٦ ص ٤٠٤.

(٥) المغني ج ٤ ص ٩٢.



- ولما كان الثمن الرمزي ليس هو الثمن الحقيقي للسلعة، وإنما هو جزء منه وباقي الثمن هو تلك الأقساط الإيجارية المحددة، وإرادة المتعاقدين تتجه إلى عقد بيع، وهي نفس الصورة السابقة إلا أنه هنا قد تحدد ثمن رمزي للعين يدفعه المستأجر في نهاية المدة متى رغب في شرائها، بخلاف ما لو كان الثمن الحقيقي للسلعة هو الثمن الرمزي، وأن قيمة الأقساط الإيجارية تمثل ثمن مثل المنفعة حيث لا إشكال في ذلك كما سبق من بيان أقوال الفقهاء.

- بينما كيفه فقهاء القانون على أنه بيع مقسط فيه الثمن.

لكن الذي يمنع تكييفه بذلك في الفقه الإسلامي: الصيغة وهي قول المالك - أجزتك - فهذا اللفظ دال على الإجارة، إلى انتهاء أجل الأقساط، ثم عقد بيع بعد القيام بالالتزامات التي أوجبها العقد^(١).

وهي مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على رأيين:

الرأي الأول: عدم جواز عقد الإجارة المنتهية بتمليك العين بثمن رمزي، وإليه ذهب بعض أهل العلم منهم: د/ منذر قحف^(٢)، ود/ حسن الشاذلي^(٣)، وبه أخذ غالب هيئة كبار العلماء في السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(١) د/ سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهي بالتمليك ص ٢٥، د/ منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة. ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر.

(٢) د/ منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة. ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر.

(٣) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهية بالتمليك ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٦٩.



الرأي الثاني: ذهب جَمْع من العلماء إلى صحّة الإجارة المنتهية بتمليك العين بثمان رمزي بشروط معينة، وبه قال الشيخ عبدالله بن منيع^(١)، د/ محمد مختار السلامي^(٢)، ود/ وهبة الزحيلي^(٣)، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية^(٤)، والهيئة الشرعية في مجموعة دلة البركة^(٥).

بينما اشترط الدكتور/ محمد مختار السلامي لجواز تلك الصورة: تقديم الثمن

(١) الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه. عبد الله بن سليمان المنيع، موقع

<http://www.feqhweb.com/>

(٢) د/ محمد مختار السلامي: الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٤١١.

(٣) أ. د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية ص ٤٠٤-٤٠٥.

(٤) وجاء نص الفتوى: يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالمطاطرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمان يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترئ الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما وفيه بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلي وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الإجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناه وأثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك المؤجر خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعة هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر، من موقع:

<http://minhadjadvisory.com>

(٥) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة، مجموعة دلة البركة،



الرمزي المتفق عليه حتى لا يؤول إلى تعمير ذمتين الممنوع شرعاً، فعلى المشتري (المستأجر) أن يدفع الثمن الرمزي حالاً، أو أن يدفع الثمن المتفق عليه ناجزاً أيضاً^(١).

وبه أفتت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي. (وليس لبيت التمويل الكويتي أن يهب من أموال المؤسسين أو المستثمرين إلا بإذنه، ولا أن يبيع السيارة بسعر رمزي)^(٢).

بالإضافة للشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون عقد الإجارة عقدًا حقيقياً مستجمعاً لأركان الإجارة وتوفّر شروطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك أيضاً العلم بالأجرة، وتحديد مدة الإجارة، وأن تكون العين صالحة للإجارة، وغير ذلك من الشروط، بحيث يترتب على عقد الإجارة جميع آثاره المقررة شرعاً للمؤجر وللمستأجر، مع الوعد بالتملك بعد انتهاء مدة الإجارة.

الشرط الثاني: أن يكون عقد البيع في أثناء مدة الإجارة، أو بعد انتهاء مدتها حتى لا يجتمع عقدان (عقد البيع والإجارة) في عقد واحد.

الشرط الثالث: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون

(١) د/ محمد مختار السلامي: الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٤١١.

(٢) الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة (الإجارة المنتهية بالتمليك): أ. د/ علي محيي الدين القره داغي، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني عشر نقلاً من الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ج ٤ ص ١٠٢.

التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمّله المالك المؤجر وليس المستأجر^(١).

- كما اشترط الدكتور/ وهبة الزحيلي: بأنه يجب على المالك للعين (وهو المصرف) أن يأخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك، فيما لو كانت العين المؤجرة من أموالهم، وإن كان ثمن العين من صناديق الاستثمار فلا بد من موافقة أصحابها على التصرف، أو وجود نص خاص بذلك في نظامها^(٢).

الأدلة والمناقشة:

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول: أنهما عقدين وردا على عين واحدة، الأول: الإجارة، والثاني: البيع غير مستقرّ على أحدهما، لما روي عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة)^(٣)

الدليل الثاني: أن العقد فيه جهالة وغرر؛ وذلك أن عقد البيع معلق على تمام سداد أقساط الإجارة، فإذا عقد البيع على عين، وكان نفاذ هذا البيع مؤجلاً إلى بعد إنتهاء عقد الإجارة، وكانت مدة الإجارة طويلة بحيث تتغير فيها السلعة وهذا التغير

(١) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة، مجموعة دلة البركة، ص ٢١٠، الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه. عبد الله ابن سليمان المنيع، موقع:

<http://www.feqhweb.com/>

(٢) المعاملات المالية: أ. د/ وهبة الزحيلي، ص ٤٠٤-٤٠٥.

(٣) سبق تخريجه.



لا يمكن ضبطه؛ لأنَّ الناس يتفاوتون في الاستخدام، فيكون عقد البيع على هذا قد أُبرِم على عين مَجْهولة غير معلومة الصَّفة، معرَّضة للتَّلف كُلِّياً أو جزئياً من غير تعدُّ ولا تفريط، ممَّا يجعل العين مَجْهولة الصَّفة، وهذا ممَّا يُبطل البيع^(١).

وقد اشترط المالكية لجواز بيع العين المستأجرة: أن يبقى من مدة الإجارة ما لا يكون غرراً يخاف تغير السلعة في مثله.

أدلة الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول: أن الأجرة في الإجارة والثلث في البيع كما يجوز أن يكون أقل من المثل فكذاك يصح أن يكون بأكثر من المثل، والعبرة في الجواز هو تراضي العاقلين واتفاقهما على مقدار الأجرة، وثلث البيع، وألا يكون هناك تغرير وخداع، فإذا دخل العاقد على بصيرة من أمره بمقدار الأجرة وبمقدار ثمن البيع فلا حرج في ذلك شرعاً^(٢).

الدليل الثاني: أنه لا حرج على الرشيد العالم ما يفعل في الثمن الذي يرضى به في البيع، خاصة إذا كان البائع بنك له خبراؤه، وهو حريص على ما ينفعه حرصاً تسنده الخبرة والعلم بمسار الاقتصاد لا في الدولة التي ينتسب إليها فقط ولكن في العالم خصوصاً مع وسائل الاتصال الحديثة والنشرات المتتابعة عما يجري في

(١) الإجارة المنتهية بالتَّملك: الشيخ ديبان محمد الديبان، موقع:

dobayan@hotmail.com

(٢) الإجارة المنتهية بالتَّملك: الشيخ ديبان محمد الديبان، موقع:

dobayan@hotmail.com.



الأسواق^(١).

الترجيح:

بعد عرض آراء العلماء المعاصرون في تلك المسألة أرى - والله أعلم - صحة الإجارة المنتهية بتمليك العين بضمن رمزي على أن يكون عقد البيع منفصلاً عن عقد الإجارة سواء كان في أثناء مدة الإجارة، أو بعد انتهاء مدتها. مع مراعاة باقي الشروط وذلك لقوة أدلتهم وخاصة أن الثمن الرمزي ليس هو الثمن الحقيقي المقدر للسلعة وإنما هو جزء منه والباقي من الثمن هي تلك الأقساط المتفق عليها.

ثانياً: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك بضمن حقيقي:

في هذا العقد يتحدد الثمن الحقيقي للسلعة المؤجرة عند إبرام عقد الإجارة، أو أن يتفقا المتعاقدان على تحديده بعد الانتهاء من دفع القسط الأخير خلال المدة المحددة لذلك، ويترتب على تحديد هذا الثمن اختلاف واضح في مقدار القسط وبذلك يتحقق للبنك - المؤجر - ما يحرص عليه من عائد تمويلي مع أخذ الأقساط الإيجارية بعين الاعتبار.

وفي هذا العقد ثمن المنفعة: - ممكن أن يكون مثلياً أي يمثل ثمن الانتفاع بالعين في المدة المحددة فقط، وممكن أن يكون أكثر بقليل، مما يجعل ثمن السلعة في نهاية مدة الإجارة أقل من سعر السوق بقليل، وذلك يكون حافزاً للمستأجر لتنفيذ

(١) الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير: د/ محمد مختار السلامي، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٤١٠.



الوعد بالشراء^(١).

وتكفف هذا العقد على أنه عقد إجارة في بدافة تسرى علىه آثار عقد الإجارة وأحكامه الفف قررها الفشرفع الإسلامف؁ وبعد الانتهاء من الوفاء بكافة الأقساط الإفجارية ففملك المسفأجر العفن بعقد بفع بشفن فقفقف للعفن وفترتب علىه أحكام عقد البفع وآثاره كما بفنه الفشرفع الإسلامف.

وهذه الصورة فمكن القول بصحتها فف الفقه الإسلامف^(٢).

وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامف على أن ففضمن الإجارة فف هذه الصورة وعد بالبفع من قبل البنك المؤجر؁ ووعد بالشراء من قبل المسفأجر^(٣).

الصورة الفالفة: حكم الإجارة المقرونة بوعد بالبفع:

هذه الصورة - كما سبق بفانها - هف: أن فصاغ العقد على أنه عقد إجارة؁ فمكن المسفأجر من الانتفاع بالعفن المؤجرة فف مقابل أجرة محددة فف مدة محددة للإجارة؁ على أن المؤجر فعء المسفأجر وعداً ملزماً - إذا وفف المسفأجر بسداد الأقساط الإفجارية فف المدة المحددة - بفع العفن المؤجرة فف ففافة العقد على المسفأجر بمبلغ معفن^(٤).

(١) الإجارة الففففة بالففملك وصكوك الأفعان المؤجرة: د/ منذر قحف؁ ص١٨؁ الإجارة الففففة بالففملك دراسة فقففة إقفصادفة: ؁ د. شوقف ففنا؁ ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامف العدد رقم ١٢.

(٢) الإجارة الففففة بالففملك وصكوك الأفعان المؤجرة: د/ منذر قحف؁ ص١٨؁ د/ حسن الشاذلف: الإفجار الففففة بالففملك ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامف العدد الخامس.

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامف العدد الفاف عشر ج ٢ ص ٢٥٣١.

(٤) الإجارة الففففة بالففملك فف الفقه الإسلامف: د/ فهد بن على الفسون؁ ص١٩؁ الفأفر الففففة



التكليف الفقهي لهذه الصورة: لا يخرج التكليف الفقهي لهذه الصورة عن كونه عقد إجارة عادي خلال كامل مدة العقد، فيسري عليه جميع أحكام الإجارة، وذلك إلى حين تملك المستأجر للعين فتنتقل صفته من مستأجر للعين إلى مالك لها. حيث قد ورد هذا التكليف في فتوى ندوة البركة^(١).

الحكم الشرعي لهذه الصورة:

ينبئ حكم هذه الصورة على حكم الوفاء بالوعد، وهل هو لازم أم لا، وسبق أن بينت آراء الفقهاء في ذلك وذكرت أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة إلا لعذر وقضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة هذا الوعد.

وبناء على ذلك فإن الوعد الصادر من المالك المؤجر للمستأجر ببيع هذه السلعة - المؤجرة - له إذا رغب في ذلك، ودفع ثمناً لها هو كذا - يكون وعداً ملزماً للمالك - بيعها للمستأجر لها، بعد تحقق الشرط، وهو استيفاء جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها وإبداء رغبته في شرائها وتقديم الثمن الذي اتفق عليه، هذا إذا كان الوعد صادراً من المالك، أما إذا كان الوعد قد صدر منهما بأن وعد المالك ببيع السلعة للمستأجر ووعد المستأجر بشراء هذه السلعة من المالك إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بكامل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة، وحدد

= بالتمليك: د/ سعد بن عبدالله السبر، ص ١٣-١٤، نقلاً من الإيجار المتهى بالتمليك للشاذلي. والإجارة وتطبيقاتها المعاصرة للقرعة داغى ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس، الثاني عشر.

(١) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة، ص ٢١١



الثلث، فحيثُذ يكون كل منهما ملزم بهذا الوعد وهو إجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفقا عليه

ولكن بشرط وجود صيغة جديدة تصدر عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد وهو الوفاء بكافة الأقساط الإيجارية، وذلك لعدم وجود صيغة له من قبل - أي الجواز مشروط بأن يكون عقد البيع منفصلاً عن عقد الإجارة.

وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة - إن شاء الله -؛ لعدم وجود المحذور الشرعي فيها^(١)، وهي من الصور التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م)^(٢).

على أن يتم العقد وفق الخطوات التالية:

- ١ - عقد شراء العين من المورد أو بتوكيل سابق مستقل للراغب في الاستئجار.
- ٢ - يبرم عقد اجارة بشكله المستقل.
- ٣ - بشكل متوازي مع إبرام عقد الاجارة يتم اتفاق الطرفين على كيفية نقل ملكية العين للمستأجر في نهاية الإجارة بوثيقة مستقلة سواء كان ذلك بعقد الهبة المعلق أو بالوعد بالبيع بالسعر الرمزي أو السعر المتفق عليه.

(١) د/ سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهي بالتمليك، ص ٢٦، د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهي بالتمليك، الشيخ مختار السلامي: الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه العدد الخامس والثاني عشر، الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة، مجموعة دلة البركة، ص ٢١٠.

(٢) مجلة مجمع الفقه العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٥١٧.



٤- تنفيذ عملية نقل الملكية بإيجاب وقبول يصدر من الطرفين في حالة وثيقة عقد الإجارة إذا اشتملت على وعد ببيع الأعيان المؤجرة^(١).

الصورة الرابعة: حكم الإجارة المنتهية بالتملك عن طريق الهبة:

ولها صورتان:

الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد وعداً ملزماً بهبة العين للمستأجر إذا وفي بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة في نهاية العقد^(٢).

الثانية: أن يصاغ العقد على أساس أنه عقد إجارة مع عقد هبة فوري معلق على شرط سداد جميع الأقساط كأن يقول: إذا قمت بسداد جميع الأقساط المتفق عليها في المدة المحددة فإني وهبتك هذه الدار، ووافق عليها الطرف الآخر^(٣).

الحكم في الصورة الأولى يدخل تحت حكم لزوم الوعد أو عدم لزومه وبناء على الراجح من آراء الفقهاء من لزوم الوفاء بالوعد ديانة إلا لعذر وقضاء إذا دخل الموعد بسببه في كلفة، وفق الضوابط المذكورة في الصور السابقة

(١) المراجع السابقة.

(٢) التأجير المنتهي بالتملك لسعد بن عبدالله السبر ص ١٤، الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي: د/ فهد بن علي الحسون ص ١٩.

(٣) الإيجار المنتهي بالتملك وصكوك التأجير: فضيلة الشيخ محمد مختار السلامي، الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة (الإجارة المنتهية بالتملك) دراسة فقهية مقارنة: أ. د/ علي محيي الدين القره داغي، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢، ج ٢.



وبناء على ذلك فهذه الصورة جائزة- إن شاء الله -؛ لعدم وجود المحذور الشرعي فيها^(١) وهذا يعد من الصور التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م)^(٢).

كما صدرت الفتوى بالجواز عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي عام ١٩٨١م وهذا نصها:

إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة، على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحل فإن هذا العقد يصح إذ روعي فيه ما يأتي:

أ- ضبط مدة الإجارة، وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة.

ب- تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة.

ج- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذاً لوعده سابق بذلك بين المالك والمستأجر^(٣) على أن يكون بإيجاب وقبول يصدر من الطرفين في حالة وثيقة وعد بالهبة^(٤).

(١) المرجع السابق.

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢ ج ٢.

(٣) أ. د/ علي محيي الدين القره داغي: الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة (الإجارة المنتهية بالتمليك): سعد بن عبدالله السبر، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني عشر نقلاً من الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ج ٤ ص ١٠٢.

(٤) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة، مجموعة دلة البركة،



بينما الحكم في الصورة الثانية يدخل تحت اختلاف الفقهاء في حكم تعليق الهبة على شرط مستقبل وهي مسألة اختلف فيها فقهاء السلف على رأيين:

الرأي الأول: يرى عدم جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣)، ووافقهم الظاهرية^(٤).

الرأي الثاني: جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل وهذا قول بعض الحنفية^(٥)، والمالكية^(٦)، ورواية لأحمد^(٧)، وهو ما قال به شيخ الإسلام ابن القيم^(٨).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن الأصل في عقود التمليكات أن تكون منجزة^(٩).
جاء في المغني: "ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة،

= ص ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣.

(١) رد المحتار ج ٥ ص ٢٥٧، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ٢ ص ٣٧٧.

(٢) أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٧٩.

(٣) المغني ج ٦ ص ٢٨٨.

(٤) المحلى ج ٨ ص ٥٩.

(٥) رد المحتار ج ٦ ص ٢٨١.

(٦) مواهب الجليل ج ٨ ص ٤.

(٧) الإنصاف ج ٨ ص ١٥٥.

(٨) إغاثة اللفهان ج ٢ ص ١٦.

(٩) غمز عيون البصائر ج ٤ ص ٤١ بتصرف.

فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع^(١).

أدلة الرأي الثاني:

استدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة:

١ - عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة قال: (لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقِي من مسكٍ ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى إلا هديتي مردودة عليّ فإن ردّت عليّ فهي لك) قال وكان كما قال رسول الله ﷺ وردّت عليه هديته (فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسكٍ وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة)^(٢).

٢ - ما روي أن جابرًا رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ: (لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثاً) فلم يقدم حتى توفي النبي ﷺ فأمر أبو بكرٍ مُنادياً فنادى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دِينَ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِي فَحَسَى لِي ثَلَاثًا^(٣).

وجه الدلالة من الحديثين: دل ظاهرهما على صحة تعليق الهبة على شرط.

(١) المغني ج ٦ ص ٢٨٨.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ج ٥ ص ٢٤٦، برقم (٢٧٢٧٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٣:

فيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب إذا وهب هبة أو وعد عدة

ثم مات قبل أن تصل إليه - ج ٣ - ص ١٦٠، برقم (٢٥٩٨).



الراجح:

الرأي الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل بصحة تعليق الهبة على شرط مستقبل وذلك لقوة أدلتهم حيث أنهم استدلوا بالسنة بينما أصحاب الرأي الأول استدل بالمعقول، ولأن الهبة من عقود التبرعات، والمتبرع متفضل فله أن يتبرع كيفما شاء.

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان:

"فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط وقد صح عن النبي ﷺ أنه علق الهبة بالشرط - ثم ذكر الحديثان - ثم قال فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين" (١).

وبناء على الراجح من آراء الفقهاء فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين (٢) إلى جواز هذه الصورة وهي أن تشتمل صيغة الإجارة على هبة السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأجرة المتفق عليها، ويقبل الطرف الآخر، فتكون هبة معلقة على شرط وهي من الصور التي أجازوها مجمع الفقه الإسلامي (٣).



(١) إغاثة اللهفان ج ٢ ص ١٦.

(٢) الإيجار المنتهي بالتمليك: د/ حسن الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير: فضيلة الشيخ محمد مختار السلامي، الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير: د/ محمد جبر الألفي، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس والثاني عشر، الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، مجموعة دلة البركة، ص ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣.

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢ ج ٢.



وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م).

قرر ما يلي:- الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.

ب- ضابط الجواز:

١- وجود عقدين منفصلين مستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

٢- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

٣- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

٤- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحملة المالك المؤجر وليس المستأجر.

٥- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال



مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

٦- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر طوال مدة الإجارة^(١).

ومن القرارات التي أصدرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع "عقد الصيانة" في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من ٢٥-٣٠ رجب ١٤١٩ هـ (١٤-١٩ نوفمبر ١٩٩٨).

الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر.

هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة^(٢).

أهم النتائج:

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن الإجارة المنتهية بالتمليك تُعد من العقود التي توفر التمويل اللازم للحصول على الاحتياجات الرأسمالية التي تتلاءم مع حجم النشاط للأفراد والشركات على السواء، ولهذا العقد العديد من المزايا لكل من المؤجر والمستأجر، مما ينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني، إذا ما تم وفق الضوابط الشرعية:

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، ج ٢، القرار رقم: ١١٠ (١٢/٤).

(٢) المرجع السابق، العدد الحادي عشر، ج ٢، القرار رقم: ٩٤ (١١/٦).



أهم الضوابط التي تحكم الإجارة المنتهية بالتملك ما يلي:

١- الالتزام بأحكام وقواعد الإجارة ، وأهمها:

- أن يكون عقد الإجارة عقدًا حقيقيًا مستجمعًا لأركان الإجارة وتوفّر شروطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك أيضًا العلم بالأجرة، وتحديد مدة الإجارة، وأن تكون العين صالحة للإجارة، وغير ذلك من الشروط، بحيث يترتب على عقد الإجارة جميع آثاره المقررة شرعًا للمؤجر وللمستأجر، مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الإجارة.

- أن تكون يد المستأجر على الأصل يد منفعة أي يد أمانة، وإذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر.

- الأجرة المدفوعة أثناء مدة الإجارة تعتبر ثمنًا للمنفعة التي استفادها المستأجر، ومن ثم لا يجوز له المطالبة باستردادها إذا لم يتحقق الوعد بالتملك.

- يتحمل المستأجر النفقات الخاصة بالتشغيل.

٢- لا تُنقل ملكية الأصل للمؤجر للمستأجر إلا بعد وفائه بالتزاماته والتمثلة في الأقساط المتفق عليها.

٣- أن يكون عقد البيع في أثناء مدة الإجارة، أو بعد انتهاء مدتها حتى لا يجتمع عقدان (عقد البيع والإجارة) في عقد واحد.

٤- يتم نقل ملكية الأصل إلى المستأجر إما بعقد هبة منفصل عن عقد الإجارة وإما بعقد بيع وفي الحالتين يكون هناك وعد بالهبة أو البيع عند إبرام عقد الإيجار، والوعد بالبيع أو بالهبة من الصور التي أجازها مجلس مجمع الفقه الإسلامي.



للتوسع في موضوعات هذا القسم ينظر إلى:

- ١ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
- ٢ - المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي.
- ٣ - دورة عقد التأجير التمويلي (دراسة شرعية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي) للدكتور/ يوسف الشبيلي.

نموذج أسئلة

عرف الإجارة المنتهية بالتملك، مع ذكر الفرق بينها وبين البيع بالتقسيط؟

س ١

اذكري بعض مزايا عقد الإجارة المنتهية بالتملك، بالنسبة للمؤجر؟
للعلماء آراء في حكم الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً اذكرها مع الأدلة، وذكر ما تراه راجحاً وسبب الترجيح؟

س ٢

س ٣

أكملي مكان النقاط بإجابة مناسبة:

١- تُنقل ملكية الأصل للمستأجر بعد..... بالتزاماته والمتمثلة في الأقساط المتفق عليها.

٢- النفقات الخاصة بتشغيل العين المؤجرة تكون على.....

٣- إذا اشترط المؤجر الضمان على المستأجر كانت الإجارة.....

٤- ذكر بعض العلماء أن التكليف الفقهي لصورة الإجارة المنتهية بالتملك أنها عقد بيع.....



٥- من باع داراً علي أن يسكنها البائع شهراً ثم يسلمها إليه فالبيع عند الحنفية.....

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:-

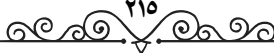
(١) في عقد الاجارة المنتهى بالتملك حيازة العين المستأجرة تكون.....
(للمستأجر - للمؤجر - للعميل - لا شيء مما سبق)
(٢) في عقد الاجارة المنتهى بالتملك يكون ضمان العين المؤجرة على...
(المستأجر - المؤجر - هما معا)
(٣) تحقق الاجارة المنتهية بالتملك العديد من المزايا بالنسبة.....
(للمؤجر - المستأجر - الاقتصاد القومي - جميع ما سبق)
(٤) يد المستأجر على العين المؤجرة يد
(أمانة - ضمان - أ، ب معاً - لا شيء مما سبق)
(٥) في البيع بالتقسيط تعتبر الأقساط في ذمة المشتري ديناً
(لازمًا - غير لازم - غير مستقر - لا شيء مما سبق)



ضعي علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة

الخاطئة:

- ١ - عقد الإجارة المنتهية بالتملك يمكن أن يشتمل على بيع العين المؤجرة في نهاية المدة بثمن حقيقي ()
- ٢ - إذا كان هناك وعد بالبيع في عقد الإجارة المنتهية بالتملك فإنه يكون ملزماً ()
- ٣ - اتفق الفقهاء على جواز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد إذا كان محل العقد واحداً ()
- ٤ - يُجبر الواعد على الوفاء بوعده قضاء وإن لم يترتب عليه ضرر ()
- ٥ - اتفق الفقهاء على جواز الإجارة المنتهية بالتملك بثمن رمزي ()



الموضوع الرابع:
أحكام المناقصات في الفقه الإسلامي

ويحتوي على ثلاث وحدات:



الوحدة الأولى:

في بيان مفهوم المناقصة وإجراءاتها والأسس التي تقوم عليها

أهداف الوحدة الأولى:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - معرفة مفهوم المناقصة.
- ٢ - الالمام بإجراءات المناقصات، والأسس التي تقوم عليها.
- ٣ - توضيح طرفي التعاقد في المناقصات، وأنواعها المتعددة.





الوحدة الأولى: في بيان مفهوم المناقصة وإجراءاتها والأسس التي تقوم عليها وأنواعها

أولاً: مفهوم المناقصة:

المناقصة لغة: يقال نقص الشيء نقصاً ونقصاناً، وانتقص المشتري الثمن أي استحط، والنقيصة: العيب، والنقص: الخسران في الحظ، والنقصان اسم للقدر الذاهب من المنقوص، وتناقص الشيء أي نقص شيئاً فشيئاً^(١).

والمناقصة عكس المزايدة، وهي تنافس في عرض أقل الأسعار، وهي طرح مشروع بناء أو شراء بضائع أو غيرها فيقع الالتزام على من قدم أحسن الشروط من ناحية الخدمة المطلوبة وأرخص الأسعار^(٢).

المناقصة اصطلاحاً: نظراً لأن المناقصة من العقود الحديثة لم أجد لها تعريفاً في كتب الفقهاء القدماء بينما عرفها بعض العلماء المعاصرين:

فقد عرفها بعضهم بأنها^(٣): هي إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه، نظير الوفاء بما

(١) الصحاح في اللغة ج ٢ ص ٢٢ ، القاموس المحيط ج ١ ص ٨١٧ ، المصباح المنير ج ٢ ص ٦٢١ ، المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨١٥ .

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة ج ٢ ص ١٠١٥ ، ٣ ، ٢٢٦٩ .

(٣) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي للشيخ عاطف أبو هريبد.



التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة.

شرح التعريف:

إجراء: يشمل كل إجراء سواء كان إجراء تعاقدى أو غير تعاقدى، وسواء تضمن التزاماً أو لم يتضمن.

بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنه عنه: وهذا قيد يخرج من التعريف كل إجراء لا يتضمن التزاماً ويبقى الإجراء الذي يقتضي التزاماً، وإسناد الالتزام للجهة المعلنه بيان لأحد أركان المناقصة.

بالتعاقد: قيد يخرج كل إجراء يتضمن التزاماً مستقلاً عن إرادة الغير، لكون العقد ارتباط بين إرادتين.

مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه: هذا قيد يبين أنه عقد من عقود المنافسة سواء كان عقد مناقصة أو عقد مزايده، وتقييد التعاقد بصاحب عرض العوض الأقل يخرج عقد المزايدة وهذا يعد ركناً من أركان المناقصة.

نظير الوفاء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة: هذا قيد يبين أن العوض الذي تقدم به صاحبه إنما هو مقابل ما التزم به سواء كان هذا الالتزام توريداً أو مقاوله أو غير ذلك، بحيث يكون هذا الالتزام مطابقاً للشروط والمواصفات المحددة من الجهة المعلنه للمنافسة.

أما المزايدة: فالذي يجريها البائعون، فهم يريدون أن يعقدوا البيع بأعلى سعر يتقدم به المشاركون، إذن فالمناقصة نجد أن الجهة الداعية لإجرائها ترغب بأقل سعر



سواء كانت في شراء سلع أو في تقديم خدمة، وبالتالي فهي تجرى إما في عقود المقاولات عندما يتعلق الأمر بالإجارة أو الاستصناع- فالمقاول: هي أن يتعهد أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً للطرف الثاني، مقابل ثمن معين، فإن تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة كان مقاوله في العرف، واستصناعاً في الشرع، وإن تعهد بتقديم العمل، كان مقاوله في العرف، وإجارة في الشرع - أو في عقود التوريدات^(١) عندما يتعلق الأمر بسلعة^(٢).

والمناقصة تختلف عن الشراء المباشر حيث إن هناك إجراءات تسبقها وتمهد لها.

ثانياً: إجراءات المناقصات:

عندما تحتاج جهة إدارية ما إلى سلع للتوريد أو أعمال للتنفيذ فإن تلك الجهة في البداية تقدر القيمة التقريبية للتوريد أو للمشروع، وتؤكد من وجود الاعتماد اللازم للموازنة، ثم تشكل لجنة لوضع المواصفات والشروط مثل شرط التسليم في محل البائع أو في ميناء الشحن على ظهر المركب، أو في ميناء الوصول أو في

(١) عقد التوريد: هو عقد بين جهة إدارية عامة ومنشأة خاصة (أو عامة)، على توريد أصناف (سلع، مواد) محددة الأوصاف، في تواريخ معينة، لقاء ثمن معين، يدفع على نجوم (أقساط)، د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية- عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع.

(٢) د/ محمد تقي العثماني: (عقود التوريد والمناقصة)، د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية- عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة-)، الشيخ/ مصطفى كمال التارزي (الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر) ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، والثاني عشر، والسابع، د/ سعد بن ترك: المعاملات المالية المعاصرة ص ١٩٠-١٩١.



مستودعات الجهة الإدارية صاحبة المناقصة... إلخ.

خاصة أن هذه الشروط لها أثر في الثمن وفي تحديد الجهة (البائع، المشتري) التي تتحمل المصاريف المختلفة كالشحن، والتفريغ، والتأمين، والرسوم الجمركية... إلخ^(١).

بعد وضع المواصفات والشروط، تجرى الدعوة إلى المناقصة عن طريق:-

١ - الإعلان من خلال الصحف الكثيرة الانتشار - إذا كانت المناقصة عامة - ويحدد في الإعلان الصنف أو العمل المطلوب، وقيمة دفتر الشروط، وآخر موعد لتقديم العروض.

٢ - يشترط للاشتراك في المناقصة شراء دفتر الشروط والذي يحتوي على المعلومات التي أعدها الجهة الإدارية حول المشروع.

٣ - بعد الحصول على دفتر الشروط يدرس الراغبون في المشاركة في المناقصة هذه الشروط فإذا وجدوا في أنفسهم القدرة والرغبة تقدموا بعروضهم إلى الجهة الإدارية حسب المواعيد المحددة، على أن تقدم هذه العروض في مظاريف مختومة (بالشمع الأحمر) وموقعة ولا يجوز فتحها إلا في الموعد المحدد لذلك، وليس للمناقضين بعد تقديم عروضهم تعديل الأسعار بالزيادة أو النقصان لما في هذا من الإخلال بمبدأ المساواة بين المناقضين ومبدأ السرية في المناقصات.

٤ - تشكل لجنة لفتح المظاريف بعد التأكد من سلامة الأختام في موعد محدد

(١) د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية- عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة -)، مجلة

مجتمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع ج ٢ ص ١٩٠.



بحضور المناقصين أو مندوبيهم.

٥- تشكل لجنة لفحص العروض، والتأكد من توافر الشروط الشكلية في العروض، ومطابقتها للشروط والمواصفات.

٦- تشكل لجنة للبت في العروض، ولا يحال إلى هذه اللجنة إلا العروض التي توافرت فيها الشروط، مثل تقديم الضمان الابتدائي، وصورة من شهادة السجل التجاري وبطاقة الاشتراك في الغرفة التجارية، أو الصناعية... إلخ حيث تقوم اللجنة باختيار العرض الأقل سعراً، وتعد محضراً توصي فيه بقبول هذا العرض وأسبابه^(١).

ثالثاً: الأسس التي تقوم عليها المناقصات:

المناقصات تقوم على مبدأين رئيسيين هما المنافسة والمساواة.

أولاً: مبدأ المنافسة:

يراد بذلك إتاحة الفرصة لكل من تتوفر فيه شروط المناقصة أن يتقدم بعطاءه وذلك حتى يكون المجال مفتوحاً للإدارة في اختيار من تراه مناسباً.

وهذا المبدأ يتطلب ضرورة الإعلان عن المناقصة حتى يتمكن كل من يرغب فيها أن يكون بين المتنافسين، وبالتالي لا تستطيع الإدارة منع أحد من التقدم إلى المناقصة المعلن عنها ما دام قد استوفي الشروط المطلوبة، وللإعلان عن المناقصة فوائد كثيرة منها:

(١) د/ حسن الجواهري: (عقود التوريد والمناقصات)، د/ رفيق المصري: المرجع السابق: ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: التاسع، والثاني عشر.



- ١ - تجنب الإدارة أجواء الشك والريبة في التعامل النزيه في إبرام العقود.
- ٢ - إيجاد منافسة مشروعة بين الراغبين في التعاقد مما يؤدي إلى اختيار أفضل العقود.

٣ - تأكيد مبدأ حرية التجارة والعمل والمساواة بين الأفراد في ذلك^(١)

ثانياً مبدأ المساواة:

يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها المناقصات وتتجلى مظاهر هذه المساواة من خلال ما يلي:

- ١ - الإعلان عن المناقصة حتى يعلم بها أكبر عدد ممكن ، على أن يكون الإعلان في صحف واسعة الانتشار.
- ٢ - تجنب ذكر مواصفات أو شروط تنطبق على بلد أو مورد أو مقاول بعينه.
- ٣ - منح الجميع مهلة كافية للتقدم بالعروض.
- ٤ - عدم إجراء أي تعديل في الشروط أو في المواصفات لمصلحة أحد المناقصين أو بعضهم، ولا استبعاد عطاءات البعض بقرارات عامة أو فردية، وأن تكون معايير قبول أو استبعاد العطاءات وفحصها والبت فيها واحدة للجميع.
- ٥ - عدم العدول عن التعاقد مع صاحب العطاء الأقل سعراً، إلا بقرار مسبب وواضح.

(١) د/ محمد الزيني: المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ١٦، الطبعة الأولى ١٤٢٣ - ٢٠٠٣ م نقلاً من مراجع مختلفة.

- ٦- المساواة بين الجميع من حيث المعلومات والفرص واحترام المواعيد وإجراءات التسليم والصرف والضمان والغرامة وسحب العمل.
- ٧- في حالة التساوي بين عرضين أو أكثر يلجأ إلى التفاوض فلو بقي التساوي قائماً بعد التفاوض تقسم الكمية بينهما إذا أمكن ذلك، وإلا اختير أحدهما بالقرعة.
- ٨- وجود رقابة فعالة لمنع أي تجاوزات أو محاباة أو رشوة أو إفشاء للسرية لصالح أحد المناقصين أو بعضهم^(١).

رابعاً: أطراف المناقصة وأنواعها:

للمناقصة طرفان:

الطرف الأول: الجهة الإدارية (صاحبة المناقصة) وهي التي تقوم بطرح المناقصة والإعلان عنها، وهذه الجهة قد تكون مصلحة حكومية أو شركة من الشركات.

الطرف الثاني: الموردون أو المقاولون المشتركون في المناقصة^(٢)، ودائماً يتنافس هؤلاء في الوصول إلى الفوز بالتعاقد مع الجهة الإدارية من خلال طرح أقل عطاء من وجهة نظره.

(١) مناقصات العقود الإدارية - عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة -، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد رقم ٩ ج ٢ ص ١٩٤ وما بعدها، المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ١٧.

(٢) د/ رفيق المصري: مناقصات العقود الإدارية - عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة -، بحث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد رقم ٩ ج ٢ ص ١٨٩.



ثانياً: أنواع المناقصات: للمناقصات أنواع وتقسيمات لكنها لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي لها:

للمناقصات أنواع متعددة وباعتبارات مختلفة:

أولاً: باعتبار نظامها:

تنقسم المناقصات باعتبار نظامها إلى مناقصات عامة ومناقصات محدودة:

أ- مناقصات عامة: وهي الأصل، بخلاف المحدودة، فالقاعدة العامة في تنفيذ المقاولات والتوريدات الحكومية هي أن تتم عن طريق مناقصة عامة توجه الدعوة للمشاركة فيها لعدد غير محدود من المناقصين وبالتالي تخضع لمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، ويعلن عنها في الصحف الرسمية^(١).

ب- المناقصة المحدودة: توجه الدعوة للمشاركة فيها إلى عدد محدود من المقاولين أو الموردين عن طريق الرسائل لمن تتوافر فيهم أهلية الاشتراك في المناقصة من حيث كفاءتهم المالية والفنية وأن يتوافر بشأنهم حسن السمعة، ويتوقع أن يكون عددهم قليلاً بالنظر إلى الإمكانيات الفنية والمالية المطلوبة، ويلجأ إليها استثناءً لتحقيق مصلحة مالية عامة تتمثل في الاقتصاد في تكاليف المناقصات العامة ولا فرق بين النوعين من الناحية الشرعية.

ثانياً: مناقصات باعتبار حدودها

وتنقسم إلى مناقصات داخلية ومناقصات خارجية:

(١) المرجع السابق ص ١٩٨، د/ محمد تقي العثماني: (عقود التوريد والمناقصة) المرجع السابق عدد



أ- المناقصة الداخلية: التي يقتصر الاشتراك فيها على من هم داخل البلد، ويكتفي فيها بالإعلان الداخلي.

ب- المناقصة الخارجية: هي التي يشترك فيها موردون ومقاولون من خارج البلد، ويعلن عنها بداخل البلد وخارجه^(١).

ثالثاً: مناقصات باعتبار طرق اجرائها

وتنقسم إلى مناقصات علنية ومناقصات سرية:

المناقصات العلنية: وذلك باعتبار حضور المناقصين في المناقصة، وتقديم عروضهم بصورة علنية، ويتناقصون في السعر إلى أن ترسو على صاحب السعر الأقل، ومن مميزاتها أن أسعار المتنافسين فيها مكشوفة، وهم يتنافسون على بيئة فيكون عرض كل واحد معروفاً للآخرين.

والمناقصات السرية هي السائدة حديثاً، إلا أن الواضح أن المناقصات العلنية تحقق الغرض منها وهو التنافس بين المشتركين فيها للوصول إلى أفضل عرض.

أما عن الهدف من سرية المناقصات الحديثة هو: أن المناقصات الحديثة، مناقصات فنية معقدة يحتاج تقديم العروض فيها إلى دراسة، وقد يكون الهدف من سرية المناقصة أنها تنطوي على كميات كبيرة من السلع أو الخدمات وقد يخشى لسبب أو لآخر في العلانية أن يندفع البعض للنزول إلى أسعار غير معقولة، فيتعثر التوريد أو التنفيذ، أما إذا كان السعر مدروساً وعادلاً وبعيداً عن حرارة المنافسة

(١) المرجع السابق ص ١٩٨، فضيلة الشيخ حسن الجواهري: (عقود التوريد والمناقصة) العدد الثاني



العلنية فان المتقدم للمناقضة يستطيع أن يضع لنفسه حداً من الربح يعينه على تنفيذ التزاماته^(١).

رابعاً: مناقصات باعتبار موضوعها

وهي تنقسم إلى:

أ- مناقصات موضوعها الشراء: وذلك حينما تحتاج إدارة ما إلى شراء ما تحتاجه بمواصفات معينة فتسعى من أجل ذلك لإجراء مناقضة لتصل من خلالها إلى أقل الأسعار.

ب - مناقصات موضوعها الإجارة: وهي تتعلق بإجارة أشياء تستعين بها الإدارة في القيام بأعمالها أو إنشاء مشروع معين على أن تكون مواد المشروع من الجهة الداعية لإجراء المناقضة.

ج- مناقصات لأجل الاستثمار: كما في حالة تعلق المناقضة بالمضاربة أو بالمزارة أو بالمساقاة، فإن الممول في المضاربة الشرعية، وصاحب الأرض والبذر الذي يريد زراعة أرضه بنسبة من الربح، وصاحب الأصول الذي يرغب في أن يسقي غيره أصوله المغروسة قد يعقدون مناقضة لمن يكون شريكاً لهم في الربح، فيعلن (المضارب والمزارع والمُسَاقِي) رغبته للتعاقد مع أفضل من يتقدم للشركة معه^(٢).

(١) د/ رفيق المصري: مرجع سابق ص ١٩٩ - ٢٠٠ بتصرف.

(٢) الشيخ حسن الجواهري: المناقصات (عقد الاحتياط ودفع التهمة) مرجع سابق، العدد التاسع ج ٢ ص ٢٦٣.



الوحدة الثانية: في الأحكام الشرعية للمناقصات

أهداف الوحدة الثانية:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - فهم التكييف الفقهي للمناقصات.
- ٢ - التمييز بين المناقصات وبين بعض البيوع المنهي عنها والتي قد تلبس بها.
- ٣ - توضيح المقصود بدفتر الشروط وحكم بيعه.





الوحدة الثانية: الأحكام الشرعية للمناقصات

أولاً: التكييف الفقهي للمناقصات:

اختلف هؤلاء المعاصرون في تكييفها على عدة آراء هي:

الرأي الأول: يرى أصحابه أن المناقصة كالمزايدة^(١) ينطبق عليها ما ينطبق على المزايدة، والاختلاف بينهما في الشكل فقط حتى أن معظم أحكامهما تنظمها لائحة واحدة، وبه قال الدكتور رفيق المصري في قول له^(٢)، والدكتور علي السالوس^(٣)، والدكتور عبد الوهاب أبو سليمان^(٤)، والدكتور محمد المختار السلامي^(٥).

الرأي الثاني: المناقصة تشبه عقد المسابقة في الاسم والمضمون، وبه قال الدكتور رفيق المصري في قول ثان له^(٦)، فالمناقصة مسابقة بين المناقصين على

(١) وسوف أبين حكم المزايدة بعد بيان آراء العلماء في التكييف الفقهي للمناقصة.

(٢) مناقصات العقود الإدارية (عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة): للدكتور/ رفيق يونس المصري ص ٤٢.

(٣) مداخلة للدكتور في أثناء مناقشة عقد المناقصة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن.

(٤) عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون-دراسة مقابلة-مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي.

(٥) بيع المزايدة: للشيخ محمد المختار مفتي الجمهورية التونسية، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي.

(٦) مناقصات العقود الإدارية (عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة) دكتور، رفيق يونس المصري ص

الفوز بعقد التوريد، أو المقاوله ويشترط فيها ما يشترط في المسابقة من حيث المساواة بين المشتركين في كل شيء، في المعلومات، وفي الفرص، وفي سائر الشروط والمواصفات.

الرأي الثالث: المناقصات تختلف باختلاف موضوع المناقصة وأن الدعوة إلى المناقصة في أي عقد يجوز إنجازه شرعاً على الفور هي دعوة إلى هذه العقود، فمثلاً إن كان موضوع المناقصة عقد البيع للمبيعات الموجودة عند البائع، أو عقد الإجارة، أو عقد الاستصناع أو المقاوله، فالدعوة إلى المناقصة في هذه العقود دعوة إلى هذه العقود وهو ما قال به الدكتور/ تقي العثماني^(١)، ويوافقه الشيخ حسن الجواهري^(٢) بقوله: أن المناقصة من مصاديق البيع والتجارة، وهي مشروعة، لما يلي:

١- قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾^(٥)

وجه الاستدلال:

أن المعاملة الجارية بصورة المناقصة هي بيع أو إجارة أو مزارعة أو مضاربة أو

= ٤٣.

(١) عقود التوريد والمناقصة للقاضي/ محمد تقي العثماني، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي.

(٢) المناقصات (عقد الاحتياط ودفع التهمة) الشيخ حسن الجواهري، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي.

(٣) سورة البقرة: ٢٧٥.

(٤) سورة المائدة: ١.

(٥) سورة النساء: ٢٩.



غير ذلك، فالدليل الذي دل على صحة هذه العقود من الأدلة العامة أو الخاصة هو نفسه الدليل على صحة هذه المناقصة بشرط أن تسلم أصول العقد وتحقق أغراضه.

٢- إن المناقصات تستهدف في حقيقتها المحافظة على المنافسة الشريفة في خفض الأسعار لصالح طالب السلعة، أو خفض الأجرة لصالح طالب العمل، وهذا العمل قد يتعين في الشريعة الإسلامية إذا كان الغرض منه الشراء للأيتام بواسطة الحكام أو الوصي أو القيم، لما فيه من توقع الشراء بأقل ودفع التهمة.

كما قد يتعين هذا العمل في الشراء أو إنجاز العمل لمؤسسات الدولة كالأوقاف والمؤسسات العامة كالمدارس، وإن لم يتعين فلا أقل من استحبابه في مثل الصورة المتقدمة لما فيه من تحقيق المصلحة العامة أو مصلحة المتولي عليه أو دفع التهمة على المباشر في بعض الصور.

ونوقش: بأن هذا التكييف لا يستقيم؛ لأن المراد هو تكييف المناقصة من حيث هي أي ذات المناقصة، والتي تقوم على اختيار صاحب العطاء الأقل للتعاقد معه وفق إجراءات معينة وليس تكييف ما تؤول إليه، إذ إنها قد تؤول إلى بيع أو استصناع أو إجارة.

الرأي الرابع : المناقصة منظومة عقود، أي يدخل فيها عدة عقود؛ لاشتمالها على عقد بيع دفتر الشروط، وعقد الضمان بنوعيه، ثم تنتهي المناقصة بإبرام عقد يؤول إما إلى عقد توريد سلع، أو عقد مقاوله للقيام بخدمات أو أعمال، وهذا العقد المركب، الإيجاب فيه يصدر من المناقص عند تقديمه العطاء وهو ملزم له، والقبول فيه يصدر من المناقص له عند إبرامه العقد مع صاحب العطاء الأقل سعراً والذي رست عليه المناقصة. وهو ما قال به رفيق المصري في قول له^(١)

(١) مناقصات العقود الإدارية (عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة) دكتور، رفيق يونس المصري ص



الرأي الخامس: المناقصة ما هي إلا إجراءات للدخول في العقد، وليست عقداً، وبه قال الشيخ عبدالله بن منيع^(١)، والدكتور/ القره داغي^(٢)، وغيره من العلماء المعاصرين^(٣).

نوقش:

بأن المناقصة ليست إجراءات فقط بل هي عقد تام، إذ تقديم المناقص العرض يعد إيجاباً، وهذا الإيجاب يُعتبر ملزماً له، لا يرجع عنه حتى ترسو المناقصة على غيره، وإبرام العقد بعد رسو المناقصة يعتبر قبولا، وتنتهي المناقصة بإبرام العقد بين المناقِص له وبين المناقِص صاحب العطاء الأقل سعراً، وهذا هو القبول الذي وافق الإيجاب السابق، وهما من أركان أي عقد، وما تضمنه من وجوب الالتزام من كلا الطرفين^(٤).

= ٤٣. ط، دار المكتبي سورية، الطبعة الاولى ١٤٢٠-١٩٩٩ م

(١) أورد رأيه في المناقشات حول موضوع المناقصات، وقد جاء قوله: "وعقود المناقصات والمزايدات إنما سميت عقوداً على سبيل التجاوز وإنما هي إجراءات لعقود". مجلة مجمع الفقه الاسلامي - العدد التاسع.

(٢) أورد رأيه في المناقشات حول موضوع المناقصات، وقد جاء قوله: "وبخصوص تكييف عقد المناقصة على أساس أنه عقد، أنا أرى أن المناقصة نفسها ليست عقداً وإنما هي إجراءات للدخول في العقد". مجلة مجمع الفقه الاسلامي - العدد التاسع.

(٣) ومنهم من أورد رأيه في المناقشات حول موضوع المناقصات، وقد جاء قوله: "أرى أن مثل هذه القضايا ومنها قضية المناقصات هي قضية إجرائية أكثر منها قضية عميقة وأصل المسألة... من الناحية الفقهية ليس هنالك ما يمنعه". مجلة مجمع الفقه الاسلامي - العدد التاسع.

(٤) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير للباحث/ عاطف محمد حسين أبو هرييد، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بغزة، ص ٩١.



الرأي الراجح

بعد عرض أقوال العلماء في بيان التكييف الفقهي للمناقصات أرى - والله أعلم - أن أقرب التخريجات الفقهية للمناقصة:

- ١ - أنها تشبه عقد المزايدة في الكثير من الإجراءات مع مراعاة التقابل بينهما.
- ٢ - أنها منظومة عقود وليست عقدا واحدا مثل:
- عقد بيع كراسة الشروط
- عقد الضمان
- العقد الذي يتعلق بموضوع المناقصة كعقد توريد سلع وهو عقد بيع أو بيع منفعة أو عقد استصناع.

ثانياً: حكم بيع المزايدة

ولكي يتضح حكم المناقصة في الشرع لا بد وأن أبين حكم بيع المزايدة، وحكم تلك العقود التي خرجت عليها المناقصة والتي تعتبر أساس في المناقصات:

تعريف المزايدة:

المزايدة لغة: زيادة: نافسه في الزيادة وفي ثمن السلعة، زاد فيه على آخر، زيد: الزاي والياء والذال أصل يدل على الفضل، والمزاد: موضع الزيادة.

وبيع المزاد: البيع الذي يتم بطريق الدعوة إلى شراء الشيء المعروض ليرسو



على من يعرض أعلى ثمن، وثمن المزداد هو الثمن الذي رسا به على المزاد^(١).

المزايدة في اصطلاح الفقهاء: عرفها ابن حزي بقوله: أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها^(٢).

وعرفها الزيلعي بقوله: أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا بالبيع فيأتي آخر فيزيد عليه^(٣).

أراء الفقهاء في حكم بيع المزايدة:

اختلف الفقهاء في حكم بيع المزايدة على ثلاثة أراء:

الرأي الأول: أن بيع المزايدة جائز مطلقاً وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية^(٤)، والمالكية^(٥)، والشافعية^(٦)، والحنابلة^(٧)، ووافقهم الظاهرية^(٨)، والزيدية^(٩).

(١) مقاييس اللغة ج ٣ ص ٤٠، المعجم الوسيط ص ٨٤٨ - ٨٤٩.

(٢) القوانين الفقهية ص ١٨٣.

(٣) تبين الحقائق ج ٤ ص ٦٧.

(٤) البحر الرائق ج ٦ ص ١٠٨، تبين الحقائق ج ٤ ص ٦٧ ط / دار الكتاب الإسلامي، شرح فتح القدير ج ٦ ص ٤٧٩ ط / دار الفكر.

(٥) المتقى شرح الموطأ ج ٥ ص ١٠١، ط / دار الكتاب الإسلامي، الفواكه الدواني ج ٢ ص ٧٢ ط دار الفكر، حاشية العدوي ج ٢ ص ١٨٩ ط / دار الفكر.

(٦) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٣ ص ١٩، أسنى المطالب ج ٢ ص ٣٩ ط / دار الكتاب الإسلامي، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٩٠ ط / دار الكتب العلمية، الحاوي الكبير ٤ ص ٧٦٩.

(٧) المغني ج ٤ ص ١٤٩، كشف القناع ج ٣ ص ١٨٣ ط / دار الكتب العلمية.

(٨) المحلي ج ٧ ص ٣٧٠ ط / دار الفكر.

(٩) سبل السلام ج ٢ ص ٣٠ ط / دار الحديث.



الرأي الثاني: عدم جواز بيع المزايدة إلا فيما يحصل عليه عن طريق الميراث والغنيمة وهذا قول الأوزاعي وإسحاق بن راهوية^(١).

الرأي الثالث: كراهة بيع المزايدة وهذا قول إبراهيم النخعي^(٢).

الأدلة والمناقشة:

أدلة الرأي الأول:

استدلوا على ما ذهبوا بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أما السنة فمنها ما يلي:

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَجَّ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ^(٣).

وجه الاستدلال:

دل ظاهر الحديث على جواز بيع المزايدة.

نوقش:

بأنه ليس في قصة المدبر بيع المزايدة؛ فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا ثم

(١) فتح الباري لابن حجر ج ٤ ص ٣٥٤، نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٣٣، تحفة الأحوزي ج ٤ ص ٣٤٤.

(٢) فتح الباري ج ٤ ص ٣٥٤، نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٧٠ - ٢٧١.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب بيع المزايدة ج ٣ ص ٦٩، برقم (٢١٤١).

يعطي به غيره زيادة عليها^(١).

أجاب ابن بطلال: بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) قال فعرضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذي باعه عليه^(٢).

٢- ما رواه أنس بن مالك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ^(٣) وَالْقَدَحَ^(٤)) فَقَالَ رَجُلٌ خَذْتُهِمَا بِدَرَاهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ) فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَيْنِ (فَبَاعَهُمَا مِنْهُ)^(٥).

وجه الدلالة:

دل ظاهر قوله ﷺ: (مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ) على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها ﷺ؛ إذ لم يجب من أعطى درهماً^(٦).

أما الأثر: فمنه ما رواه ابن أبي شيبة عن سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا، وَعَطَاءً،

(١) ابن حجر: فتح الباري ج ٤ ص ٣٥٤.

(٢) ابن بطلال: شرح صحيح البخاري ج ٦ ص ٢٦٩.

(٣) الحلس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله، والجمع (أَحْلَاسٌ) و(الحِلْسُ) بساط يسط في البيت. المصباح المنير ج ١ ص ١٤٦.

(٤) القدح: هو الذي يُؤْكَلُ فيه، قيل: يَجْمَعُ عَلَى قَدَحٍ وهو السَّهْمُ الذي يُرْمَى به عن القَوْسِ، يقال للسَّهْمِ أَوَّلٌ مَا يُقَطَّعُ: قِطْعٌ ثُمَّ يُنْحَتُ وَيُرَى فَيُسَمَّى بَرِيًّا ثُمَّ يَقُومُ فَيُسَمَّى قَدَحًا ثُمَّ يُرَاشُ وَيُرَكَّبُ نَصْلُهُ فَيُسَمَّى سَهْمًا. النهاية في غريب الأثر ج ٤ ص ٣٩.

(٥) أخرجه الترمذي في سننه أبواب البيع، باب ما جاء في بيع من يزيد ج ٢ ص ٥١٣ برقم ١٢١٨. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأَخْضَرِ بن عَجْلَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ الْحَنْفِيُّ، الذي رَوَى عن أنس، هو أبو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ. وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يُراجع: جامع الأصول ج ١٠ ص ١٥٦، المسند الجامع ج ١ ص ٤٣٤.

(٦) تكملة المجموع ج ١٣ ص ٩.



قَالَ: «لَا بَأْسَ مِنْ بَيْعٍ مَنْ يَزِيدُ»^(١)

وجه الدلالة:

دل ظاهر قول مجاهد وعطاء على إباحة بيع المزايدة. أما الإجماع: فقد نقل الإجماع على جواز بيع المزايدة ابن قدامة في المغني: قال: وهذا أيضاً إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة^(٢)

أما المعقول: فلان الحاجة ماسة اليه، فهو بيع الفقراء والمحتاجين ومن كسدت تجارته، فلو ترك الناس هذا البيع لما استطاع الفقراء أن يصلوا إلى حاجاتهم، ولو ترك الناس الزيادة في السلعة المعروضة لدخل الضرر على الباعة.^(٣) كما قال الإمام مالك: في أن العلة في تقييد النهي عن السوم على السوم في كونه بعد رضا المتعاقدين بقوله: "أما قبل التراكن والتقارب فجائز؛ لأنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة في سلعهم؛ لأنه يؤدي إلى بخسها وبيعها بالنقص"^(٤).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية، باب في بيع من يزيد، ج٤ ص ٢٨٧ برقم ٢٠٢٠٥. هذا الحديث ضعيف فإن في إسناده بن لهيعة وهو ضعيف. يُراجع: تحفة الأحوذى ج٤ ص ٣٤٤.

(٢) المغني ج ٤ ص ٣٠٠ ط / دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون للدكتور / محمد عثمان شبير - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ص ٣٣٩٠٣٤٠، الناشر جامعة الكويت.

(٣) عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون للدكتور / محمد عثمان شبير - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ص ٣٣٩:٣٤٠، الناشر جامعة الكويت.

(٤) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج ٦ ص ٩٦.



أدلة الرأي الثاني:

استدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة والأثر:

أما السنة: فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ) ^(١).

وجه الدلالة:

ظاهر الحديث يدل على النهي عن بيع المزايدة إلا في الغنائم والمواريث، وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الدال على الجواز.

أما الأثر فممنه ما يلي:

- ١ - ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن، وابن سيرين: «أَنْهَمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ» ^(٢).
- ٢ - روى ابن أبي شيبة عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّهُ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ» ^(٣).

(١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٥ ص ٥٤، برقم (٥٣٩٨)، إسناده صحيح، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٥٠: "هو في الصحيح، خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث"، ثم قال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وبقيته رجاله رجال الصحيح".

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية، باب في بيع من يزيد، ج ٤ ص ٢٨٧ برقم ٢٠٢٠٤. هذا الحديث ضعيف فإن إسناده بن لهيعة وهو ضعيف. يُراجع: تحفة الأحوذى ج ٤ ص ٣٤٤.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية، باب في بيع من يزيد، ج ٤ ص ٢٨٧ برقم



وجه الدلالة:

دل ظاهر الأثرين على جواز بيع المزايدة في الغنائم والمواريث دون غيرهما.

نوقش ما استدل به أصحاب الرأي الثاني من وجهين:

الأول: أن ذكر المغانم والمواريث في الحديث ليساً قيماً فيه، وأن ذكرهما خرجاً مخرج الغالب على ما كانوا يعتادون فيه البيع مزايدة ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم. بدليل أن البيع مزايدة وقع في غيرهما^(١).

الثاني: أن الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف^(٢).

أدلة الرأي الثالث:

استدل أصحاب الرأي الثالث على ما ذهبوا إليه بالسنة:

١ - روي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)^(٣)

وجه الدلالة:

دل ظاهر الحديث على النهي عن السوم في البيع، والسوم، الزيادة.

= ٢٠٢٠٦.

(١) نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٠١، تحفة الأحوذى ج ٤ ص ٣٤٤ ط / دار الكتب العلمية - بيروت.

(٢) طرح الشرب ج ٦ ص ١٠٧.

(٣) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، ج ٣ ص ١١٥٤، برقم (١٥١٥).



نوقش:

بأن المراد بالنهي عن السوم بعد رضا البائع، وقبوله الثمن الذي عرضه المشتري عليه، أما السوم في السلعة، أي التي تباع لمن يزيد فلا يحرم^(١).

٢- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ (يَنْهَى عَنِ الْمَزَايِدَةِ)^(٢).

وجه الدلالة:

ظاهر الحديث يدل على النهي عن بيع المزايدة، والنهي يحمل على الكراهة لما قد يسببه هذا البيع من إثارة الحقد والبغضاء^(٣)

كما أنه يعارضه ما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- قولاً وفعلاً في الحديث الذي رواه أنس السابق.

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات في حكم بيع المزايدة يتبين لي أن الرأي القائل بالجواز هو الراجح لقوة ما استدلوا به من أدلة، ولتعلق حاجة الناس بهذا النوع من البيوع في معاملاتهم دون التقييد بكون المبيع من ميراث أو غنيمة. والله أعلم

(١) نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٧٠.

(٢) أخرجه البزار في كشف الأستار ج ٢ ص ٩٠، حديث رقم (١٢٧٦)، مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٥١، حديث رقم (٢٨٢٦)، وقال: رواه البزار وإسناده حسن، وفي تحفة الأحوذى: إسناده ضعيف.

(٣) عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون للدكتور/ محمد عثمان شبير - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ص ٣٤١.



ثالثاً: بيع منهي عنها تلتبس بالمناقصات:

ما يتم في المناقصة طبقاً لمبدأ المساواة بين المناقصين أن ينقص المناقص عن الشخص الذي ناقص قبله فهل هذه العملية تدخل تحت النهي عن البيع على البيع، والسوم على السوم، والنجش؛ وذلك للتشابه بين المناقصات وبين هذه البيوع التي ورد النهي عنها فكان لا بد من التعرض لهذه البيوع وبيان معانيها وأدلة تحريمها ثم المقارنة بينهما وبين المناقصات.

بيع الرجل على بيع أخيه.

معناه: بأن يتراضيا أي البائع والمشتري على ثمن سلعة فيجيء آخر في زمن الخيارين فيقول للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن فيضر بصاحب السلعة^(١).

أو أن يقول: أنا أبيعك خيراً منها بثمنها، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري، فيفسخ البيع، ويشترى هذه.

وفي معنى البيع الشراء على الشراء: وهو أن يجيء مشتري آخر إلى البائع قبل لزوم العقد فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشترى به المشتري الأول^(٢).

حكمه: يحرم بيع الرجل على بيع أخيه عند جمهور الفقهاء المالكية^(٣).

(١) شرح فتح القدير ج ٦ ص ٤٧٧، ط / دار الفكر.

(٢) المغني ج ٤ ص ٣٠٠.

(٣) التاج والإكليل ج ٦ ص ٢٥٤ ط / دار الكتب العلمية.

والشافعية^(١)، والحنابلة^(٢)، ووافقهم الظاهرية^(٣).

بينما خالفهم الحنفية حيث ذهبوا إلى أنه مكروه تحريماً^(٤).

واستدلوا على ذلك: بما رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)^(٥).

لكن اختلف الفقهاء في صحة هذا العقد على رأيين:

الرأي الأول: صحة بيع الرجل على بيع غيره مع لحوق المشتري الإثم وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية^(٦)، والمالكية في قول^(٧)، والشافعية^(٨)،

والحنابلة في رواية^(٩)، ووافقهم الزيدية^(١٠)، وهو الراجح في نظري - والله أعلم - لأنه

(١) أسنى المطالب ج ٢ ص ٣٩ ط / دار الكتاب الإسلامي.

(٢) كشف القناع ج ٣ ص ١٨٣ ط / دار الكتب العلمية، مطالب أولي النهي ج ٣ ص ٥٥ ط / منشورات المكتب الإسلامي بدمشق.

(٣) المحلى ج ٧ ص ٣٧٠ ط / دار الفكر.

(٤) رد المحتار ج ٥ ص ١٠١ ط / دار الكتب العلمية.

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، ج ٣ ص ٦٩، حديث رقم (٢١٣٩).

(٦) البحر الرائق ج ٦ ص ١٠٧ ط / دار الكتاب الإسلامي، الجوهرة النيرة ج ١ ص ٢٠٦ ط / المطبعة الخيرية.

(٧) التاج والإكليل ج ٦ ص ٢٥٤، الفواكه الدواني ج ٢ ص ١٠٨-١٠٩.

(٨) تكملة المجموع شرح المهذب ج ٣ ص ٣٠٨ ط / المطبعة المنيرية، تحفة المحتاج ج ٤ ص ٣١٤، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٤.

(٩) كشف القناع ج ٣ ص ١٨٣-١٨٤، الإنصاف ج ٤ ص ٣٣٢ ط / دار إحياء التراث العربي، المغني ج ٤ ص ٣٠٠.

عقد مكتمل الأركان والشروط، والنهي الوارد في ذلك لأمر خارج عن عقد البيع.

الرأي الثاني: بطلان بيع الرجل على بيع أخيه وهذا قول ثاني للمالكية^(٢)، والحنابلة في ظاهر المذهب^(٣)، ووافقهم الظاهرية^(٤) لأنه منهي عنه؛ والنهي يقتضي الفساد^(٥).

وقد وضع الفقهاء شروطاً لتطبيق منع بيع الرجل على بيع أخيه:

- ١- أن يقع البيع من غير إذن البائع، أو أن يقع الشراء من غير إذن المشتري، فلو أذن المتضرر منهما في العقد لم يحرم البيع؛ وذلك لأن الحق لهما وقد أسقطاه^(٦).
- ٢- أن يقع البيع مع رضا المتعاقدين على الثمن بخلاف ما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر، فهو يعتبر في هذه الحالة بيع من يزيد وهو حائز.
- ٣- أن يقع البيع على البيع قبل اللزوم أي في زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط لتمكنه من الفسخ فإذا وقع البيع بعد مضي زمن الخيار، ولزوم البيع فلا حرمة وذلك لعدم تمكن أحد المتعاقدين من فسخ العقد^(٧).
- ٤- أضاف بعض الشافعية: أن لا يكون المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً، وإلا جاز

(١) التاج المذهب ج ٣ ص ٣٨٧.

(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٣٣.

(٣) الإنصاف ج ٤ ص ٣٣١ ط / دار إحياء التراث العربي، المغني ج ٦ ص ٣٠٦.

(٤) المحلى ج ٧ ص ٣٧٠.

(٥) مطالب أولي النهي ج ٣ ص ٥٥.

(٦) أسني المطالب ج ٨ ص ٥٩، روضة الطالبين ج ٤ ص ٤٢٨.

(٧) كشف القناع ج ٩ ص ١٣، مطالب ج ٣ ص ٥٥، المغني ج ٦ ص ٣٠٦.



البيع على البيع، لأن الدين النصيحة^(١).

الفرق بين المناقصة ومنع البيع على البيع:

فالشروط التي وضعها الفقهاء لمنع البيع على البيع لم تتوافر في المناقصة، فالمناقصة لا تدخل تحت النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ وذلك لأن الراغب في الاشتراك في المناقصة يتقدم بعطاءه وليس معنى تقدمه بالعطاء الموافقة عليه من الطرف الآخر للمناقصة، ولم يحصل ركون أو ميل من الطرف الآخر لإبرام العقد فلا تدخل المناقصة تحت النهي.

ثانياً: السوم على السوم:

فالسوم: هو الذهاب في ابتغاء الشيء، والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع سلعته بثمان ما ويطلبها المشتري بثمان دونه.

السوم على السوم معناه: أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدها فيقول آخر لصاحبها أنا اشتريها بأكثر أو للراغب أنا أبيعك خيراً منها بأرخص وهذا حرام بعد استقرار الثمن^(٢).

والفرق بين البيع على بيعه والسوم على سومه: أن في البيعة على بيعه تم العقد إلا أن بين المتعاقدين خيار شرط أو مجلس، أما في السوم على سومه: فهو بعد الاتفاق وقبل العقد^(٣).

(١) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٣ ص ١٨.

(٢) عمدة القارئ ج ١١ ص ٢٥٧.

(٣) منحة العلام في شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ / عبدالله بن صالح الفوزان ج ٦ ص ١٠٤، ط / دار =



حكمه: يحرم سوم الرجل على سوم أخيه عند جمهور الفقهاء^(١) ما عد الحنفية^(٢) حيث ذهبوا إلى أنه مكروه تحريماً.

والحكمة من تحريم ذلك: لما في ذلك من إخلال بالمروءة، وإيغار للصدور، وزرع للبغضاء، وإثارة للنزاع والشحناء، وإفساد للمجتمعات بقطع الصلات، مما يتنافى مع حرص الإسلام على تألف المجتمعات، وتحسين الصلات^(٣).

وقد وضع الفقهاء عدة شروط لمنع السوم على السوم:

أن يكون سوم الغير بعد استقرار الثمن.
وأن يكون السوم بعد حصول التراضي بين المتعاقدين، أو ركون كل منهما إلى الآخر^(٤).
عدم الإذن من المتضرر منهما، فإن أذن البائع أو المشتري بالسوم لم يدخل تحت النهي.

= ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

(١) حاشية العدوي ج ٢ ص ١٨٩، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٤، المغني ج ٦ ص ٣٠٧، المحلى ج ٧ ص ٣٧٠-٣٧١.

(٢) مجمع الأنهر ج ٢ ص ٧٠ ط/ دار إحياء التراث العربي، العناية شرح الهداية ج ٦ ص ٤٧٧ ط/ دار الفكر.

(٣) الفقه المنهجي على مذهب الاكام الشافعي للدكتور/ مصطفى الخن وآخرون ج ٦ ص ٤٣، ط/ دار القلم دمشق.

(٤) العناية شرح الهداية ج ٦ ص ٤٧٧، تحفة المحتاج ج ٤ ص ٣١٤، الفواكه الدواني ج ٢ ص ١٠٨، الإنصاف ج ٥ ص ٣٩٥، التاج المذهب.



الفرق بين المناقصات والسوم على السوم:

في سوم الرجل على سوم أخيه نجد أن السوم الثاني ورد بعد استقرار الثمن ورضا المتعاقدان، ولم يتبقى إلا أن يأخذ العقد شكله الأخير، أما المناقصات فهي قبل استقرار الثمن؛ إذ يتقدم الراغب بعطاءه، ولما لم يرتض الطرف الآخر بالعطاء أو يركن إليه، ووجد الإذن من صاحب المناقصة بالسماح لمن يرغب في الاشتراك التقدم بعطاءه، اكتسبت المنافسة بالنقصان في العطاءات الجواز والصحة، فلم تدخل المناقصة تحت النهي عن السوم على السوم.

النجش:

النجش لغة: الاستتار لأنه يستر قصده ويخفيه ومنه يقال للصائد نَاجِشٌ لاستتاره^(١).

وشرعاً: أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريها لنفسه ولكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنها^(٢).

الناجش لا يريد شراء السلعة، ويزيد فيها ليتتفع البائع ويضر المشتري حيث يظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك.

ومن صورته أيضاً ذلك الذي يمدح سلعته ويطري في مدحها بالكذب ليغر غيره ويخدعه^(٣).

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٩٤.

(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٣٣.

(٣) فيض القدير ج ٦ ص ٣٨١ ط / دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى.

حكمه: ذهب جمهور الفقهاء المالكية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣)، ووافقهم الظاهرية^(٤)، والزيدية^(٥)، إلى حرمة النجش

بينما ذهب الحنفية: إلى أنه مكروه تحريماً فيما لو بلغت السلعة قيمتها، أما إذا لم تبلغ قيمتها فلا كراهة لانتفاء الخداع والتدليس^(٦).

ومما ورد في النهي عن النجش من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾^(٧).

وجه الدلالة:

قال القرطبي: أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة، كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلف^(٨). فتغريب المشتري أو الغير يدخل تحت عموم الآية.

ومن السنة: مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ)^(٩)

(١) المتقى شرح الموطأ ج ٥ ص ١٠٧ ط / دار الكتاب الإسلامي.

(٢) أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٠، حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٢ ص ٢٩٢، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٣.

(٣) المغني ج ٦ ص ٣٠٤.

(٤) المحلى ج ٧ ص ٣٧٢.

(٥) التاج المذهب ج ص

(٦) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٣٣.

(٧) سورة الأحزاب آية ٥٨.

(٨) تفسير القرطبي ج ١٤ ص ٢٤٠.

(٩) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيل - باب ما يكره من التناجش - ج ٩ ص ٢٤٣ برقم ٦٩٦٣ /



فالحديث بمنطوقه دل على حرمة النجش.

بينما اختلف الفقهاء في حكم البيع إذا وقع مع النجش على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: صحة البيع ولزومه وعصيان الناجش وهذا قول الحنفية^(١)، ووجه للشافعية^(٢)، والمختار عند الإباضية^(٣).

الرأي الثاني: البيع صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا كان بمواطأة البائع وهذا ما ذهب إليه المالكية في قول^(٤)، والشافعية في وجه خلاف الأصح^(٥)، ورواية الحنابلة^(٦)، ووافقهم الظاهرية^(٧)، والزيدية^(٨)، والإباضية في قول ثاني^(٩).

بينما أضاف الحنابلة^(١٠): أن الخيار يثبت للمشتري إذا غبن غبنًا غير معتاد، وإن لم يكن بمواطأة البائع وإلا فالخيار له.

= ومسلم في صحيحه كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ٣ ص ١١٥٦ برقم ١٥١٦.

(١) شرح فتح القدير ج ٦ ص ٤٧٦، البحر الرائق ج ٦ ص ١٠٧.

(٢) أحكام الأحكام ج ٢ ص ١١٣-١١٤، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٣.

(٣) شرح كتاب النيل.

(٤) التمهيد ج ١٣ ص ٣٤٨ ط / مؤسسة القرطبة، حاشية الصاوي ج ٣ ص ١٠٦.

(٥) المجموع ج ١٣ ص ١٥، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٩٢.

(٦) المغني ج ٦ ص ٣٠٥، الإنصاف ج ٤ ص ٣٩٦.

(٧) المحلى ج ٧ ص ٣٧٢.

(٨) التاج المذهب ج ص.

(٩) شرح كتاب النيل ج ص.

(١٠) المغني ج ٦ ص ٣٠٥.



واشترط الظاهرية لثبوت الخيار: أن لا يكون المشتري قد اشترط على البائع السلامة في العقد، فإن اشترط ووقع البيع، ولم يعلم قدر الغبن، لكن علمه غيره فهو بيع باطل مفسوخ ومضمون ضمان الغصب، وإن علمه ثبت له الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه^(١).

الرأي الثالث: البيع باطل وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه^(٢).

الأدلة والمناقشة:

أولاً: أدلة الرأي الأول، استدلووا على ذلك:

بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ)^(٣)، والنهي في الحديث عائد إلى الناجش وليس إلى العقد فلم يفسد؛ لأن النهي المقتضي للفساد هو النهي لأمر يتعلق بالعقد، لا لأمر خارج^(٤).

كما أن النجش ليس بعيب في نفس البيع، وإنما هو خديعة في الثمن^(٥)، ولأن المشتري زاد في الثمن عن اختياره وإرادته^(٦).

(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٥٩.

(٢) الإنصاف ج ٤ ص ٣٩٥، المغني ج ٦ ص ٣٠٥.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) المغني ج ٤ ص ٣٠٠.

(٥) شرح ابن بطال ج ١١ ص ٢٧٩.

(٦) الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٣.

ثانياً: أدلة الرأي الثاني، استدلو على ذلك بالسنة والمعقول:

أما السنة: فما روي أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاً^(١) فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ)^(٢). في الحديث جعل الرسول الله ﷺ لمشتري المصرة الخيار إذا علم بعيب التصرية ، ولم يقضي بفساد البيع ، ومعلوم أن النجش مثل التصرية لما في ذلك من مكر وخديعة، وبالتالي فالنجش يصلح فيه البيع ويكون المشتري بالخيار من أجل ذلك قياساً ونظراً^(٣).

نوقش:

بأن النجش ليس بعيب في نفس المبيع كالمصرة المدلس بها وإنما هو كالمدح وقد كان يجب على المشتري التحفظ وأن يستعين بأهل الخبرة^(٤).

أما المعقول فمنه وجهين:

الأول: أن في البيع مع النجش تغرير بالعاقد، فإذا كان مغبوناً ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان^(٥).

(١) المصرة: أن يريد بيع الناقة أو الشاة فيحقن اللبن في ضرعها أياماً لا يحتلبه ليرى أنها كثيرة اللبن. الفائق في غريب الحديث والأثر ج ٢ ص ٢٩٣.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر، ج ٣ ص ٧١، حديث رقم (٢١٥١).

(٣) التمهيد ج ١٣ ص ٣٤٨ بتصرف.

(٤) المرجع السابق ص ٣٤٩.

(٥) المغني ج ٦ ص ٣٠٥.



الثاني: أن النهي عن النجش لحق الآدمي فلم يفسد العقد؛ لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار^(١).

ثالثاً: أدلة الرأي الثالث، استدلو على ذلك بما يلي:

ما رَوَتْهُ السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)^(٢)

دل ظاهر قول الرسول ﷺ في الحديث على أن البيع مع الخديعة باطل مردود.
- روى ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ)^(٣) والنهي يقتضي الفساد فكان البيع مع النجش باطلاً^(٤).

- فقد روى ابن أبي شيبه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بعث عمرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزد، فلما فرغ جاءه فقال له عمر: كيف كان البيع اليوم؟ فقال: إن البيع كان كاسداً يا أمير المؤمنين لولا أني كنت أزيد عليهم فأنفقه، فقال عمر: (كنت تزيده عليهم ولا تريد أن تشتري)؟ فقال: نعم، قال عمر: (هذا نجش، والنجش لا يحل، ابعث يا عمرة منادياً ينادي ألا إن البيع مردود وإن النجش لا يحل)^(٥).

(١) المرجع السابق.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأفضية - باب نقض الأحكام الباطلة ونقض محدثات الأمور ج ٣ ص ١٣٤٣ برقم ١٧١٨.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) المغني ج ٦ ص ٣٠٥ بتصرف.

(٥) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه - كتاب البيوع - باب في بيع من يزد ج ٥ ص ٢٩ أثر رقم ٣.



وجه الدلالة:

دل ظاهر فعل عمر رضي الله عنه على حرمة النجش وبطلان البيع معه.

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو القول بصحة البيع مع ثبوت الخيار للمشتري وذلك لقوة أدلتهم، ولأن النهي إنما ورد لأمر خارج عن العقد، فهو عقد كامل الأركان والشروط، لكن يثبت الخيار للمشتري جبراً للغبن الذي قد يقع فيه متى كان ذلك بمواطأة البائع، ووقع البيع بأكثر من قيمته، ولأنه رضي الله عنه (قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) فيما رواه عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ^(١).

الفرق بين المناقصة وبين النجش:

صورة النجش قد توجد في المناقصة لكن معكوسة، وذلك كأن تتواطأ الجهة الإدارية الداعية لإجراء المناقصة مع أحد المشاركين فيها بأن يتقدم بعطاء يعرض فيه ثمن أقل من ثمن السوق وهو غير مريد للبيع حقيقة، وإنما خدمة للجهة الداعية للمناقصة، فالعلة التي نهى عن النجش لأجلها متحققة في المناقصة وهي الخديعة للغير والإضرار به، فلو تقدم أحد المشاركين في المناقصة بعرض فيه تنقيص في الثمن وهو لا يريد بيعاً، لحق مقدم العطاء الإثم، وإن لم يوجد تواطؤ من الطرف الآخر، وعليه فإن المناقصة تشترك مع النجش في صورة تنقيص الثمن، ولكنها تختلف عنه في انتفاء قصد البيع من الناجش ^(٢).

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ج ٣ ص ٤٣٠، حديث رقم (٢٣٤٠).

(٢) د/ عاطف محمد حسين: عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، موقع:



رابعاً: حكم بيع كراسة الشروط

المعمول به في المناقصات أن تصدر الجهة الإدارية للمناقصة ما يسمى بكراسة الشروط وهي تشتمل على تفاصيل العقد ومواصفاته وتطرح للبيع عند الإعلان عن المناقصة فما حكم بيع هذه الكراسة؟ وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من توضيح العناصر المؤثرة في تكاليف إجراء المناقصة وهي على النحو التالي:

- ١ - المجهود الذهني المبذول في دراسة المشروع وإعداده.
 - ٢ - تكاليف إعداد الخرائط والرسوم والمخططات اللازمة للمشروع.
 - ٣ - تكاليف الخدمات والاستشارات الهندسية.
 - ٤ - قيمة الأوراق المتعلقة بالمشروع.
 - ٥ - حصة من المصاريف الإدارية، تقدر بنسبة ١٠، من مجموع العناصر السابقة^(١).
- أما عن يتحمل تلك التكلفة فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على أربعة آراء:-

الرأي الأول: جواز بيع كراسة الشروط لمن يرغب المشاركة في المناقصة وهو

= <http://www.startimes.com/?t=٢٦٨٠٨٧٣٧>

(١) د/ رفيق المصري: (عقد التوريد والمناقصات) بحث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢.



ما ذهب إليه فضيلة الشيخ مختار السلامي^(١)، ود/ عبد الله المنيع^(٢)، أبو سليمان في قول ثان له، وفضيلة الشيخ حسن الجواهري^(٣)

الرأي الثاني: إن الذي يتحمل قيمة كراسة الشروط هو المناقصة الذي رست عليه المناقصة، وبه قال الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان^(٤)

الرأي الثالث: وجوب بذل كراسة الشروط بالمجان، وعلى الجهة المصدرة له أن تتحمل تكلفة إعدادها، لكن يجوز أخذ تأمين من طالب الدفتر على أن يُرد إليه إذا رد دفتر الشروط؛ لعدم اشتراكه في المناقصة، أو لعدم رسوها عليه، أو لإلغاء المناقصة. وهذا قول د/ رفيق المصري^(٥).

الرأي الرابع: جواز بيع كراسة الشروط إذا كانت مشتملة على دراسات فنية ورسم خرائط على أن تكون القيمة تمثل قيمة تكاليف إعدادها بخلاف ما لو كانت كراسة الشروط مشتملة على مجرد شروط العقد؛ لأنه بمنزلة بيان شروط العقد من أحد العاقدين وهذا قول د/ محمد تقي العثماني^(٦).

(١) فضيلة الشيخ مختار السلامي: بيع المزايدة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن

ج ٢ ص ١٦٠٩٧

(٢) حيث أورد رأيه في المناقشة وليس في بحث. المرجع السابق العدد الثامن ج ٢.

(٣) الشيخ حسن الجواهري: المناقصات (عقد الاحتياط ودفع التهمة)، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع.

(٤) عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة للدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مجلة المجمع، العدد الثامن.

(٥) المرجع السابق.

(٦) د/ محمد تقي العثماني: (عقد التوريد والمناقصة) المرجع السابق العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٨٧٥



الأدلة والمناقشة

أولاً: أدلة الرأي الأول

واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية:

الأول: أن كراسة الشروط تحتوي على معلومات يجوز بيعها على من يريد أن يقتنيها للدخول في المناقصة عملاً بعموم الأدلة التي تدل على مشروعية البيع^(١)، منها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(٢)، كما يشملها مشروعية التجارة عن تراض في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾^(٣)

الثاني: أن كراسة الشروط وثيقة مادية مسعرة بسعر محدد لم يلزم بها أي مشتر إلزاماً ظاهراً.

الثالث: إن القصد من شراء كراسة الشروط هو أن يكون كل مشارك في المناقصة على بينة من أمره في شروط العقد وضوابطه وليس القصد بيعه؛ لأن تفاهة قيمته بالنسبة للمبيع لا تجعله مقصوداً بالثمن^(٤)

(١) الشيخ حسن الجواهري: المناقصات (عقد الاحتياط ودفع التهمة)، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع.

(٢) سورة البقرة: ٢٧٥.

(٣) سورة النساء: ٢٩.

(٤) فضيلة الشيخ مختار السلاوي: بيع المزايدة بحث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن، ج



نوقش ذلك:

بأن الأعيان والمنافع التافهة القيمة لا تعد من الأموال المتقومة مثل قطرة الماء وحب القمح، ولكن هل ثمن دفتر الشروط من هذا القبيل؟^(١).

الرابع: أن قيمة كراسة الشروط إنما هي تمثل قيمة ما أنفق على إعدادها وإن كانت تلك القيمة لا تمثل إلا جزءاً قليلاً من ثمنه فإن الغرض من ذلك هو أن لا يدخل في المناقصة من ليس أهلاً لها فتضيع الفرصة ثم يرجع إلى الذي يليه كما أنه يبين جدية المناقص في الاشتراك في المناقصة، وبالتالي فقد يكون بيعه بتلك القيمة من المصالح المعبرة^(٢).

نوقش:

بأن الجدلية في الإقدام على المشاركة في المناقصة لا تتعلق بدفتر الشروط وإنما تتعلق بالضمان^(٣).

الخامس: إن اشتراط الحصول على كراسة الشروط بثمن يُعتبر شرطاً سائغاً ليس له تأثير في العقد؛ ولذلك فلا مانع منه^(٤).

السادس: أن من لم يرس عليه العطاء مستفيداً أيضاً من دفتر الشروط وذلك؛

(١) د/ رفيق المصري: (عقد التوريد والمناقصات) بحث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢.

(٢) د/ عبد الله المنيع: حيث أورد رأيه في المناقشة وليس في بحث. المرجع السابق العدد رقم ٨ ج ٢.

(٣) د/ رفيق المصري: (عقد التوريد والمناقصات)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر.

(٤) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير للباحث/ عاطف محمد حسين أبو هريدي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بغزة، ص ٩٥.



بمعرفة مدى إمكانية إنجازه للمطلوب، فلا يدخل مغامرًا دون معرفة قدراته وإمكاناته في تنفيذ مشروع معين، مما يساعده على الفوز في مناقصات مستقبلية؛ إذ يحفز هذا على رفع كفاءته، وتطوير قدراته، وتحسين أدائه^(١).

ثانيًا: أدلة الرأي الثاني:

استدلوا بما يلي:

أولاً: ان ما تشتمل عليه كراسة الشروط من مواصفات ودراسات ستوفر على المتقدم في المناقصة الكثير، بحيث لا يحتاج إلا للتنفيذ بموجبها عندما يرسو عليه العطاء، وإذا كان هذا معلوماً لديه مسبقاً فإنه يحتسب تكلفة تلك الدراسات ضمن تكاليف المشروع.

ثانياً: إن المناقصين الذين لم يرس عليهم العطاء يدفعون تلك الرسوم دون مقابل، وأن العدل والانصاف يقضي أن تكون مسئولية دفع التكاليف جميعها من قبل من ظفر بالمناقصة، وبهذا نستطيع أن نخلص معاملاتها من شبهة أكل أموال الناس بغير حق.

ثالثاً: أدلة الرأي الثالث:

استدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية:

الأول: إن الجهة المصدرة له هي المستفيدة منه فهي التي اختارت إجراء

(١) نقله الدكتور/ رفيق المصري عن الشيخ: أبو سليمان بقوله: " لقد نشر أبو سليمان بحثه هذا أيضاً في مجلة: (البحوث الفقهية المعاصرة) إلا أنه غير رأيه": (عقد التوريد والمناقصات)، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد الثاني عشر.



المناقصة وحددت شروطها ، وبالتالي فمن له الغنم كان عليه الغرم .

الثاني: إن المناقِصين لو حَمَلُوا بثمن دفتر الشروط فإن واحداً منهم فقط هو الذي سيفوز بالعقد برسو المناقصة عليه، وليس هناك من وجه لتحميل سائر المناقِصين تكلفة دفتر الشروط .

الثالث: إن أخذ المناقِص له مقابلًا لدفتر الشروط أشبه بالضرية؛ لذلك يجب بذله بالمجان لمن يطلبه .

الرابع: أما بالنسبة لأخذ الجهة الداعية للمناقصة تأمينًا نقديًا فإنما هو لحماية دفتر الشروط ممن يأخذه وهو غير جاد فلا ينتفع به هو أو ينتفع به غيره^(١) .

رابعاً: أدلة الرأي الرابع:

استدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

إن كراسة الشروط إذا كانت مشتملة على دراسات فينة ورسم خرائط فذلك يتطلب جهداً ومالاً، كما أنه من ناحية أخرى يخفف العبء على المشاركين في المناقصة؛ لأنه لولا إصداره لاحتاج كل واحد من المناقِصين إلى إجراء هذه الدراسة بنفسه فيحتاج لبذل الجهد والمال^(٢) .

(١) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي ص ٩٤، رسالة ماجستير للباحث / عاطف محمد حسين

أبو هرييد، د. رفيق المصري مجلة. مجمع الفقه الإسلامي

(٢) د/ محمد تقي العثماني: المرجع السابق العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٨٧٥ .



الترجيح:

بعد عرض آراء العلماء أرى جواز بيع كراسة الشروط لمن يرغب المشاركة في المناقصة وذلك لقوة ما استدلووا به؛ ولأن في شرائها تحصيل منفعة للمشاركة في المناقصة، كما أن المناقص له بذل مجهوداً يستحق عليه أخذ العوض؛ وعليه فهو يحقق مقصد الشارع في عدم أكل أموال الناس بالباطل.

كما أنه شرط سائغ لا تأثير له في صحة في العقد، وقد قال عليه السلام: "المسلمون على شروطهم" ^(١) - والله أعلم -



(١) سبق تخريجه.



الوحدة الثالثة: الضمان في المناقصات

أهداف الوحدة الثالثة:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على أن:

- ١ - معرفة الحكم الفقهي للمطالبة بالضمان.
- ٢ - الإمام بما يتعلق بكتاب الضمان المصرفي من حيث: التعريف به، وذكر أنواعه، وفائدة إصداره، وكيفية الإصدار له وحكم الضمان به.
- ٣ - شرح المقصود بعمولة إصدار كتاب الضمان، وتوضيح الحكم الفقهي لذلك.
- ٤ - توضيح الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة، وحكم العجز عن التنفيذ.





الوحدة الثالثة: الضمان في المناقصات

أولاً: حكم المطالبة بالضمان:

أولاً: تعريف الضمان:

هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. فيثبت في ذمتها جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، واشتقاقه من الضم^(١).

وهو جائز شرعاً ودليل مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾^(٢).

أما السنة: فَمَا رَوَى أَبُو أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ)^(٣).

أما الإجماع: فقد نقله ابن قدامه في المغني بقوله: وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة^(٤).

(١) المغني ج ٥ ص ٧٠.

(٢) سورة يوسف الآية ٧٢.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداه، ج ٢ ص ٥٥٦ برقم ١٢٦٥. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. يُراجع: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ج ٤ ص ١٥٨.

(٤) المغني ج ٥ ص ٧٠.



ثانياً: حكم المطالبة بالضمان:

الراغب في المشاركة في المناقصة عندما يتقدم بعطاءه لا بد وأن يقدم معه ضماناً وهو ما يعرف بالضمان الابتدائي، ويهمل كل عرض لا يصاحبه ضمان، ويرد الضمان الابتدائي إلى أصحاب العروض الذين لم ترس عليهم المناقصة، أما من رست عليهم المناقصة فإما أن يستكمل الضمان الابتدائي باعتبار أن نسبته أقل من الضمان النهائي، أو يسترد الضمان الابتدائي، ويقدم ضماناً نهائياً^(١).

وعلى ذلك فالضمان المطلوب من المناقصين ينقسم إلى قسمين:-

القسم الأول: الضمان الابتدائي:

الهدف منه التأكد من جدية المناقصين وصدق رغبتهم في الاشتراك في المناقصة، والتزامهم بالتعاقد في حالة إرساء العطاء على أحدهم.

حكمه: لا مانع شرعاً من المطالبة بالضمان الابتدائي بناءً على ما سبق من أدلة مشروعية الضمان، وعملاً بقوله ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)^(٢)، وهو يعد أمانة في يد المناقص له، يرد إلى من لم ترس عليهم المناقصة، وهو ما أقره علماء مجمع الفقه الإسلامي^(٣).

(١) د/ محمد تقي العثماني: (عقد التوريد والمناقصة) العدد رقم ١٢ ج ٢، د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة) أبحاث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم ٩ ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن.



أما إذا سحب المناقص عطاءه قبل إرساء المناقصة فإن مبلغ الضمان لا يرد لصاحبه^(١).

وهذا يشبه صورة من صور بيع العربون، وهو أن يشتري أو يكتري سلعة ويعطيه شيئاً من الثمن على أنه - أي المشتري - إن كره البيع تركه للبائع وإن أحبه حاسبه به أو تركه^(٢).

وهذه الصورة من صور بيع العربون اختلف فيها الفقهاء على رأيين:

الرأي الأول: منع بيع العربون وهذا قول جمهور الفقهاء المالكية^(٣)، والشافعية^(٤)، ورواية للحنابلة^(٥).

الرأي الثاني: صحة بيع العربون وهو الصحيح من مذهب أحمد^(٦).

(١) د/ محمد تقي العثماني: (عقد التوريد والمناقصة) المرجع السابق العدد رقم ١٢ ج ٢، د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة)، أبحاث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم ١٢ ج ٢، العدد رقم ٩ ج ٢، د/ محمد الزيني: المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ٨٥

(٢) الشرح الصغير على أقرب المسالك ج ٣ ص ١٠٠.

(٣) حاشية الصاوي ج ٣ ص ١٠٠، منح الجليل ج ٥ ص ٤٦.

(٤) مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٩٥، أسنى المطالب ج ٢ ص ٣١.

(٥) الإنصاف ج ٤ ص ٣٥٨.

(٦) الإنصاف ج ٤ ص ٣٥٨، مطالب أولي النهي ج ٣ ص ٧٧.



الأدلة والمناقشة:

أولاً: أدلة الرأي الأول، استدلووا على ذلك بالسنة والأثر والمعقول:

أما السنة: فَمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ)^(١).

وجه الدلالة: دل ظاهر الحديث على تحريم البيع مع العربان؛ ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل^(٢).

أما الأثر: فقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء وعن ابن طاوس عن أبيه: أنهما "كرها العربان في البيع"^(٣).

وجه الدلالة:

دل ظاهر الأثر على منع بيع العربون.

أما المعقول: فمن عدة أوجه:

الأول: أنه يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل^(٤).

(١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع، باب في العربان، ج ٣ ص ٢٨٣ برقم ٣٥٠٢. قال ابن عدي في

الكامل: هذا الحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. يُراجع: الكامل في ضعفاء الرجال

ج ٥ ص ٢٥٢، البدر المنير ج ٦ ص ٥٢٥

(٢) سبل السلام ج ٢ ص ٢٢ بتصرف.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع ج ٥ ص ٧ برقم ٢٣٢٠٣.

(٤) حاشية الصاوي ج ٣ ص ١٠٠.

الثاني: لأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي.

الثالث: لأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير ذكر مدة، فلم يصح كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً^(١).

ثانياً: أدلة القول الثاني، استدلو على ذلك بالأثر ومنه ما يلي:

١- روى عبد الرحمن بن فروخ: أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمئة لصفوان^(٢).

٢- روي عن ابن سيرين أنه كان: لا يرى بأساً أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك^(٣).

٣- روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول: إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال: فإن لم يجئه فهو له^(٤).

وجه الدلالة:

دل ظاهر الآثار على جواز بيع العربون سواء فيما فعله نافع بن عبد الحارث في عقد البيع أو فيما روى عن ابن سيرين.

(١) المغني ج ٤ ص ٣١٢.

(٢) ذكره البخاري تعليقا في كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم، ج ٣ ص ١٢٣، واخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع، ج ٥ ص ٧ برقم ٢٣٢٢٠١.

(٣) اخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع، ج ٥ ص ٧ برقم ٢٣١٩٨.

(٤) اخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع، ج ٥ ص ٧ برقم ٢٣٢٠٢.



الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لي - والله أعلم - أن الرأي الأولي بالقبول هو ما قال به جمهور الفقهاء أصحاب الرأي الأول وهو منع بيع العربون وذلك لقوة أدلتهم، ولأنه يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١).

وبناء على ذلك فإن مصادرة الضمان المالي الابتدائي هو يعد من قبيل بيع العربون في صورة من صورته فلا يحق لصاحب المناقصة أخذه سواء ظفر المناقص بالعقد أم لا (٢).

القسم الثاني: الضمان النهائي:

وفيه يقدم المناقص الذي رست عليه المناقصة خلال مدة محددة من تاريخ إصداره برسو المناقصة عليه والتزامه بالتعاقد.

حكمه: يباح للجهة الداعية للمنافسة المطالبة بالضمان النهائي ولا يختلف حكمه عن الضمان الابتدائي، فالغاية منه هو التزام المناقص بتنفيذ كافة شروط العقد في المدة المحددة له دون تأخير أو مخالفة، كما أن مصادرة كضمان الضمان الابتدائي لا يجوز إلا إذا لم يف صاحبه بواجبه تجاه تنفيذ العقد وترتب على عدم

(١) سورة البقرة آية ١٨٨.

(٢) د/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: عقد المزايدة بين الشريعة والقانون، دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن ج ٢ ص ١٦١٥٤.



وفائه ضرر مالي للمناقص له، وفي تلك الحالة يمكن المقاصة بين مبلغ الضمان النهائي وبين ما يجب على المناقص المتعهد من تعويض مالي^(١).

ثانياً: الضمان بخطاب ضمان مصرفي:

مفهومه: يعد خطاب الضمان المصرفي صورة من صور الضمان، وهو عبارة عن: تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ معين في وقت معين^(٢).

بينما عرفه د/ بكر أبو زيد بقوله: هو تعهد قطعي مقيد بزمان محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له) - بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ويرجع البنك بعد ذلك على العميل بما دفعه عنه للمستفيد^(٣).

فائدة خطاب الضمان:

لخطاب الضمان المصرفي أهمية كبيرة في حماية المستفيد من تنفيذ المشاريع أو تأمين المشتريات وفق شروط محددة، وفي أوقات محددة، بالإضافة إلى أنه لا يقبل إصدار خطاب الضمان إلا إذا توافرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية

(١) انظر بحث د/ تقي عثمانى - عقود التوريد والمناقصة - مجلة المجمع، العدد الثاني عشر.

(٢) د/ خالد المشيقيح: المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٢.

(٣) د/ بكر أبو زيد: فقه النوازل (قضايا فقهية معاصرة) ص ٢٠١ ط / مؤسسة الرسالة.



والمعنوية^(١).

حيث يتقدم أصحاب رؤوس الأموال إلى المصارف لأخذ خطاب ضمان في حالات منها:

عند طرح المناقصات أو المزايدات يتقدم من يرغب من أصحاب الشركات وغيرهم في المشاركة فيها عند ذلك تطلب منهم الجهة المنظمة للمناقصة أو المزايدة ضماناً ، لكن بدلاً من أن يضع المناقص نقوداً تحجز عليه ولا يستفيد منها لمدة معينة ، لأنه إذا لم يتمكن من هذه المناقصة يأخذ فترة طويلة لكي يسترجع هذه النقود، يتوجه إلى المصرف لأخذ خطاب ضمان، فيعطيه المصرف خطاب بأنه ضامن لهذا العميل بمبلغ كذا وهو المبلغ الذي تطالبه به الجهة الإدارية^(٢).

وفي حالة الاشتراك في المناقصات الدولية تقوم خطابات الضمان بدورها حيث إنها توفر على مقدم الضمان القيام بإجراءات تحويل العملة واستردادها، وتحميه مما قد يتعرض له من خسائر نتيجة لاحتمال هبوط أسعار العملة^(٣).

أقسامه:

ينقسم خطاب الضمان المصرفي إلى أقسام متعددة تبعاً لاعتبارات مختلفة:

(١) د/ بكر أبو زيد: فقه النوازل (قضايا فقهية معاصرة) ص ٢٠٢.

(٢) المشيخ: المعاملات المعاصرة ص ٦٢.

(٣) مجلة البحوث الإسلامية ج ٨ ص ١٠١ نقلاً من البنوك التجارية، المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي ص ١٢٨.



أولاً: خطاب الضمان من حيث الغطاء وعدمه وينقسم إلى قسمين:

أ- أن يكون الغطاء كاملاً: بحيث يمثل الغطاء نفسه قيمة الخطاب.

مثاله: كأن يطلب العميل من المصرف خطاب ضمان بمليون جنيه، ويكون قد دفع للمصرف غطاء بمليون جنيه أو دفع أسهماً أو عقارات أو وثائق بقيمة ذلك.

ب- أن يكون الغطاء جزئياً: هو يمثل بعض قيمة الضمان.

مثاله: أن يطلب العميل من المصرف خطاب ضمان بمائة ألف ويكون قد دفع للمصرف خمسين ألفاً أو أسهماً بقيمة ذلك.

ثانياً: من حيث الغرض منه ينقسم إلى قسمين:

خطاب ضمان ابتدائي: وهو لا يختلف عن الضمان من المنافص له كما سبق، وهو يمثل نسبة ضئيلة من حجم المشروع لا تتجاوز عشرة في المائة.

خطاب ضمان نهائي: وهو تعهد من المناقص بعد التعاقد لتأكيد التزامه بتنفيذ العملية وفق الشروط والمواصفات المحددة، كما سبق^(١).

كيفية إصدار البنك لخطاب الضمان:

يتقدم طالب خطاب الضمان بطلب للبنك يحدد فيه مبلغ الضمان ومدته والجهة المستفيدة والغرض منه، ويجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور، القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً فإن البنك يطلب

(١) المشيخ: المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٢، د/ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٥ ص ٤١٦.



عادة تأمينات لقاء ذلك إما أن تكون رهناً عقارياً مسجلاً أو رهن أسهم في شركات أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقود فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الضمان - مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر أو كفالة بنك خارجي معروف، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالى ٢٥ ٪ من قيمة الضمان وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان^(١).

أما عن الحكم الشرعي لخطاب الضمان:

قبل بيان الحكم الشرعي لا بد وأن نبين العلاقة بين مصدر خطاب الضمان وبين كل من المناقص والمناقص له وعلى أساس ذلك يتضح الحكم الشرعي.

أولاً: علاقة المصدر لخطاب الضمان وهو البنك وبين الجهة المستفيدة من الخطاب وهو المناقص له علاقة ضمان وكفالة، والضمان جائز ومشروع وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.

ثانياً: علاقة المصدر لخطاب الضمان والمناقص تختلف على حسب كون الخطاب له تغطية كاملة أم لا.

حكمه: بالنظر إلى أقسام خطاب الضمان نجد أنها لا تخالف الضمان الذي ثبتت مشروعيته من خلال الأدلة السابقة فقد تحقق فيها شروط الضمان التي ذكرها الفقهاء المتقدمين من رضا الضامن، وكونه أهلاً للتبرع، وكون المضمون معلوماً

(١) فقه النوازل: مرجع سابق ص ٢٠٣.



حالا أو مالا^(١)، أما الضمان بكتاب الضمان الابتدائي فهو ضمان لدين لم يجب، حيث أن المناقص الذي يستخرج كتاب الضمان الابتدائي من البنك لكي يقدمه مع العرض للجهة الإدارية وهو ليس مديناً لها بشيء وبالتالي فإن ضمان البنك لهذا المناقص يعد ضماناً لما سيجب وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء والراجع فيها قول جمهور الفقهاء^(٢) حيث ذهبوا إلى جوازه للحاجة الداعية إليه.

أما حكم أخذ المصرف عمولة لإصداره كتاب الضمان:

فهي مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: لا يجوز للمصرف أن يأخذ مقابل على إصدار كتاب الضمان سواء كان له غطاء أم لا، وهذا قول لبعض العلماء المعاصرين^(٣).

الرأي الثاني: يجوز للمصرف أخذ مقابل على إصداره لكتاب الضمان على اعتبار أنه عقد وكالة وهو ما قال به بعض العلماء المعاصرون منهم د/ زكريا البري^(٤) وزير الأوقاف الأسبق.

(١) انظر شرح مختصر خليل ج ٦ ص ٢٢، نهاية المحتاج ج ٤ ص ٤٣٣ وما بعدها، حاشية البيجرمي ج ٣ ص ١٢١، مطالب أولي النهي ج ٣ ص ٣٠٠.

(٢) شرح مختصر خليل ج ٦ ص ٢٤، نهاية المحتاج ج ٤ ص ٤٣٩، المغني ج ٥ ص ٧١، مطالب أولي النهي ج ٣ ص ٣٠٠.

(٣) د/ بكر أبو زيد: (كتاب الضمان)، د/ عبد الستار أبو غدة: (كتاب الضمان) أبحاث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم ٢ ج ٢، د/ خالد بن علي المشيقح: المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٣، د/ ياسر بن طه: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي ص ١٢٩، أبحاث هيئة كبار العلماء ج ٥ ص ٢٨٣.

(٤) د/ زكريا البري: (كتاب الضمان) بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي العدد الثاني ج ٢.



الرأي الثالث: فرق بين ما إذا كان خطاب الضمان له غطاء أم لا فإذا كان له غطاء جاز للمصرف أخذ الأجر نظير إصداره لخطاب الضمان، وإن لم يكن له غطاء لم يجز للمصرف أخذ مقابل لأجل إصداره لخطاب الضمان لكن يجوز أخذه تكاليف الإصدار فقط أي بمقدار جهده وإجراءات عمله - التكلفة العملية - دون ربط الأجر بمقدار المبلغ الصادر به خطاب الضمان وهي ما يقدره المختصون وهذا قول لبعض العلماء المعاصرين^(١).

الأدلة والمناقشة:

أولاً: أدلة الرأي الأول، استدلو على ذلك بالمعقول من عدة أوجه:

الأول: أن خطاب الضمان المصرفي يعتبر عقد كفالة وهو عقد من عقود الإرفاق والإحسان ولا يجوز أخذ الأجر عليه^(٢).

الثاني: أن حقيقة الكفالة أنها دين على المكفول وهو المدين فإذا رده مع الزيادة فهو رباً؛ لأن المصرف سيدفع إلى الجهة الإدارية للمناقصة وسيأخذ زيادة على ذلك، فهو يعتبر قرض جر نفعاً^(٣).

الثالث: أن المصرف قد ينتفع بمبلغ الغطاء لخطاب الضمان، والغطاء من باب

(١) د/ علي السالوسي: المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي ص ١٤٣، ط/ دار الاعتصام، د/ حسن عبد الله الأمين، د/ أبو بكر زيد، د/ وهبه الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة ص ٤٧١-٤٧٢، المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ٨٥.

(٢) المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي ص ١٢٩.

(٣) د/ خالد بن علي المشيخ: المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٣ وما بعدها.



الرهن، فكان انتفاع الضامن به محرماً حيث أنه ليس بظهر يركب بنفقته ، أو ذا در يحلب بنفقته^(١).

ثانياً: أدلة الرأي الثاني، استدلو على ذلك بما يلي:

وذلك لأن الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم وهذا موجود في خطاب الضمان ، فالعميل يوكل المصرف في أن يسدد عنه إذا لم يقيم بتنفيذ العملية أو نحو ذلك ، وأخذ الأجرة على الوكالة جائز.

كما أن المصلحة تقتضي إباحة أخذ الأجرة عليه، وإذا كان مقتضى الضمان المصرفي إلزام المصرف بالمغامر التي تترتب على هذا الضمان، تنفيذاً لالتزامه، فلم لا يكون للمصرف غنم من المضمون، يؤديه العميل للمصرف الضامن نتيجة الاتفاق والرضا^(٢)

ثالثاً: أدلة الرأي الثالث، استدلو على ذلك بما يلي:

أن خطاب الضمان الذي له غطاء يعد كفالة ووكالة معاً: كفالة بالنسبة لعلاقة المصرف بالمستفيد (الطرف الثالث)، ووكالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع العميل والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر وقد نوه بعض العلماء بما قاله ابن قدامة في المغني: ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل ؛ فإن النبي ﷺ وكل أنيساً في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة ، وعمراً وأباً رافع في قبول النكاح بغير جعل أي بغير أجر. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ، ويجعل لهم عمالة. ولهذا قال له ابنا عمه: لو بعثنا على

(١) أبحاث هيئة كبار العلماء ج ٥ ص ٢٨٣.

(٢) المرجع السابق.



هذه الصدقات ، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ، ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة. فإن كانت بجعل ، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل.

أما خطاب الضمان غير المغطى فإن علاقة المصرف بالعميل علاقة كفالة، وعقد الكفالة من عقود الإرفاق كما سبق في الرأي الثاني^(١).

فإذا اشترط الضامن شيئاً لنفسه خرج الضمان عن حقيقته فمنع لذلك.

الترجيح:

بعد عرض آراء العلماء المعاصرين في حكم أخذ المصرف أجر نظير إصداره خطاب الضمان يتبين أن الراجح هو ما قال به أصحاب الرأي الثالث الذي فرق بين كون خطاب الضمان له غطاء مالي أم لا، فإذا كان له غطاء مالي جاز للمصرف أن يأخذ أجراً؛ لأن علاقته بالعميل علاقة وكالة وهي تجوز بأجر وبدون أجر، أما إذا كان غير مغطى فلا يجوز لما فيه من شبهة الربا وذلك لقوة أدلتهم ، كما أن في القول بذلك عدم فتح المجال لمن ليس لهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم في الدخول في المناقصات. - والله اعلم -

كما أن فيه حداً من التعامل الجشع والتوسع في الأعمال مما ليس في استطاعة الإنسان القيام به مما قد يضطره في النهاية إلى الخضوع لما تفرضه عليه المصارف من فوائد ربوية نظير قيامه بالسداد بمقتضى الضمان^(٢)

وقد جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر في دورة

(١) المرجع السابق.

(٢) د/ محمد الزيني: المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة ص ٨٩.



انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ، الموافق ٢٢-٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م. بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي:

١- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهايي لا يخلو: إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيم يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: (الضمان) أو (الكفالة).

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

٢- أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:

أولاً: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء^(١).

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني ج ٢ ص ١٠٣٠.



حكمة مشروعية المناقصة:

تضح الحكمة من مشروعية المناقصة من خلال عدة نقاط^(١):

١- حصول المناقص له على أكبر منفعة بأقل تكلفة، وقد أشارت الشريعة إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^(٦٧)، ولا شك أن المناقصة تحقق المنفعة بأقل تكلفة.

٢- إن عقود المناقصات تشكل وسائل رقابة على النفقات العامة التي تقوم بها الدولة؛ حتى لا تسيء استخدام الأموال العامة، مما يؤدي إلى حفظ المال العام من العبث والإهدار.

٣- عقود المناقصات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأقل التكاليف، مع دفع التهمة عمن يباشرها، خاصة إذا تعلق الأمر بالأموال العامة، أو أموال اليتامى؛ ولذلك قد تتعين المناقصات في الشراء، أو إنجاز العمل لمؤسسات الدولة العامة كالمدارس، والأوقاف، أو المصالح المتعلقة بأموال اليتامى.

٤- من خلال عقود المناقصات تسعى المؤسسات العامة، والخاصة إلى ضمان تنفيذ مشاريعها على الوجه المطلوب، وفي الوقت المحدد بما يحقق المصلحة وفق أفضل الشروط وأقل الأسعار.

(١) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير للباحث / عاطف محمد حسين أبو هرييد، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بغزة، ص ١١١.



خصائص عقد المناقصة

من خلال النظر لعقد المناقصة وما يتضمنه من عقود وشروط تبين أنه يمتاز بمجموعة من الخصائص هي على النحو التالي^(١):

١ - عقد رضائي: يعتبر عقد المناقصة كغيره من عقود المعاملات التي تتوقف على رضا المناقص والمناقص له؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾^(٢).

٢ - عقد معاوضة: إذ إن كلاً من المتعاقدين في عقد المناقصة يقصد الحصول على منفعته مقابل عوض يبذله للطرف الآخر.

٣ - عقد إذعان: حيث إن أحد المتعاقدين وهو المناقص له ينفرد بوضع شروطه مسبقاً، وليس للمناقص إلا أن يقبل العقد كاملاً، أو يرفضه كاملاً، دون أن يكون لديه الحق في تعديل الشروط.

٤ - عقد مركب: فإن عقد المناقصة يتضمن مجموعة من العقود، كعقد بيع دفتر الشروط، وعقد الضمان، بالإضافة إلى العقد المتعلق بموضوع المناقصة.

٥ - عقد ملزم: بحيث إنه إذا تم إبرام العقد بين المناقص والمناقص له فيجب أن يفي كل منهما بما التزم به، إلا إذا اتفقا على فسخ العقد، أو كان يتضمن شرطاً بذلك.

(١) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير للباحث/ عاطف محمد حسين أبو هريبد، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بغزة، ص ١١١.

(٢) سورة النساء: ٢٩.



٦- عقد محدد: بمعنى أن المناقص فيه سواء كان سلعة كما في التوريد، أو عملاً ومنفعة كما في المقاوله يُحدد تحديداً دقيقاً يُوصل إلى العلم به، فهو إذن ليس عقداً احتمالياً كالجعالة.

٧- عقد مستمر (متراخي): إذ إن عقد المناقصة في الغالب ليس عقداً فورياً، بل هو عقد تحصل فيه المنفعة على فترات كالمقاوله، ويستمر فيه البيع لفترة كالتوريد على مدى فترة زمنية معينة.

٨- عقد إجرائي: أي أنه يتم وفق منظومة من الإجراءات، كالإعلان عن المناقصة في الصحف، ثم تقديم العطاءات، وغير ذلك كما سبق بيانه، إلى أن يتم إبرام العقد مع المناقص الفائز.

٩- عقد مستحدث: فهذا النوع من العقود لم يكن معروفاً عند الفقهاء المتقدمين، وهو جائز جرياً على أصل الإباحة.

الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة:

من المعلوم أن العقود ليست غاية في حد ذاتها إنما تعقد من أجل ما يترتب عليها من التزامات في ذمة طرفيها، ومما يترتب على إبرام عقد المناقصة سواء ألت المناقصة إلى عقد توريد أو عقد مقاوله عدة التزامات منها ما يقع على المناقص ومنها ما يقع على المناقص له:

أولاً: التزامات المناقص:

تنفيذ العمل الذي تعهد به: يجب على المناقص القيام بالعمل الذي تعهد به ووفق الشروط والمواصفات المتفق عليها ما لم تكن هناك مخالفة شرعية لقوله ﷺ:



وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا^(١) وإذا لم يكن هناك ثمة شروط متفق عليها فالمرجع حينئذ إلى العرف عند أهل كل صنعة^(٢).

١ - تسليم العمل بعد إنجازه: يجب على المناقص إنجاز العمل خلال المدة الزمنية المحددة في العقد ما لم تكن هناك قوة قاهرة تمنع التسليم، وبعد إنجازه للعمل وفق الشروط والمواصفات والمدة المتفق عليها، عليه أن يقوم بتسليمه إلى المناقص له وذلك إنما يكون بأن يخلي بين ما تعهد به وبين المناقص له على الوجه والمكان المتفق عليه، وفي حالة عدم قيام المناقص بتسليم العمل منجزاً ولم تمنع قوة قاهرة التسليم فإنه بذلك يكون مخالفاً بالتزاماته مما يترتب عليه تحمل المسؤولية والجزاءات الواردة في العقد^(٣).

٢ - ضمان العمل بعد تسليمه: وهذا الضمان يعرف بضمان حسن أداء المعقود عليه بعد التسليم مدة معينة.

ثانياً: التزام المناقص له:

يلتزم المناقص له بعبء التزامات هي:

١ - تمكين المناقص من تنفيذ العمل الذي تعهد به: يجب على المناقص له أن يمكن المناقص من تنفيذ العمل ويتم ذلك بعدم الحيلولة بينه وبين البدء بالتنفيذ^(٤) عملاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٥)

(١) سبق تخريجه.

(٢) الوسيط ج ٧ ص ٦٤-٦٥، عقد التوريد ص ٥٠-٥١.

(٣) الوسيط ج ٧ ص ٩١.

(٤) أصول القانون الإداري ص ٤٢٢، عقد التوريد ص ٥٤.

(٥) سورة المائدة جزء من الآية ١.





٢- دفع العوض: حث يلتزم المناقص له بدفع المقابل المالي للمناقص وفقاً لما تم الاتفاق عليه سواء من جهة المقدار والجنس والنوع وطريقة الدفع^(١).

٣- الحق في الحصول على تعويض: قد يقوم المناقص بعمل إضافات لم تطلب منه في العقد، ولم يتم الاتفاق عليها، فإذا تبين أن هذه الإضافات مفيدة ولازمة تعين على المناقص له أن يعرض المناقص مقابل ذلك^(٢).

وقد أفتى بيت التمويل الكويتي: إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جرت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف^(٣).

حكم العجز عن تنفيذ عقد المناقصة

لما كان تنفيذ عقد المناقصة يتم على مراحل زمنية متعددة فقد يقع في هذه المدة تغير جوهرى في الأسعار نتيجة لقوة قاهرة أي حادث طارئ مثل حرب أو زلزال أو طوفان مما يترتب عليه الإخلال بميزان المعاوضة المترتب على المناقصة وهذا ينطبق على حكم الجائحة في الفقه الإسلامي.

مفهوم الجائحة لغة: مشتقة من الجوح: الجيم والواو والحاء أصل واحد، وهو

(١) أصول القانون الإداري ص ٤٢٢، عقد التوريد ص ٥٤

(٢) المرجع السابق ص ٤٣٣.

(٣) الفتاوى الاقتصادية، موقع: <http://fatawa.al-islam.com>.



الاستئصال، يقال: جاح الشيء يجوحه: استأصله، والجمع جوائح، ومنه اشتقاق الجائحة: وهي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة^(١).

الجائحة اصطلاحاً: فقد عرفها ابن عرفة بقوله: ما أُلِف من معجوز عن دفعه عادة قدراً من ثمر أو نبات بعد بيعه^(٢).

وفي المجموع: هي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها^(٣).

وفي المبدع: الجائحة. كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أو أن جذه، فهو من ضمان البائع^(٤).

من خلال تعريفات الفقهاء للجائحة: نجد أنه جاء مقتصرًا على ما تلف من الثمار بخلاف تعريفها لغة فقد جاء عاماً في الثمار وغير الثمار من الأموال.

ونظراً لذلك فقد وضع لها أحد الباحثين: تعريفاً عاماً ليشمل غير الثمار من الأموال الأخرى، وهذا التعريف مفاده أن الجائحة هي: حدث عام طارئ أثناء تنفيذ العقد، غير متوقع الحدوث وقت إبرامه، ويتعذر دفعه أو تجنب آثاره، مما يسبب خسارة فادحة للمدين إذا استمر في تنفيذ التزامه بشروطه السابقة^(٥).

(١) المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٠٣، مقاييس اللغة ج ١ ص ٤٣٧.

(٢) حاشية الدسوقي ج ٣ ص ١٨٢.

(٣) تكملة المجموع ج ١٣ ص ٩١.

(٤) المبدع شرح المقنع ج ٤ ص ١٧٠.

(٥) د/ عاطف: عقود المناقصات في الفقه الإسلامي نقلاً من كتاب: أثر الجائحة على العقد، ص ٢٨٠.



فإذا عجز المناقص عن تنفيذ العقد:

كما لو حدثت ظروف طارئة بعد إرساء العطاء على المناقص وترتب على ذلك عجزه عن الوفاء بالتزاماته وفق شروط عقد المناقصة، أو إرهاقه، جاز له اللجوء للقضاء لتخفيف ذلك عليه اعتماداً على الرأي القائل: بوضع الجوائح في الفقه الإسلامي^(١)، والمستدل عليه بقوله ﷺ: (لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ)^(٢).

وفي ذلك قال ابن تيمية: "أن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه، فكل منهما أخذ معط طالب مطلوب، فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه - مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها وتلف ما يبيع بكيل أو وزن قبل تمييزه بذلك واقباضه ونحو ذلك - لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن، ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه - وهو التلف بأمر سماوي - بطل العقد ووجب رد الثمن إلى المشتري إن كان قبض منه وبرئ منه إن لم يكن قبض، وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان وهو أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه للمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل التمكن من قبضه وله الإمضاء لإمكان

(١) ولزيادة الاطلاع في هذه المسألة يرجع للمصادر الآتية: الشرح الصغير على أقرب المسالك ج ٣ ص ٢٤١-٢٤٢، المتتقى يشرح الموطأ ج ٤ ص ٢٣٢، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٤٢٩، تكملة المجموع ج ١٣ ص ٩٠، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٤٣٠، أسنى المطالب ج ٢ ص ١٠٨، المغني ج ٤ ص ٢٣٣، كشف القناع ج ٣ ص ٢٨٥، المحلى ج ٧ ص ٢٧١-٢٧٢.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب المساقاة - باب وضع الجوائح، برواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.



مطالبة المتلف" (١).

وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي: ونصه كما يلي:

أولاً: في العقود المترخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبديلاً غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاب للملتزم ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأى أهل الخبرة الثقات.

ثانياً: ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقاً للعدل الواجب بين طرفي العقد ومنعاً للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه

(١) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج ٣٠ ص ٢٦٦.



وإن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها^(١).

ملخص الموضوع:

- ١- تهدف المناقصة للوصول إلى العرض الأقل سعراً على فرض تساوي المتقدمين جميعهم من حيث الشروط والمواصفات المذكورة في كراسة الشروط.
- ٢- من أهم المبادئ التي تقوم عليها المناقصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين.
- ٣- تتضمن المناقصة الكثير من الإجراءات التي تحقق مبدأ السرية في المنافسة.
- ٤- تستمد أحكام المناقصة من المزايدة فهي أقرب المعاملات إليها فيبينهما علاقة تضاد.
- ٥- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة كراسة الشروط بما لا يزيد على قيمته الفعلية
- ٦- لا مانع شرعاً من أخذ ضمانات من المناقصين للدخول في المناقصة.
- ٧- إذا عجز المناقص عن تنفيذ العقد لظروف طارئة بعد إرساء العطاء عليه، جاز له اللجوء للقضاء لتخفيف ذلك عليه اعتماداً على الرأي القائل: بوضع الجوائح في الفقه الإسلامي.

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع ج ٢ ص ١٨٢٤٨.



للتوسع في موضوعات هذا القسم ينظر إلى:

- ١ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
- ٢ - المعاملات المالية المعاصرة للدكتور/ وهبة الزحيلي.
- ٢ - المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي للدكتور/ على السالوسي.
- ٣ - مناقصات العقود الإدارية، عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة: للدكتور/ رفيق يونس المصري.

أسئلة على هذا القسم:

السؤال الأول: اذكر تعريفاً للمصطلحات الآتية:

- ١ - المناقصة.
- ٢ - مبدأ المنافسة في المناقصات.
- ٣ - خطاب الضمان المصرفي.

السؤال الثاني: بين:

- أ - العلاقة بين النجش والمناقصة.
- ب - حكم شراء كراسة الشروط
- ج - وضح الفرق بين المناقصات والسوم على السوم.



السؤال الثالث:

عرفي المزايدة، ثم أذكري أدلة من قال بجواز المزايدة مطلقاً، مع ذكر المناقشة والأدلة، وبيان القول الراجح في المسألة؟

السؤال الرابع:

اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي للمناقصة وضحى القول الراجح في المسألة مدعوماً بالدليل؟

السؤال الخامس:

ما هو القول الراجح في حكم بيع كراسة الشروط مع ذكر الدليل على ذلك؟

السؤال السادس: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:

أ- تجرى الدعوة إلى المناقصة عن طريق:..... وله فوائد كثيرة منها:.....،.....،.....

ب- من التزامات المناقص له:..... المناقص من تنفيذ العمل الذي تعهد به، ويتم ذلك بعدم..... بينه وبين البدء بالتنفيذ.

ج- المناقصة يجريها.....



السؤال السابع: ضعي علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة:

- () (١) يختلف الحكم الشرعي للمناقصة تبعاً لأنواعها وتقسيمها
- () (٢) تنقسم المناقصات باعتبار طرق إجرائها إلى مناقصات داخلية ومناقصات خارجية
- () (٣) يتغير الحكم الشرعي للمناقصات تبعاً لتغير أنواعها
- () (٤) اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع المزايدة
- () (٥) لا مانع شرعاً من أخذ ضمانات من المناقصين للدخول في المناقصة
- () (٦) اتفق الفقهاء على تحريم بيع الرجل على بيع أخيه
- () (٧) يختلف الضمان الابتدائي عن الضمان النهائي في جواز مطالبة الجهة الداعية للمناقصة بالضمان.

السؤال الثامن: اختاري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ - التكيف الفقهي للمناقصة أقرب إلى كونها

عقد مزايدة - منظومة عقود - عقد مسابقة - جميع ما سبق).

٢ - من التكيف الفقهي للمناقصات

(شبيه ببيع الاستجرار - شبيه بالمسابقة - شبيه بالمضاربة).





فهرست الموضوعات

مقدمة.....	٣
الموضوع الأول: البطاقات الائتمانية.....	٦
الوحدة الأولى: ماهية البطاقات الائتمانية ومنافعها.....	٨
الوحدة الثانية: أقسام بطاقات الائتمان وحكمها.....	١٨
الوحدة الثالثة: أطراف بطاقات الائتمان والتكييف الفقهي لأطراف التعاقد.....	٣١
الوحدة الرابعة: الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان.....	٥١
نماذج أسئلة:.....	٨١
الموضوع الثاني: الشرط الجزائي (غرامات التأخير).....	٨٤
الوحدة الأولى: تعريف الشرط الجزائي، والعوامل التي ساعدت على العمل به وصوره.....	٨٦
الوحدة الثانية: التكييف الفقهي للشرط الجزائي وذكر أنواعه وحكمه.....	٩٣
نماذج أسئلة:.....	١٢٧
الموضوع الثالث: الإجارة المنتهية بالتملك.....	١٣٠



- الوحدة الأولى: مدخل لدراسة عقد الإجارة المنتهية بالتملك: ١٣١
- المبحث الأول: في تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتملك مع بيان ما يميز هذا العقد عن غيره ١٤٢
- المطلب الأول: في تعريف الإجارة المنتهية بالتملك وما يطلق عليه من مصطلحات ١٤٣
- المطلب الثاني: نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتملك ١٤٦
- المبحث الثاني: الفرق بين عقد الإجارة المنتهية بالتملك وبين بعض عقود المعاوضات مع مزايا هذا العقد ١٤٨
- المطلب الأول: الفرق بين عقد الإجارة المنتهية بالتملك وبين عقدي البيع والإجارة التشغيلية والبيع بالتقسيط ١٤٩
- المطلب الثاني: مزايا عقد الإجارة المنتهية بالتملك ١٥٢
- الوحدة الثانية: في ذكر صور الإجارة المنتهية بالتملك مع بيان بعض المسائل الفقهية التي ينبنى عليها التكييف الفقهي لتلك الصور ١٥٥
- الوحدة الثالثة: التكييف الفقهي مع بيان الحكم الشرعي لصور الإجارة المنتهية بالتملك ١٨٠
- الوحدة الثالثة: التكييف الفقهي والحكم الشرعي لصور الإجارة المنتهية بالتملك



١٨١	
٢١٣	نموذج أسئلة
٢١٦	الموضوع الرابع: أحكام المناقصات في الفقه الإسلامي
٢١٨	الوحدة الأولى: في بيان مفهوم المناقصة وإجراءاتها والأسس التي تقوم عليها وأنواعها
٢٢٨	الوحدة الثانية: في الأحكام الشرعية للمناقصات
٢٢٩	الوحدة الثانية: الأحكام الشرعية للمناقصات
٢٦٠	الوحدة الثالثة: الضمان في المناقصات
٢٦١	الوحدة الثالثة: الضمان في المناقصات
٢٨٤	ملخص الموضوع:
٢٨٥	أسئلة على هذا القسم:
٢٨٨	فهرست الموضوعات

